

Curso Examen de Grado

Módulo 5: Fuentes de las Obligaciones

Presentación.

Módulo 5: Fuentes de las Obligaciones

Las fuentes de las obligaciones dicen relación con el nacimiento de las mismas. Se analiza pormenorizadamente la principal de todas, los contratos, como también la responsabilidad extracontractual derivada de los delitos y cuasidelitos.

Al final del módulo los alumnos deberán: a) entender y comprender el concepto de contrato, las clasificaciones legales y doctrinarias y los principios que los rigen; b) conocer y entender los distintos tipos de contratos que regula el Código Civil, específicamente los contratos consensuales, solemnes y de garantía, en cada uno de ellos los alumnos deberán saber su concepto, características y efectos; c) finalmente, se analiza la responsabilidad extracontractual emanada de los delitos y cuasidelitos, donde los alumnos deberán entender, comprender y aplicar las consecuencias jurídicas de la comisión de un ilícito civil, como también el sistema de responsabilidad que rige en nuestra legislación.

Los contenidos se presentan a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: Teoría General del Contrato.
- Unidad 2: Los Contrato en Particular. Contratos Consensuales y Solemnes.
- Unidad 3: Contratos Accesorios o de Garantía.
- Unidad 4: Interpretación de los Contratos.
- Unidad 5: Responsabilidad Civil Extracontractual.

Durante el desarrollo del módulo, los y las participantes dispondrán de los contenidos a través del sitio del curso. Accederán a recursos como PDF, sitios de interés, multimedios y bibliografía relacionada con los contenidos, así como también se propone la realización de actividades de evaluación para medir sus progresos.

Las consultas sobre contenidos, serán canalizadas a través del correo electrónico y el Foro de Debate.

Bien, iniciemos ahora nuestro aprendizaje, revisando la teoría General del Contrato.

Unidad 1: Teoría General del Contrato.

Tema 1: Generalidades.



Observación

El artículo 1437 del CC señala cuales son las fuentes de las obligaciones: **“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”.**

La preeminencia del contrato como fuente de las obligaciones se refleja en el articulado del CC, que destina a los principios generales que lo gobiernan y a las reglas que regulan los contratos más importantes, la casi totalidad de las disposiciones del Libro IV. Las restantes fuentes tienen un carácter excepcional.

1.1 Concepto del contrato.

El contrato es una convención destinada a producir obligaciones. El artículo 1438 del CC lo define de este modo: **“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa”.** En doctrina, la convención es el género y el contrato la especie. Ante la ley positiva, en cambio, las expresiones son sinónimas como claramente se advierte de los artículos 1437 y 1438 del CC.

1.2 Campo de acción del contrato.

El concepto de contrato abarca todo concierto de voluntades tendiente a crear obligaciones, tanto en el campo de los derechos patrimoniales como de los derechos de familia, sin atender a sus resultados transitorios o perdurables. Para ciertos autores, el concepto de contrato comprende sólo los actos destinados a producir obligaciones de carácter transitorio. Desde que se trata de establecer un estatuto de carácter permanente, un *modus vivendi*, el acto dejaría de ser un contrato para convertirse en una institución.

1.3 Elementos del contrato.

De acuerdo al artículo 1445 del CC: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es menester: **1°** que sea legalmente capaz; **2°** que consienta en el acto o declaración y que el consentimiento no adolezca de vicios; **3°** que recaiga sobre un objeto lícito, y **4°** que tenga una causa lícita”. En los contratos solemnes otra condición o requisito es aún indispensable: la observancia de las formas prescritas por la ley. En los contratos solemnes, el consentimiento se manifiesta o exterioriza a través del cumplimiento de las formalidades legales.

Tema 2: Clasificación de los contratos.

El Código Civil ha formulado una clasificación de los contratos: **1° contratos unilaterales y bilaterales**; **2° contratos gratuitos y onerosos**; **3° contratos conmutativos y aleatorios**; **4° contratos principales y accesorios**, y **5° contratos consensuales, solemnes y reales**. A esta clasificación legal pueden agregarse: **6° contratos nominados e innominados**; **7° contratos de libre discusión y de adhesión**, y **8° contratos individuales y colectivos**.

Esta clasificación la revisaremos a continuación:

2.1 Contratos unilaterales y bilaterales.

El artículo 1439 señala: “**El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente**”. Ejemplo de contrato unilateral es el mutuo; de contrato bilateral es la compraventa.

La distinción entre contratos unilaterales y bilaterales es fecunda en consecuencias jurídicas:

- a) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1489 del CC, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por una de las partes lo pactado. La condición resolutoria tácita sería inoperante en los contratos unilaterales.
- b) Solamente en los contratos bilaterales se plantea el problema de los riesgos, que consiste en determinar si la extinción por caso fortuito de la obligación de una de las partes extingue igualmente o deja subsistente la obligación de la otra. En los contratos unilaterales el caso fortuito extingue, como es lógico, las obligaciones de la única parte obligada.
- c) El artículo 1552 establece que en los contratos bilaterales la mora purga la mora, o, en otros términos, ninguna de las partes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra no cumpla o esté pronta a cumplir sus obligaciones recíprocas.

Los **contratos sinalagmáticos imperfectos** son aquellos contratos que generan obligaciones sólo para una de las partes contratantes, pero circunstancias posteriores a su celebración determinan que se obligue también aquella parte que inicialmente no contrajo ninguna obligación, como por ejemplo, en el depósito, el comodato o la prenda. El CC no reconoce la distinción entre contratos sinalagmáticos perfectos o imperfectos. Los contratos sinalagmáticos imperfectos son, en criterio del legislador, contratos unilaterales. Para apreciar la naturaleza del contrato es menester situarse en el momento en que se perfecciona; si, entonces, sólo una de las partes se encuentra obligada, el contrato es unilateral.

2.2 Contratos gratuitos y onerosos.

Señala el artículo 1440: **“El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno en beneficio del otro”**. Ejemplo de contrato oneroso es la compraventa; de gratuito es la donación y el comodato. De lo dicho resulta que los contratos bilaterales son siempre onerosos; al obligarse ambas partes reportan un beneficio y soportan el gravamen que significa la obligación recíproca. Los contratos unilaterales son generalmente gratuitos.

La clasificación de los contratos en gratuitos y onerosos ofrece, igualmente, considerable importancia práctica:

- a) La circunstancia de ser gratuito u onerosos el contrato determina las condiciones en que es atacable por medio de la acción pauliana, conforme al artículo 2468 del CC. Para que sean revocables los actos gratuitos, ejecutados por el deudor en perjuicio de sus acreedores, basta la mala fe del deudor; los actos onerosos son revocables a condición de que estén de mala fe el otorgante y el adquirente.
- b) Importa la distinción para determinar el grado de culpa de que responde el deudor. En los contratos onerosos, puesto que ambas partes obtienen un beneficio mutuo, el deudor responde de culpa leve. En los contratos gratuitos, responderá de la culpa grave o levísima según si la gratuidad cede en provecho del acreedor o del deudor.

2.3 Contratos conmutativos y aleatorios.

Dispone artículo 1441 del CC: **“El contrato es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio”**. La distinción entre contrato conmutativo y aleatorio tiene importancia para la rescisión por causa de lesión. La rescisión por lesión enorme sólo tiene

cabida en los contratos conmutativos, como que consiste en una grave desproporción de las prestaciones que las partes miraron como equivalentes.

2.4 Contratos principales y accesorios.

Dice el artículo 1442 del CC: **“El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella”.**

Los contratos accesorios se denominan por lo general cauciones, conforme al artículo 46 del CC. El interés de esta clasificación deriva de la aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. El contrato accesorio no puede subsistir sin una obligación principal, pero puede existir sin ella. En otros términos, se concibe el contrato accesorio sin que exista aun la obligación principal, pero es inconcebible que sobreviva a la extinción de la obligación principal.

Los contratos dependientes son ciertos contratos que no caben en la definición legal de contratos accesorios, porque su finalidad no es asegurar el cumplimiento de una obligación principal, pero manifiestamente dependen de otro contrato. Como respecto de los contratos accesorios, no se concibe su existencia independiente. Tal es el caso, por ejemplo de las capitulaciones matrimoniales.

2.5 Contratos consensuales, solemnes y reales.

El artículo 1443 del CC establece: **“El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento”.** La regla general es que los contratos sean consensuales. El otorgamiento de un instrumento que constate el acuerdo de voluntades puede tener importancia desde el punto de vista de la prueba. El contrato solemne requiere la observancia de ciertas formas, no basta el consentimiento de las partes para que se repute perfecto. El consentimiento de los contratantes debe manifestarse o exteriorizarse mediante la observancia de las formas legales. Son contratos solemnes el matrimonio, la adopción, la hipoteca, la compraventa de bienes raíces, etc. En los contratos reales tampoco es suficiente el solo consentimiento de las partes; es menester además, la tradición o entrega de la cosa que es objeto del contrato. Son contratos reales el comodato, el depósito, el mutuo, la prenda común, etc. En los contratos reales, el artículo 1443 del CC declara que es necesaria la tradición de la cosa; así ocurre en el mutuo, pero en otros contratos reales, como la prenda y el comodato, la entrega de la cosa no tiene el significado de tradición.

2.6 Contratos nominados e innominados.



Contratos nominados son aquellos que tienen una individualidad acusada y, por lo mismo, un nombre y una reglamentación legal. **Los contratos innominados**, menos frecuentes en la práctica, carecen de una denominación y, sobretodo, de una especial reglamentación. Son creaciones de las partes que usan de su libertad de contratación. Tales contratos son gobernados por las estipulaciones de las partes, por los principios generales de los contratos y por las reglas legales dictadas para los contratos afines.

2.7 Contratos de libre discusión y de adhesión.

El contrato de libre discusión supone que las partes concluyen sus condiciones como resultado de una libre deliberación. Ha adquirido creciente auge el contrato denominado de adhesión, en que una de las partes formula las condiciones del contrato y la otra se limita a prestar su aprobación o adhesión a dichas condiciones en su totalidad.

2.8 Contratos individuales y colectivos.

Contrato individual es aquel que requiere el consentimiento unánime de las partes a quienes dejará vinculadas. El **contrato colectivo** se caracteriza porque afecta a una colectividad o grupo de individuos, aunque no hayan concurrido a su celebración, por el hecho de pertenecer a ese grupo o colectividad.

Tema 3: Elementos Constitutivos del Contrato.

3.1 Cosas de la esencia de los contratos, de su naturaleza y accidentales.

El artículo 1444 dispone: “**Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales**”.

Son de la **esencia** del contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Le dan su fisonomía propia y característica, le individualizan y distingue de los demás.



Son **cosas de la naturaleza** del contrato las que no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. Pueden ser suprimidas o alteradas sin que

pierda su fisonomía característica, pero para ello hace falta una cláusula formal. A falta de una expresa estipulación, tales cosas se subentienden y reputan incorporadas al contrato.

Son **cosas accidentales** del contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Sólo pertenecen al contrato por acuerdo especial de las partes contratantes.

Tema 4: Efectos de los Contratos.

El contrato arranca su fuerza obligatoria de la voluntad de las partes. Por consiguiente, es lógico que sus efectos queden limitados o circunscritos a las personas que consintieron. No ha establecido nuestro CC una disposición expresa que consagre el principio de que los contratos no aprovechan ni perjudican a terceros, sin embargo se encuentra implícito en el artículo 1545 del CC que atribuye al contrato legalmente celebrado el carácter de ley, pero sólo entre los contratantes. En principio, el contrato no genera derechos ni impone obligaciones a terceros; nadie puede resultar acreedor o deudor sin haber consentido. Sin embargo, junto a las partes se encuentran ciertas personas que aprovechan de los efectos del acto o sufren sus consecuencias.

4.1 Efectos entre las partes.

4.1.1 Concepto de partes.

Son partes en un contrato las personas que intervinieron en su celebración, cuyo consentimiento le dio vida. Debe considerarse también como partes a aquellos que, sin intervenir personalmente en el contrato, actuaron debidamente representados, conforme al artículo 1448 del CC.

4.1.2 La ley del contrato. El artículo 1545 precisa: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. El legislador deja a las partes en libertad para señalar las normas que han de regir sus relaciones y que tales normas tienen para ellas la fuerza de una verdadera ley. Por lo mismo, las estipulaciones del contrato se imponen también a los jueces, quienes deben respetarlo para que sea acatada la voluntad contractual.

4.1.3 Limitaciones al principio.

Tiene el carácter de ley para los contratantes el contrato legalmente celebrado. Por lo tanto, el contrato debe ser válido para que tenga la fuerza obligatoria de una ley particular entre los contratantes. El contrato válido debe respetarse y cumplirse con dos excepciones: primero, que las partes acuerden abolirlo, y, segundo, que la ley autorice expresamente dejarlo sin efecto por determinadas causas.

4.1.4 Infracción de la ley del contrato.

Corresponde a los jueces interpretar el contrato en caso de controversia. En uso de esa facultad, les incumbe determinar su sentido y señalar el alcance de sus estipulaciones. Pero la calificación jurídica que corresponde atribuir al contrato, dados los hechos acreditados en el juicio y cuya apreciación corresponde soberanamente a los jueces del fondo, es un problema de derecho. Los jueces de fondo no pueden desconocer los efectos legales de una convención cuya existencia se ha constatado; la calificación jurídica de un contrato y la determinación de sus obligadas consecuencias cae dentro del control de la Corte Suprema. Del mismo modo, no es lícito a los tribunales, bajo el pretexto de interpretarlo, desnaturalizar las estipulaciones del contrato, desconocer lo pactado por los contratantes y hacerle producir efectos no queridos por las partes o contrarios a los preceptos legales que lo rigen.

4.1.5 Ejecución de buena fe.

El artículo 1546 establece: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a los que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. La ejecución de buena fe del contrato significa que debe cumplirse conforme a la intención de las partes y a las finalidades que se han propuesto al contratar. Se comprende que la conclusión de un contrato sería un problema extremadamente complejo si las partes hubieran de prever todos sus efectos y todas las consecuencias de su incumplimiento. El artículo 1546 del CC establece el gran principio de que las leyes relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes.

4.1.6 Principio de la autonomía de la voluntad.

Las partes son libres de señalar las proyecciones del contrato, su duración y, en general, sus efectos. La libertad de contratación no tiene más limitaciones, en general, que las que imponen las leyes en defensa de las buenas costumbres y del orden público. Por de pronto, los particulares pueden celebrar toda suerte de contratos, aunque no sean de aquellos que la ley ha dotado de una especial reglamentación, esto es, de contratos innominados. Las partes pueden, conforme a los artículos 1802 y 1921 del CC, hacer solemnes contratos que son naturalmente consensuales y revestirlos de las solemnidades que juzguen convenientes. En suma, las disposiciones legales que rigen los contratos son generalmente supletorias de la voluntad de las partes y pretenden interpretar esta voluntad que no ha llegado a manifestarse.

4.1.7 Limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad.

El principio de la autonomía de la voluntad descansa en la hipótesis optimista de la igualdad de los contratantes; éstos, libremente, formularán las normas más adecuadas para satisfacer sus necesidades. Pero desde que se reconoce que el contrato no es el fruto de un acuerdo de voluntades en que las partes actúan en un pie de igualdad, el principio ha debido sufrir considerable descrédito. Una materia de tanta envergadura como el contrato de trabajo escapa a

la libre discusión de los contratantes. Múltiples leyes regulan el precio de venta y arrendamiento de ciertos bienes, reglamentan las condiciones en que pueden introducirse al país determinadas mercaderías, etc. La estabilidad del contrato tiende a hacerse más precaria con instituciones como, por ejemplo, el concepto de lesión y la teoría de la imprevisión.

4.2 Efectos respecto de terceros.

4.2.1 ¿Quiénes son terceros?



Entre los no contratantes hay personas cuya situación es radicalmente diversa. Preciso es distinguir entre: **los herederos o sucesores a título universal; los sucesores a título singular; los acreedores de las partes, y, los verdaderos terceros que la doctrina llama, para distinguirlos con nitidez, penitus extranei.**

4.2.2 Herederos o sucesores a título universal.

No pueden considerarse extraños al contrato, pese a que no intervinieron en su celebración. Los herederos representan al causante, se identifican con él, le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, conforme al artículo 1097 del CC. Se dice que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos. Los contratos, pues, aprovechan y perjudican a los herederos de modo que sus efectos pueden invocarse por ellos y contra ellos. Pero esta regla tiene algunas excepciones:

- a) Se exceptúan desde luego, aquellos contratos que se celebran intuitu personae.
- b) Se exceptúan, asimismo, los contratos de que derivan derechos personalísimos.
- c) Se exceptúan también los contratos en que las partes han convenido expresamente que sus consecuencias no ligarán a sus herederos.

4.2.3 Sucesores a título singular.

Adquieren de su causante determinados bienes o derechos, no le suceden en todo o en una cuota de su patrimonio. El derecho del causahabiente a título singular se mide exactamente por el de su causante, de acuerdo con la regla de que nadie puede transferir más derechos que los que posee. Por consiguiente, los contratos por los que el autor había consolidado, transformado, aumentado o disminuido su derecho, aprovecharán o perjudicarán al causahabiente a título singular. Pero los contratos que no afectan al derecho mismo, ni para mejorarlo, disminuirlo, consolidarlo o transformarlo, no pueden ser opuestos al causahabiente ni invocados por éste. Dos condiciones deben reunir los contratos para que afecten a los sucesores a título singular: primero, deben ser anteriores a la adquisición, y, segundo, deben referirse al mismo bien adquirido.

4.2.4 Acreedores de las partes.

La prenda general se verá incrementada por las adquisiciones que haga el deudor y experimentará una disminución con las nuevas obligaciones que contraiga. En este sentido, los contratos celebrados por el deudor afectan a los acreedores y les son oponibles; los acreedores, en suma, no son partes pero tampoco se les puede considerar por completo terceros. La confianza ilimitada que los acreedores han puesto en su deudor supone que éste les pague con la misma moneda. Por consiguiente, deben sufrir los resultados de sus negocios desafortunados, pero no las consecuencias de sus actos fraudulentos. Asimismo, los acreedores pueden desconocer los actos simulados del deudor.

4.2.5 Los terceros extraños.

Son aquellos a quienes no liga ni ligará en el futuro ninguna relación con los contratantes. Para estos terceros rige plenamente el principio de la relatividad de los efectos de los contratos. El contrato no puede conferirles ni quitarles un derecho, convertirles en acreedores o deudores.

4.3 Excepciones al principio de la relatividad de los contratos.

El principio de la relatividad de los efectos del contrato tiene diversas excepciones. Merece citarse, como ejemplo, el contrato de matrimonio, pues algunas de sus consecuencias se imponen a extraños. Pero ésta y otras analogías no constituyen propiamente una excepción al principio general, en el sentido de que los efectos del contrato alcanzan a terceros porque así lo han querido las partes. El contrato colectivo de trabajo, en cambio, constituye una excepción típica porque se celebra con el propósito deliberado de crear derechos y obligaciones para terceros. Merecen un párrafo aparte la estipulación a favor de otro y la promesa por otro.

4.3.1 La estipulación a favor de otro.

El interés de la estipulación a favor de otro deriva de que importantes contratos adoptan la forma de tal estipulación: el contrato de seguro de vida, el contrato de transporte cada vez que el consignatario es una persona jurídicamente extraña al consignante, la estipulación que celebran el comprador y vendedor de un establecimiento de comercio por la cual el segundo se obliga, por ejemplo, a conservar a su servicio al actual personal, etc.

El artículo 1449 del CC dispone: **“Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona aunque no tenga derecho para representarla, pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado, y mientras no intervenga su aceptación tácita o expresa, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él”.** Intervienen en la estipulación tres personas: el estipulante, el prometiende y el tercero beneficiario.

Es menester que el tercero sea extraño a la convención, por esto resulta indispensable que el estipulante no tenga derecho para representar al tercero. Tampoco podrá considerarse al beneficiario como un extraño cuando invista la calidad de heredero. Es preciso que el estipulante obre a nombre propio, pues en caso contrario será un agente oficioso. Sólo el tercero puede demandar lo estipulado; la particularidad de esta institución consiste, justamente, en que crea para el tercero un derecho exclusivo y directo.

El contrato es revocable por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. La revocación es el resultado de un acuerdo de voluntades y no un acto unilateral del estipulante. Podrá dejarse sin efecto íntegramente el contrato o sólo alterarse sus términos. La revocación puede ejercitarse libremente, aunque no siempre en forma impune para el estipulante.

La aceptación del tercero puede ser expresa o tácita. Conforme al artículo 1449 constituye aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato. La aceptación puede prestarse en todo tiempo, mientras las partes no hayan revocado la estipulación, pero la aceptación no es una condición para la adquisición del derecho por el tercero pues el derecho nace para él directamente de la estipulación. La aceptación, pues, no condiciona la incorporación del derecho al patrimonio del tercero, sino que hace irrevocable el contrato.

En cuanto a **la naturaleza jurídica de la estipulación**, la doctrina no se encuentra conteste:

- a) **Para la doctrina de la oferta**, supone que el estipulante ofrece al tercero el derecho de que se trata y este lo incorpora a su patrimonio por medio de la aceptación. El estipulante adquiere para sí el derecho y lo incorpora a su patrimonio; luego ofrece al tercero transmitirle el derecho, traspasarle los beneficios de la estipulación, que le sustituya como acreedor del promitente. La teoría de la oferta ha sido abandonada por los siguientes motivos: primero, el derecho del tercero no nacería sino al intervenir su aceptación y mientras tanto habría una simple oferta sujeta a todas las contingencias de una póliza; y, segundo, porque el tránsito del derecho por el patrimonio del estipulante puede ser igualmente fatal para el beneficiario, por lo que los propósitos del estipulante podrían llegar a frustrarse.
- b) **La doctrina de la agencia oficiosa** considera al estipulante como un gestor de negocios y reputa interesado al tercero. El estipulante gestiona intereses ajenos y no los suyos propios. La aceptación no es otra cosa que la ratificación del interesado de una gestión que le resulta beneficiosa. Los efectos de la ratificación se retrotraen al momento del contrato; la ratificación convierte la gestión en un mandato y, en suma, se considera que el tercero ha tratado directamente con el promitente. Esta doctrina presenta ventajas en relación a la de la oferta porque la operación ya no tiene el carácter precario que tenía pues la gestión puede ser ratificada aún después de la muerte del gestor. Además, el derecho no permanece en el patrimonio del estipulante, antes de la aceptación, expuesto a la acción de los acreedores y de los herederos. Pero es innegable que median entre la estipulación y la agencia oficiosa

diferencias insalvables, tanto así que se concluye que la agencia oficiosa es excluyente de la estipulación. Por de pronto, el estipulante actúa a nombre propio mientras que el gestor es un mero intermediario y obra a nombre del interesado. Por otra parte, no media entre el estipulante y el tercero ninguna relación, éste no podría reclamar cuentas a aquél.

- c) **La doctrina de la creación directa del derecho** considera la estipulación a favor de otro, francamente, como una derogación del principio general en virtud del cual los contratos no aprovechan a los terceros. Por excepción al principio el contrato crea directamente un derecho para el tercero, como los que genera para las partes. El derecho del tercero, antes que el futuro acreedor manifieste su voluntad, se origina en una declaración unilateral de la voluntad del estipulante.

En cuanto **a los efectos de la estipulación a favor de otro**, para una mejor comprensión, conviene estudiarlos desde un triple punto de vista:

- a) En cuanto a las relaciones entre el tercero y el prometiende; el tercero beneficiario, desde el momento de la estipulación queda convertido en acreedor del prometiende. Como consecuencia, puede el tercero reclamar del prometiende el cumplimiento de la prestación debida. Pero, aunque investido del derecho de demandar el cumplimiento de la estipulación, el tercero no es parte del contrato.
- b) En cuanto a las relaciones del tercero con el estipulante; no media entre ellas ninguna relación jurídica derivada de la estipulación.
- c) En cuanto a las relaciones del estipulante con el prometiende; la estipulación ofrece la peculiaridad de que el estipulante, pese a su condición de parte, no puede demandar el cumplimiento de lo convenido, pues este derecho corresponde sólo al tercero beneficiario. Por su parte, el artículo 1536 dispone que es eficaz la cláusula penal en que el prometiende se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido. Pero no es dudoso que el estipulante tenga derecho a pedir la resolución del contrato.

4.3.2 La promesa por otro.

El artículo 1450 del CC dispone: **“Siempre que uno de los contratante se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa”**.

La promesa no constituye una derogación al principio de la relatividad de los efectos de los contratos, pues, el tercero no contrae ninguna obligación sino en virtud de su ratificación, esto es, si no acepta imponérsela. Si el tercero rehúsa ratificar, no contrae ninguna obligación, y el

prometiente habrá violado su promesa de obtener que el tercero se obligue e incurrirá en la responsabilidad consiguiente.

El artículo 1536 del CC establece que si se promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplírselo prometido, valdrá la pena aunque la obligación principal no tenga efecto por la falta del consentimiento de dicha persona. La disposición es defectuosa porque sugiere que es eficaz la pena sin que haya una obligación principal, siendo que la obligación del prometiente existe con independencia que el tercero no haya aceptado la suya.

Tema 5: La teoría de la inoponibilidad.

Es la sanción legal que consiste en el impedimento de hacer valer, frente a terceros, un derecho nacido de un acto jurídico válido o de uno nulo, revocado o resuelto. Dichos terceros están facultados para oponerse a que los alcancen los efectos de dicho acto jurídico. Los terceros que pueden alegar la inoponibilidad son, por lo general, los llamados terceros relativos, es decir, aquellos que pueden estimarse como representantes de las partes y que están o estarán en relaciones con éstas. En oposición a los terceros relativos, están los terceros absolutos, que son aquellos que no están ni estarán en relaciones jurídicas con los autores o las partes de un acto jurídico. En nuestra legislación, al igual que en la mayoría de los países extranjeros, los principios generales de la inoponibilidad no están regulados.



5.1 Inoponibilidades de un derecho nacido de un acto jurídico válido.

Hay formalidades que no se exigen para la constitución de un acto o contrato, sino para que los efectos de éstos puedan hacerse valer, oponerse contra terceros. La omisión de dichas formalidades es causal de las inoponibilidades de forma, que se reducen a dos: inoponibilidades por omisión de formalidades de publicidad e inoponibilidades por falta de fecha cierta.

Las inoponibilidades de fondo son aquellas que se basan en los efectos de un acto que hieren injustamente los derechos de terceros. Tales inoponibilidades son las siguientes: por falta de concurrencia, por clandestinidad, por fraude, por lesión de los derechos adquiridos y por lesión de las asignaciones forzosas.

5.1.1. Inoponibilidades de forma.

a) Inoponibilidades por omisión de formalidades de publicidad.

Son aquellas destinadas a que los terceros tomen conocimiento de un acto o contrato celebrado por las partes, o de la ocurrencia de un hecho de relevancia jurídica.

- i. Conforme al artículo 1707 del CC, las contraescrituras públicas no producen efectos con respecto de terceros cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado o copia en cuya virtud ha obrado el tercero.
- ii. Conforme al artículo 1902 del CC, la cesión de un crédito personal no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste.
- iii. Conforme al artículo 2513 del CC, la sentencia judicial que declara una prescripción hace las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, pero no vale contra terceros sin la competente inscripción.
- iv. Conforme al artículo 447 del CC, declarada en interdicción de administrar lo suyo una persona por disipación, la sentencia que hace la declaración deberá inscribirse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces.

b) Inoponibilidad por falta de fecha cierta.

Los instrumentos privados, cuya fecha es susceptible de ser alterada por las partes, no hacen fe contra terceros en cuanto a la exactitud de ella, mientras no se produzca un hecho que a los ojos de la ley dé certeza a la fecha. El artículo 1703 del CC señala que la fecha de un instrumento privado no se cuenta contra terceros sino desde el fallecimiento de algunos de los que le han firmado, o desde el día en que ha sido copiado en un registro público, o en que conste haberse presentado en juicio, o en que se haya tomado razón del o le haya inventariado un funcionario competente en el carácter de tal. Además, de acuerdo al artículo 419 del Código Orgánico de Tribunales, la fecha del instrumento privado se cuenta desde su protocolización. Tratándose de asuntos mercantiles, el artículo 127 del Código de Comercio, dice que las escrituras privadas que guarden uniformidad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros, aún fuera de los casos del artículo 1703 del CC.

5.1.2 Inoponibilidades de fondo.

a) Inoponibilidad por falta de concurrencia.

Se engloban los casos en que el acto o contrato no puede hacerse valer, oponerse, en contra de las personas que no han concurrido como partes a su celebración, por ejemplo, la venta de cosa ajena.

b) Inoponibilidad por clandestinidad.

No pueden oponerse a los terceros los actos o contratos celebrados ocultamente, por la imposibilidad de aquellos de tomar conocimiento de éstos, por ejemplo, las escrituras privadas que alteran las públicas.

c) Inoponibilidad por fraude.

Son inoponibles a los terceros los actos ejecutados en fraude de los derechos de terceros; la ley da a éstos ciertos medios para que aquellos actos no los afecten, por ejemplo, el fraude pauliano en perjuicio de los acreedores. El fraude difiere del dolo porque éste tiene lugar entre las partes cuando una de ellas se vale de engaño para perjudicar a la otra; en cambio, el fraude es una maniobra de mala fe ejecutada por una o ambas partes dirigida a perjudicar a terceros.

d) Inoponibilidad por lesión de los derechos adquiridos.

Comprende los casos en que los efectos de un acto no pueden hacerse valer contra terceros que tienen derechos adquiridos sobre las cosas a que el acto se refiere, por ejemplo, el decreto de posesión definitiva de los bienes del desaparecido es inoponible a éste si reapareciera.

e) Inoponibilidad por lesión de las asignaciones forzosas.

Si en un caso dado el testador nada asigna a sus hijos, el testamento no adolece de nulidad, es válido, pero inoponible a dichos hijos en cuanto los perjudica y ellos pueden solicitar la reforma de testamento para salvar ese perjuicio, conforme al artículo 1216 del CC.

5.2 Inoponibilidades de un derecho nacido de la nulidad o resolución de un acto jurídico.



Hay casos excepcionales en que la nulidad de un acto o contrato no puede hacerse valer en contra de terceros, los cuales tienen el derecho de que respecto de ellos el acto o contrato se mire como perfectamente válido. Un ejemplo de lo anterior, es el artículo 2058 del CC que consagra la inoponibilidad de la nulidad del contrato de sociedad por parte de los miembros de la sociedad de hecho en contra de los terceros de buena fe. Otro ejemplo lo encontramos respecto al estado civil de los hijos de un matrimonio putativo. Aunque por regla general la resolución de los actos jurídicos opera con efecto retroactivo, la resolución judicialmente declarada es inoponible a los terceros de buena fe, conforme a los artículos 1490 y 1491.

5.3 Maneras de hacer valer la inoponibilidad.

El juez no puede declarar de oficio la inoponibilidad; ésta debe ser alegada por el sujeto en cuyo favor se encuentra establecida. Generalmente la inoponibilidad se deduce como excepción por el tercero en contra del cual se pretende hacer valer el acto inoponible. En contados casos puede deducirse como acción, por ejemplo, la acción pauliana.

5.4 Extinción de la inoponibilidad.

La inoponibilidad de forma se extingue por el cumplimiento de las formalidades omitidas. Se extingue la inoponibilidad por la renuncia del tercero, ya que mira a su personal interés. En fin, la inoponibilidad se extinguirá por prescripción en los casos en que debe hacerse valer como acción, las excepciones son generalmente imprescriptibles.

5.5 Diferencias entre la nulidad e inoponibilidad.

En **primer lugar**, la nulidad ataca la validez del acto mismo, privándolo de eficacia tanto respecto de las partes como de terceros; en cambio, la inoponibilidad sólo se dirige a privar de efectos al acto respecto de terceros de buena fe.

En **segundo lugar**, la nulidad tiende a proteger a las partes del acto; y la inoponibilidad a los mencionados terceros.

En **tercer lugar**, la nulidad, sea absoluta o relativa, es una sanción de orden público, y por ende, no puede renunciarse anticipadamente; pero sí puede serlo la inoponibilidad, que es una sanción de orden privado establecida a favor de los terceros en referencia.

Tema 6: Disolución de los Contratos.

6.1 Consentimiento mutuo o resciliación.

Todo contrato se disuelve por un acuerdo de voluntades de las partes. Esta regla tiene excepciones en un doble sentido:

- a) A veces la voluntad de los contratantes es impotente para disolver el contrato, como en el caso del matrimonio.
- b) Otras veces es suficiente para poner fin al contrato la declaración unilateral de voluntad de los contratantes como, por ejemplo, en el mandato, en la sociedad y en el arrendamiento.

6.1.1 Efectos de la resciliación.

Se extienden únicamente hacia el futuro. Como consecuencia de que no opera retroactivamente la resciliación no afecta a terceros. Cuando el acuerdo de voluntades interviene antes que las estipulaciones de las partes se hayan cumplido, las obligaciones que genera se extinguen. Pero si el contrato se ha cumplido, el mutuo disenso no produce el efecto de extinguir las obligaciones,

que ya se habían extinguido mediante el pago. En tal caso, la abolición del contrato hace surgir nuevas obligaciones: las que sean menester para deshacer lo hecho.

6.2 Resolución del contrato.



Es el efecto de una condición resolutoria cumplida, especialmente de la llamada condición resolutoria tácita. La condición resolutoria opera retroactivamente; suprime los efectos del contrato para el pasado y para el porvenir. En los contratos de tracto sucesivo la resolución recibe el nombre de terminación, que produce únicamente efectos para el futuro.

6.3 Nulidad y rescisión.

Ambas suponen que el contrato adolece de vicios que lo hacen sucumbir. **La nulidad y rescisión suprimen los efectos del contrato en el pasado y en el porvenir.** Anulado o rescindido el contrato, deben volverse las cosas al estado anterior, como si no se hubiera celebrado jamás. Mientras la resolución afecta sólo, por regla general, a los terceros de mala fe, la nulidad y rescisión afectan a los terceros sin consideración a esta circunstancia, y sus efectos, por lo mismo, son mucho más radicales.

6.4 Otras causas legales.

- a) La muerte de uno de los contratantes es un modo excepcional de extinción de los contratos, pues, en principio, quien contrata lo hace para sí y para sus herederos. La muerte disuelve los contratos intuitu personae como el mandato y la sociedad.
- b) También el plazo extintivo es causal de disolución; así ocurre en la sociedad y en el arrendamiento.

Tema 7: Prelación de Créditos.

7.1 Generalidades.

Es sabido que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todo su patrimonio, excluidos únicamente algunos bienes que, por consideración de orden superior, la ley considera inembargables. Es lo que propiamente se denomina derecho de prenda general y que nuestro CC consagra en el artículo 2465 que dispone: **“Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1618 del CC”.**

Esta disposición debe complementarse con el artículo 2469 del CC que señala: “Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos”.

En cierto sentido constituye también un complemento al derecho de prenda general la norma del artículo 2468 del CC, referente a la acción pauliana, en cuanto dicha norma permite que los acreedores puedan solicitar que se dejen sin efecto las enajenaciones de bienes que el deudor hubiere hecho fraudulentamente, con lo que el derecho de prenda general cubre un ámbito mayor desde que alcanza a bienes que ya habían salido del patrimonio del deudor.

7.2 Concepto e importancia de la prelación de créditos.

La prelación de créditos se define como un conjunto de disposiciones legales que determinan el orden y forma en que deben ser pagados los diversos acreedores de un determinado deudor, cuando pretenden ser cubiertos sobre el producido de unos mismo bienes.

Alessandri señala que la prelación de créditos es el conjunto de reglas legales que determinan el orden y la forma en que deben pagarse los diversos acreedores de un deudor. Por su parte, la Corte de Valparaíso ha dicho que las normas sobre prelación de créditos son normas de carácter general para todos los casos en que, no existiendo bienes suficientes del deudor para solucionar íntegramente los créditos existentes en su contra, sea menester reglamentar la primacía y concurrencia de los acreedores al pago con el patrimonio insuficiente.

De acuerdo a lo señalado, esta institución cobra relevancia en aquellos casos en que los bienes de un deudor no son suficientes para responder del pago de todas sus obligaciones. Sin embargo, no se crea que las normas que vamos a estudiar se aplican exclusivamente a ese caso, pues también rigen en una ejecución cuando dos o más acreedores pretenden ser pagados en forma preferente con los bienes embargados, invocando una prenda o hipoteca. El cauce procesal para hacer valer la preferencia está dado por la tercería de prelación, reglamentada en el CPC en el número tercero del artículo 518 y en los artículos 525 y siguientes hasta el 529.



7.3 Concurrencia de los acreedores.

Si los bienes del deudor no son suficientes para que en ellos puedan hacerse exigibles la totalidad de los créditos de sus diferentes acreedores, en teoría hay tres formas de solucionar el problema:

- i. Mediante el principio de la prioridad, esto es, que los acreedores se vayan pagando según las fechas de sus créditos, de tal suerte que se satisfagan primero los más antiguos.
- ii. Aplicando el principio de la igualdad, esto es, pague todos los acreedores una parte proporcional al valor de sus créditos.
- iii. Dando preferencia para su pago a ciertos créditos.

7.4 Principio de la igualdad.

Nuestro CC adopta como regla general el principio de la igualdad, y así lo consagra el artículo 2469 del CC al señalar que los acreedores tienen derecho a exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo a prorrata. No se descarta, en todo caso, que por excepción ciertos créditos gocen de preferencia, al agregarse que la regla general se cumple cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos.

7.5 Causas de preferencia.

El artículo 2470 del CC expresa que las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca. De esta disposición se desprende que los términos preferencia y privilegio no son sinónimos; el primero es el **género** y es segundo una de las **especies de éste género**. La otra especie es la hipoteca.

El CC no ha definido lo que se entiende por privilegio. Alessandri lo hace señalando que es el favor concedido por la ley, en atención a la calidad del crédito, que permite a su titular pagarse antes que los demás acreedores.

Por nuestra parte, nos parece que no se justifica la distinción entre privilegio e hipoteca, pues si la razón de ella estriba en que la hipoteca otorga un derecho real que da acción persecutoria en contra de terceros, en tanto que los privilegios confieren únicamente un derecho personal, no se justifica que la prenda constituya un privilegio, en circunstancias que también da acción persecutoria contra terceros poseedores de la especie pignorada.

7.6 Fundamentos de las preferencias.

Cada caso tiene su propia explicación. Así, a veces, puede tener por fundamento el fomento del crédito. En otros, la explicación de las preferencias se encontrará en razones de humanidad, como ocurre con el pago preferente de las expensas funerales; o en razones económicas, como ocurre con el derecho del Estado de pagarse preferentemente el impuesto de retención; o en razones sociales, como ocurre con las remuneraciones de los trabajadores.

7.7 Clasificación de las preferencias.

- i. Una primera clasificación la encontramos entre privilegios e hipoteca, distinción que, como acabamos de señalar, no nos parece trascendente.
- ii. Más importancia tiene, sin duda, la que distingue entre **preferencias generales y especiales**. **La primera** es la que afecta a todos los bienes del deudor, de cualquier naturaleza que ellos sean. **La segunda** es la que afecta a determinados bienes del deudor.
- iii. El CC, para los efectos de las preferencias, distingue cinco clases de créditos. Los de **primera clase**, de **segunda clase** y de **cuarta clase** que gozan de privilegio; de **tercera clase** que son los créditos hipotecarios; y, de **quinta clase** que son los créditos valistas o quirográficos que no gozan de preferencia y que se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

7.8 Características de las preferencias.

- i. Conforme al inciso segundo del artículo 2470: “Son inherentes a los créditos para cuya seguridad se han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieran por cesión, subrogación o de otra manera”.
- ii. Constituyen un beneficio especial para determinados acreedores.
- iii. Son excepcionales, puesto que la regla general es que todos los acreedores concurren en un plano de igualdad. Por ser excepcionales son de interpretación estricta y no admiten analogías.
- iv. Siempre son legales; las partes no pueden crear preferencias no obstante que los créditos a los cuales amparan puedan tener su fuente, indistintamente, en la ley o en la voluntad de las partes.
- v. Son renunciables, porque sólo miran al interés del acreedor y no está prohibida su renuncia.
- vi. Las preferencias tienen un carácter indivisible, en virtud del cual la totalidad y cada una de las partes del objeto afectado responde a la satisfacción total de la preferencia y, recíprocamente, el crédito preferente o fracción del mismo se beneficia con la garantía.

7.9 Ámbito de la preferencia.

La preferencia ampara no sólo el capital sino también los intereses. El artículo 2491 del CC señala: “Los intereses correrán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales”.

En el caso de quiebra hay reglas especiales, contenidas en los artículos 67 y 68 de la Ley No. 18.175.

Si el crédito propiamente dicho, que es la parte principal, está garantizado con una preferencia otorgada por la ley, sin necesidad de entrar en una interpretación analógica, debemos concluir que la parte accesorio de dicho crédito, esto es, los gastos ocasionados en su cobranza, gozan también de la misma preferencia, en virtud de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

7.10 Créditos de Primera Clase: Privilegios.

7.10.1 Enunciación.

El artículo 2472 del CC dispone: “**La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se enumeran:**

- a) Las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores.
- b) Las expensas funerales necesarias del deudor difunto.
- c) Los gastos de enfermedad del deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia.
- d) Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionado.
- e) Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares.
- f) Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del Fisco en contra de las AFP por los aportes que aquél hubiere efectuado de acuerdo con el artículo 42 del DL No. 3.500.
- g) Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses.
- h) Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador, con un límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas.
- i) Los créditos del Fisco por los impuestos de retención y de recargo.

7.10.2 Características de los créditos de primera clase.

La **primera clase de créditos** presenta las siguientes características:

- i. Son créditos privilegiados conforme lo señalado en el artículo 2471 del CC.
- ii. Afectan a todos los bienes del deudor, por lo que constituyen un privilegio general, conforme al artículo 2473. Si el deudor fallece opera lo señalado en el primer inciso del artículo 2487 que dispone: “Las preferencias de la primera clase, a que están afectos los bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del heredero, salvo que éste haya aceptado con beneficio de inventario, o que los acreedores gocen del beneficio de separación pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariado o separados”.
- iii. No pasa el privilegio contra terceros poseedores; se trata entonces de un privilegio personal. Así lo establece el inciso segundo del artículo 2473 que dispone: “Los créditos enumerados en el artículo precedente no pasarán en caso alguno contra terceros poseedores”. Ello porque nadie estaría dispuesto a recibir estos bienes en caso contrario. El deudor quedaría imposibilitado de efectuar operaciones con sus propios bienes y esto ocasionaría un perjuicio a sus acreedores.
- iv. Prefieren en el orden de enumeración, conforme lo señalado en el inciso primero del artículo 2473 del CC. Los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata.
- v. Los créditos de primera clase se pagan con preferencia a los comprendidos en otras clases. Sin embargo, respecto de los bienes dados en prenda o hipoteca, los acreedores prendarios o hipotecarios se pagan con preferencia sobre estos bienes, a menos que los demás bienes del deudor sean insuficientes, pues en tal caso prefieren los acreedores de primera clase conforme lo señalado en los artículos 2476 y 2478 del CC.

El artículo 2476 señala: “Afectando a una misma especie créditos de primera clase y créditos de segunda clase, excluirán éstos a aquellos; pero si fueren insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos de la primera clase, tendrán éstos la preferencia en cuanto al déficit y concurrirán en dicha especie en el orden y la forma que se expresan en el primer inciso del artículo 2472”. Por su parte, el artículo 2478 dispone: “Los créditos de la primera clase no se extenderán a las fincas hipotecadas sino en el caso de no poder cubrirse en su totalidad con los otros bienes del deudor. El déficit se dividirá entonces entre las fincas hipotecadas a proporción de los valores de éstas, y lo que a cada una quepa se cubrirá con ella en el orden y forma que se expresan en el artículo 2472” El onus probandi le corresponde al que invoca el crédito de primera clase, por tratarse del hecho específico en que se funda su acción. Al invocar el privilegio de primera clase tiene que acreditar que fuera del bien empeñado o hipotecado, el deudor carece de otros bienes.

7.10.3 Situación especial de los créditos hipotecarios de los bancos.

En caso que los bienes del deudor sean insuficientes para pagar a los acreedores de primera clase y que, por aplicación del artículo 2478, deba hacerse efectivo su privilegio sobre los bienes hipotecados, debe tenerse presente que conforme al artículo 105 de la Ley de Bancos, el Fisco y las Municipalidades gozarán de la preferencia que les acuerdan los artículos 2472 y 2478 del CC, o sea, privilegios de primera clase, respecto de los créditos del banco, sólo cuando se trate de impuestos que afecten directamente a la propiedad hipotecada y que tengan por base el avalúo de la propiedad raíz. En otras palabras, el crédito del Fisco prefiere al del Banco en su calidad de acreedor hipotecario sólo cuando se trate de contribuciones de bienes raíces.

7.10.4 Pago de los créditos de primera clase en el caso del deudor declarado en quiebra.

El artículo 148 de la LDQ señala:

“El síndico hará pago de los créditos privilegiados de primera clase que no hubieren sido objetados, en el orden de preferencia que les corresponda, tan pronto como haya fondos para ello; reservará lo necesario para el pago de los créditos de la misma clase, cuyo monto o privilegio esté en litigio, y para la atención de los gastos subsiguientes de la quiebra.

Los créditos a que se refieren los número uno y cuatro el artículo 2472 del CC no necesitarán verificación.

Los créditos mencionados en el quinto número del mismo artículo serán pagados con cargo a los primeros fondos del fallido de que se pueda disponer, administrativamente, siempre que existan antecedentes documentarios que los justifiquen y aun antes de su verificación.

Igualmente se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los mismo términos establecidos en el inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones convencionales de origen laboral hasta el límite de un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y por las indemnizaciones legales del mismo origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 3 de la Ley No. 19.010.

Las restantes indemnizaciones de origen laboral, así como la que sea consecuencia del reclamo del trabajador de conformidad al artículo 11 de la misma ley, se pagarán por el sólo mérito de sentencia ejecutoriada que así lo ordene.

Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecido por leyes especiales”.

7.10.5 Análisis de los créditos de primera clase.

a) Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores.

El artículo 139 del CPC dispone: “Son procesales las causadas en la formación del proceso y que corresponde a servicios estimados en los aranceles judiciales; y, personales, las provenientes de los honorarios de los abogados y demás personas que hayan intervenido en el negocio y de los

defensores públicos en el caso del artículo 367 del COT”. Para que las costas personales gocen de este beneficio es necesario que se causen en el interés general de los acreedores. En los juicios ejecutivos las costas procedentes de la ejecución gozarán de preferencia aun sobre el crédito mismo, conforme lo señalado en el segundo inciso del artículo 513 del CPC.

b) Gastos funerarios necesarios del deudor difunto.

Es clara la norma en el sentido que el privilegio cubre sólo los gastos necesarios, lo que, en cada caso, deberá determinar el juez de la causa. Personalmente estimamos que para esta determinación deberá considerarse la posición social del difunto. También la norma es clara en el sentido que el privilegio cubre sólo los gastos funerarios del difunto, excluyendo los de su familia.

c) Gastos de enfermedad del deudor.

Se establece que si la enfermedad hubiere durado más de seis meses fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia. Dentro de la expresión gastos de enfermedad deben comprenderse los honorarios médicos, los costos de hospitalización, el valor de los exámenes médicos, etc.

d) Gastos generados en la quiebra del deudor.

Quedan comprendidos en el privilegio los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de administración de la quiebra, la realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para los efectos mencionados.

e) Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares.

El privilegio persigue la protección del trabajador. El precepto debe concordarse con el artículo 61 del Código del Trabajo, que señala: “Gozan del privilegio del artículo 2472 del CC las remuneraciones adeudadas a los trabajadores y sus asignaciones familiares, las imposiciones o cotizaciones y demás aportes que corresponda percibir a los organismos o entidades de previsión o de seguridad social, los impuestos fiscales devengados de retención o recargo y las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que corresponda a los trabajadores, todo ello conforme al artículo 2473 y demás pertinentes del CC. Estos privilegios cubrirán los reajustes, intereses y multas que correspondan al respectivo crédito. Para los efectos del quinto número del artículo 2472 se entiende por remuneraciones además de las señaladas en el artículo 41, las compensaciones en dinero que corresponda hacer a los trabajadores por feriado anual o descansos no otorgados. Sólo gozarán de privilegio estos créditos de los trabajadores que estén devengados a la fecha en que se hagan valer. Los tribunales apreciarán en conciencia la prueba que se rinda acerca de los créditos privilegiados a que se refiere el presente artículo”

f) Las cotizaciones para seguridad social.

Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del Fisco en contra de las AFP por los aportes que hubiere efectuado conforme al artículo 42 del DL No. 3.500. Es indudable que lo que la norma pretende es asegurar y proteger el pago de este tipo de cotizaciones para que el trabajador pueda gozar de todos los beneficios que le asegura el sistema de seguridad social vigente en el país.

g) Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses.

Este privilegio tiene por objeto facilitar al deudor la adquisición de lo necesario para poder subsistir. La causal de preferencia se refiere exclusivamente a los elementos necesarios para conservar la vida y no a otros suministros distintos como serían el vestido o la habitación, ni tampoco a los suministros suntuarios que no se compadece con la mala situación económica del deudor. Como el CC no ha dado una definición general de lo que se entiende por familia, habrá que estarse a la del artículo 815 del CC y que alcanza a una serie de personas.

h) Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral.

Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que correspondan a los trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiera, se considerarán valistas.

i) Los créditos del Fisco por los impuestos de retención y de recargo.

Los impuestos de retención y de recargo son aquellos en que el sujeto pasivo, aquel legalmente obligado al pago del impuesto, no soporta en su patrimonio el gravamen, sino que lo traslada a un tercero que es el verdaderamente incidido. En ambos casos, la ley autoriza al sujeto pasivo para trasladar la incidencia del gravamen, actuando dicho sujeto como un verdadero recaudador fiscal. La diferencia entre ambos tipos de impuesto resulta de la dirección de los flujos de dinero: si la prestación va del incidido al sujeto pasivo, el impuesto es de recargo, como ocurre con el IVA; en caso contrario, es de retención, como acontece en el impuesto único a las rentas del trabajo dependiente. Quedan excluidos, por consiguiente, los demás impuestos que no tengan éste carácter y que constituyen la regla general. También quedan fuera los demás tributos que no son impuestos, como las tasas y las contribuciones especiales o de mejoras. A nuestro juicio, no quedan cubiertas con el privilegio en estudio las multas, por el carácter excepcional de los privilegios. Pero sí los intereses, en virtud de lo establecido en el artículo 2491 y los reajustes, por tratarse simplemente de un valor actualizado.

7.10.6 Créditos con preferencia superior a los de primera clase.

Con posterioridad a la entrada en vigencia del CC se fueron dictando leyes que otorgan preferencias a ciertos créditos para ser pagados antes que cualquiera otra obligación del deudor, por ejemplo, el privilegio del acreedor en el pagaré agrario; el privilegio del acreedor en el pagaré industrial, etc. El asunto quedará solucionado con el nuevo inciso final introducido en 1993 al artículo 148 de la LDQ que señala: **“Los créditos privilegiados de primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o privilegiado establecidos por leyes especiales”**. Por consiguiente, ya no se puede seguir hablando de superpreferencia.

7.11 Créditos de Segunda Clase.

7.11.1 Enunciación.

El artículo 2474 del CC dispone: “A la **segunda clase de créditos** pertenecen los de las personas que en seguida se enumeran:

- i. El posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste en la posada, mientras permanezcan en ella y hasta la concurrencia de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños.
- ii. El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados, que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta la concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensas y daños, con tal que dichos efectos sean de propiedad del deudor. Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada o acarreados de su cuenta.
- iii. El acreedor prendario sobre la prenda”.

Debe agregarse que en virtud de leyes especiales, gozan de preferencia de segunda clase otros créditos, por ejemplo, el derecho legal de retención declarado judicialmente sobre bienes muebles, conforme al artículo 546 del CPC:

7.11.2 Características de los créditos de segunda clase.

- i. Son privilegios especiales, es decir, afectan sólo a bienes determinados. Por consiguiente, si el acreedor no se alcanza a pagar con ellos, pasa a ser valista en el exceso, conforme lo señalado en el artículo 2490 del CC.
- ii. Se pagan con preferencia a los demás créditos, salvo respecto a los de primera clase, conforme al artículo 2476 del CC. En el caso de quiebra del deudor, el inciso primero del artículo 149 de la LDQ señala: “Los acreedores de la segunda clase, incluidos los que gocen de derecho de retención judicialmente declarado, podrán ser pagados sin aguardar las resultad de la quiebra siempre que se asegure lo necesario para pagar los créditos de primera clase si los demás bienes de la masa no aparecieren suficientes para satisfacerlos”.

7.11.3 Análisis de los créditos de segunda clase.

a) Crédito del posadero sobre los efectos del deudor introducidos en la posada.

El posadero está contratando con personas que no conoce y cuya solvencia sólo podrá apreciar por el equipaje que llevan. El privilegio sólo puede hacerse efectivo:

- i. Sobre los efectos del deudor.
- ii. Que sean de su propiedad.
- iii. Que él haya introducido en la posada.
- iv. Mientras estas especies permanezcan en la posada.
- v. Sólo para cubrir los gastos de alojamiento, expensas y daños.

La ley presume que los efectos que el deudor introduce en la posada son de su propiedad.

b) Crédito del acarreador o empresario de transporte sobre los efectos acarreados.

Crédito preferente sobre los efectos acarreados que sean de propiedad del deudor, que sólo puede hacerse efectivo mientras estos efectos se encuentren en poder del acarreador, de sus agentes o dependientes. El crédito cubre lo que se le deba por gastos de acarreo, expensas y daños. La ley presume que los efectos acarreados son de propiedad del deudor. Hacemos notar que el privilegio lo tiene exclusivamente el empresario de transporte, que bien puede no ser el dueño del vehículo en que el transporte se realiza.

c) Crédito del acreedor prendario sobre la prenda.

La prenda otorga al acreedor prendario un derecho real que le permite perseguir la cosa pignorada en poder de quien se encuentre para pagarse preferentemente con su producido.

7.11.4 Nueva realidad creada con las prendas especiales sin desplazamiento.

Bajo la sola vigencia del CC no era concebible que una misma cosa fuere entregada en prenda a varios acreedores, por tratarse de un contrato real que se perfecciona por la entrega de la cosa. Esta realidad se ha visto alterada con la aparición de las distintas prendas sin desplazamiento, lo que plantea de inmediato el saber cómo prefieren los diversos acreedores prendarios cuando sobre una misma cosa se constituyen diversas prendas.

En el **caso de la prenda industrial**, los acreedores prefieren por el orden de sus inscripciones conforme al artículo 42 de la Ley No. 5.687.

En la **prenda agraria**, la Ley No. 4.097 no resuelve el problema. Sin embargo, como para poder constituir una nueva prenda cuando la cosa ya está empeñada se requiere el consentimiento del primer acreedor, parece razonable entender que concurren a prorrata. Otros, en cambio, piensan que deberían preferir en el orden de sus inscripciones que es el sistema empleado por el CC para los acreedores hipotecarios y por la ley de prenda industrial.

En la **prenda sin desplazamiento**, la Ley No. 18.112 señala que el deudor no puede gravar ni enajenar lo dado en prenda sin previo consentimiento por escrito del acreedor, por lo que parece razonable que ambos acreedores concurren a prorrata.

Estas nuevas prendas sin desplazamiento también han creado algunos problemas en el caso que el deudor tenga las especies dadas en prenda en un predio arrendado. La duda es saber quien prefiere, si el arrendador en virtud del derecho de retención que le confiere el artículo 1942 del CC o el acreedor prendario. En el caso de la prenda industrial, prefiere el acreedor prendario a menos que al momento de perfeccionarse la prenda el arrendamiento constare por escritura pública inscrita antes de la prenda, conforme a lo señalado en los artículos 26 y 45 de la ley respectiva. En la prenda agraria, el acreedor prendario podrá ejercitar, en todo caso, sus derechos con preferencia la de retención, conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la ley respectiva.

7.12 Tercera Clase de Créditos: Créditos Hipotecarios.

7.12.1 Enunciación.

El artículo 2477 del CC señala: “La **tercera clase de créditos comprende los hipotecarios**”. El artículo 2480 del CC agrega a esta clase los censos debidamente inscritos, los que según esta norma serán considerados como hipotecas y concurrirán indistintamente entre sí y con las hipotecas según la fecha de las respectivas inscripciones. También quedan comprendidos en esta clase los bienes inmuebles respecto de los cuales se ha declarado judicialmente el derecho legal de retención, siempre que este decreto se encuentre debidamente inscrito; y el crédito del aviador en el contrato de avío minero conforme a los artículos 206 y siguientes del Código de Minería.

Respecto al derecho legal de retención, el artículo 546 del CPC señala: “Los bienes retenidos por resolución ejecutoriada serán considerados, según su naturaleza, como hipotecados o constituidos en prenda para los efectos de su realización y de la preferencia a favor de los créditos que garantizan. El decreto judicial que declare procedente la retención de inmuebles deberá inscribirse en el Registro de Hipotecas”.

7.12.2 Características de los créditos de tercera clase.

- a) Constituyen créditos preferentes, no privilegiados.
- b) Otorgan una preferencia especial, que sólo puede hacerse valer sobre la finca hipotecada. Si el valor de ésta no es suficiente para pagar la totalidad del crédito, la parte no cubierta no goza de preferencia, pasando por el déficit a la lista de los créditos de la quinta clase, con los cuales concurrirá a prorrata, conforme al artículo 2490 del CC.
- c) Los créditos hipotecarios, y lo mismo respecto de los censos o avíos mineros, se pagan con el producto de la finca hipotecada, con preferencia a todos los demás créditos que se hagan efectivos contra el deudor. Sin embargo, si hay acreedores de la primera clase y los demás bienes del deudor no son suficientes para cubrir sus créditos, el déficit se hace efectivo en las fincas hipotecadas, dividiéndose entre ellas a prorrata del valor de éstas y lo que a cada una quepa se cubrirá con ella en el orden y forma que expresa el artículo 2472 del CC. En caso de haber bienes dados en hipoteca y otros en prenda, Alessandri es de la opinión que en la situación propuesta deben concurrir por el déficit primeramente los bienes dados en hipoteca y después los pignorados, Abeliuk estima que el déficit debe ser cubierto a prorrata entre los acreedores de segunda y tercera clase.
- d) Los créditos hipotecarios prefieren en el orden de su fecha y en el caso de ser de una misma fecha, en el orden de su inscripción conforme lo señalado en el artículo 2477 del CC.
- e) De conformidad al inciso segundo del artículo 2477 del CC, a cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso particular para que se les pague inmediatamente con ella según el orden de sus hipotecas.

El artículo 2479 agrega: “Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar las resultas del concurso general para proceder a ejercer sus acciones contra las respectivas fincas; bastará que consignen o afiancen una cantidad prudencial para el pago de los créditos de primera clase en la parte que sobre ellos recaiga, y que restituyan a la masa lo que sobrare después de cubiertas sus acciones”.

De acuerdo con lo que se viene diciendo, la preferencia hipotecaria puede ser alegada de diversas formas:

- i. Mediante la correspondiente tercería de prelación, en un juicio ejecutivo, iniciado por un tercero que embargue el bien hipotecado.
- ii. Cuando el juicio ejecutivo es iniciado por otro acreedor hipotecario de grado posterior, se puede hacer efectiva la preferencia en el mismo juicio en que se pide la subasta, mediante la correspondiente tercería de prelación.
- iii. Puede ser alegada en el concurso particular de acreedores hipotecarios a que se refiere el artículo 2477 del CC, independientemente de si el deudor esté o no declarado en quiebra. El artículo 71 inciso tercero de la LDQ establece: “La formación de concurso especial de

hipotecarios, respecto de una finca gravada, suspende también el derecho de cada uno de ellos para perseguirla separadamente”.

- iv. Si el deudor está en quiebra los acreedores hipotecarios deben verificar sus créditos en la quiebra de acuerdo a las disposiciones generales porque la ley no contempla ninguna excepción. El acreedor hipotecario debe verificar, únicamente que su verificación es diferente de la de los demás acreedores, pues no va a concurrir a la liquidación general de bienes, sino en cuanto cobre el mencionado déficit. Pero su crédito y preferencia pueden ser impugnados.

7.12.3 Bienes sobre los cuales recae la preferencia hipotecaria.

Por tratarse de una preferencia especial, se hace efectiva sobre el precio que resulte de la subasta de la finca, o sobre la indemnización en el caso del seguro, si se produjo el siniestro, o en el caso de la expropiación. También, por aplicación de los artículo 2420 a 2422 del CC, sobre los inmuebles por destinación o adherencia, frutos, aumentos y mejoras que haya tenido la cosa hipotecada.

Por el hecho de afectar no sólo a la finca sino también a los bienes que por accesión se reputan inmuebles, pueden generarse conflictos cuando sobre alguno de esos bienes se ha constituido también una prenda especial, sin desplazamiento. El artículo 4 de la Ley No. 4.097 sobre prenda agraria dispone que el crédito prendario gozará de preferencia, en estos bienes, sobre el acreedor hipotecario. En otras leyes, como la Ley No. 5.687 sobre prenda industrial nada se ha dicho. Para Somarriva prefiere el crédito prendario, conclusión a la que llega aplicando por analogía lo dicho para la prenda agraria. Para otros, deben concurrir ambos a prorrata, por ser esta la regla general contenida en el artículo 2469 del CC. En el caso de la Ley No. 4.072 sobre prenda de cosas muebles que se venden a plazo, se dispone que no le afectará ninguna hipoteca o gravamen sobre el inmueble sin el previo consentimiento del acreedor prendario. Situación semejante ocurre en la Ley No. 18.112 sobre prenda sin desplazamiento que dispone que se requiere del consentimiento por escrito del acreedor. En el caso de la hipoteca sobre una concesión minera, los bienes que quedan afectos a la hipoteca no pueden ser dados en prenda sin consentimiento del acreedor hipotecario.

7.12.4 Situación especial de la hipoteca sobre Aeronaves.

El **Código Aeronáutico** regula la materia estableciendo todo un sistema de prelación de créditos. Se ha dicho que constituyen una superpreferencia por cuanto confiere preferencia sobre toda clase de créditos, salvo:

- i. Costas judiciales de la acción en que se enajena forzosamente la aeronave.
- ii. Gastos por el salvamento de la aeronave.
- iii. Gastos extraordinarios para la conservación de la misma.

7.13 Cuarta Clase de Créditos.

7.13.1 Enunciación.

El artículo 2481 del CC dispone: “La **cuarta clase de créditos** comprende:

- i. Los del Fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales.
- ii. Los de los establecimientos nacionales de caridad o educación y los de las municipalidades, iglesias y comunidades religiosas contra los recaudadores y administradores de sus fondos.
- iii. Los de las mujeres casadas por los bienes de su propiedad que administra el marido, sobre los bienes de éste o, en su caso, los que tuvieren los cónyuges por gananciales.
- iv. Los de los hijos sujetos a patria potestad, por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre o la madre, sobre los bienes de éstos.
- v. Los de las personas que están bajo tutela o curaduría contra sus respectivos tutores o curadores.
- vi. Los de todo pupilo contra el que se casa con la madre o abuelo, tutora o curadora, en el caso del artículo 511”.

7.13.2 Características de los créditos de cuarta clase.

- i. Constituyen un privilegio de carácter general, es decir, se pueden hacer efectivos sobre todo el patrimonio del deudor.
- ii. Prefieren entre sí según las fechas de sus respectivas causas. En el caso de los primeros dos números del artículo 2481, la fecha será la del respectivo nombramiento; en los casos tercero y sexto del artículo 2481, la fecha será la del matrimonio; en el cuarto caso del artículo 2481, la fecha será la del nacimiento del hijo; y, en el quinto caso del artículo 2481 la fecha será la del discernimiento de la tutela o curaduría.
- iii. No dan derecho de persecución en contra de terceros conforme lo dispuesto en el artículo 2486 del CC. Hace excepción a esta regla el crédito por los gastos comunes de la unidad de un condominio que da derecho de persecución en contra de los que adquieran el piso o departamento.
- iv. Sólo se hacen efectivos después de cubiertos los créditos de las tres primeras clases de cualquier fecha que sean.
- v. En general, están destinados a proteger a una persona cuyos bienes son administrados por otro.

7.13.3 Distinción entre los diferentes créditos de cuarta clase.

Se puede distinguir dentro de la enumeración del artículo 2481 dos clases de crédito:

- i. Los de ciertas personas en contra de quienes administran sus bienes y que son los tres primeros números del artículo.
- ii. Los de los incapaces en contra de sus representantes legales y que son los dos últimos números del artículo.

7.13.4 Análisis de los créditos de cuarta clase.

a) Créditos del Fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales.

Cualquiera que sea el motivo por el cual una persona recaude o administre bienes fiscales opera este privilegio, sin que importe la denominación del cargo.

b) Créditos de los establecimientos públicos en contra de sus administradores y de los recaudadores de fondos.

Lo tienen exclusivamente las personas jurídicas e derecho público, distintas del Fisco, cualquiera sea su denominación. Rige para las iglesias de cualquier culto.

c) Privilegio de la mujer casada por lo bienes de su propiedad que administra el marido.

Sólo tiene cabida respecto de la mujer que se encuentra casada en sociedad conyugal, pues sólo en ese caso el marido administra los bienes sociales y los bienes propios de la mujer. Pueden alegar este privilegio sólo las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal, sus herederos y sus cesionarios.

Respecto a cuáles serían los bienes de la mujer amparados por la disposición, Alessandri sostiene que limitar el privilegio solo a los bienes propios de la mujer, bienes que el marido debe restituir en especie, importa limitar los efectos de la norma, pues tratándose de bienes propios de la mujer, no necesita la protección. Por ello afirma que también quedan comprendidos en el privilegio los créditos que la mujer casada tenga contra el marido por los precios, saldos o recompensas de los bienes que ella aportó o adquirió a título gratuito durante el matrimonio.

Respecto a la oportunidad en que la mujer puede hacer efectiva su preferencia, es evidente que la mujer no puede hacer efectivo el privilegio sino hasta que la sociedad conyugal se disuelva.

Respecto de los bienes sobre los que se hace efectiva la preferencia, se ha discutido si la mujer puede hacer efectivo el privilegio exclusivamente en bienes del marido o también en los bienes sociales. Según algunos sólo puede hacer efectivo el privilegio en los bienes propios del marido. Alessandri piensa lo contrario porque la única manera de proteger los intereses de la mujer y de conciliar las reglas que rigen la responsabilidad de ella por las deudas del marido es admitir que la mujer goza de preferencia no solamente en los bienes que forman el patrimonio propio del marido, sino en los bienes que constituyen el patrimonio de la sociedad conyugal. La jurisprudencia se ha inclinado en este sentido.

La mujer es quien debe alegar el privilegio y, además, conforme lo dispuesto en el artículo 2483 del CC, debe probar la existencia de los bienes administrados por el marido mediante inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de capitulaciones matrimoniales, de donación, venta, permuta, u otros de igual autenticidad. El artículo 2385 dispone que en el caso que lo demandado fueren indemnizaciones por una administración culpable o dolosa, los cargos podrán probarse de cualquier modo fehaciente. Por último, la misma disposición señala que la confesión del marido, del padre o madre de familia, del tutor o curador fallido, no hará prueba por sí sola contra los acreedores, con el fin de evitar posibles colusiones.

d) Crédito privilegiado del hijo por los bienes administrados por su padre o madre.

Este privilegio corresponde al hijo no emancipado que se encuentra sometido a la patria potestad de su padre, de su madre o de ambos, conforme lo señalado en el artículo 244 del CC. El padre, la madre, o ambos en su caso, administran y usufructúan de la generalidad de los bienes del hijo, salvo aquellos que éste adquiere con su trabajo, que constituyen su peculio profesional o industrial, bienes éstos últimos que el hijo administra personalmente conforme al primer número del artículo 250 del CC; o aquello que el hijo recibe a título de donación, herencia o legado, con la condición de que no tenga el goce o la administración quien ejerce la patria potestad,; o en que se ha dispuesto que tenga el goce de estos bienes el hijo, de acuerdo a lo señalado en el segundo número del artículo 250 del CC; o cuando corresponden a herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la patria potestad, conforme a lo señalado en el tercer número del artículo 250 del CC.

Este privilegio tiene por objeto que el hijo pueda cobrar preferentemente a su padre o madre lo que éste o ésta le adeude cuando termine su administración sea a título de restituciones, indemnizaciones, intereses, etc.

Lo mismo que en el caso anterior, para que el hijo pueda gozar de este privilegio tiene que alegarlo y además debe probar cuales son los bienes que ha administrado su padre.

El privilegio lo hace efectivo el hijo en los bienes de su padre, o de su madre si es ella la que administra.

e) Privilegio de los pupilos sobre los bienes de los guardadores.

Conforme al artículo 391 del CC: “El tutor o curador administra los bienes del pupilo y es obligado a la conservación de estos bienes y a su reparación y cultivo. Su responsabilidad se extiende hasta la culpa leve inclusive”. Por su parte, el artículo 415 le obliga a llevar una cuenta fiel, exacta y, en lo posible, documentada, con el objeto de que terminada su gestión pueda restituir los bienes a

quien corresponda y pague los saldos que resulten en su contra. Por lo tanto, el privilegio en estudio tiene por objeto defender al pupilo de una administración fraudulenta de su guardador. La doctrina entiende que este privilegio sólo cabe respecto de los tutores o curadores que ejercen la guarda sobre la persona del pupilo, siendo por ello improcedente en las curadurías de bienes y en las curadurías especiales. Lo mismo que en los casos anteriores, debe ser alegado y debe probarse la existencia de los bienes administrados por el tutor o curador.

f) Privilegio de todo pupilo contra el que se casa con la madre o abuelo, tutora o curadora.

Se encuentra tácitamente derogado por la Ley No. 5.521 de 1934 que eliminó la responsabilidad solidaria de los que se casaren con la madre, abuela, tutora o curadora del pupilo.

7.14 Créditos de Quinta Clase: Acreedores Valistas o Quirografarios.

De conformidad al artículo 2489 la quinta clase comprende los créditos que no gozan de preferencia y su inciso segundo señala: **“Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha”**.

Debe recordarse que los créditos preferentes que no se cubren en su totalidad por los medios contemplados en la ley para la respectiva preferencia pasarán por el déficit a la lista de los créditos de la quinta clase, con los cuales concurrirán a prorrata, conforme lo señalado en el artículo 2490 del CC.

Unidad 2: Los Contratos en Particular. Contratos Consensuales y Solemnes.

Tema 1: La Promesa.

1.1 Concepto.

La promesa de celebrar un contrato es, ella misma, un contrato: **el contrato de promesa**. Diversas circunstancias suelen hacer imposible o inconveniente a las partes celebrar, desde luego, un contrato proyectado, de modo que sea necesario, postergar su celebración para un futuro próximo o lejano. Si bien el contrato no puede celebrarse aún, interesa a menudo a las partes quedar desde ya comprometidas a celebrarlo, cuando sean allanadas las dificultades presentes.

La promesa es un contrato en que una o ambas partes se obligan a celebrar en el futuro un determinado contrato.

1.2 La promesa es un contrato.

Difiere la promesa de la simple oferta, policitación o propuesta pues supone un acuerdo de voluntades aunque sólo una de las partes resulte obligada a celebrar el contrato primitivo.

1.3 Promesa y contrato prometido.

La promesa y el contrato prometido son dos actos jurídicos diferentes, aunque medie entre ambos una íntima conexión. La promesa tiene por objeto celebrar otro contrato y produce el efecto de obligar a una de las partes o a ambas a celebrarlo. El contrato prometido puede tener los más variados objetos y producir los más diversos efectos, según su naturaleza. Ambos contratos se suceden: la celebración del contrato prometido importa el cumplimiento de la promesa cuyos efectos, en consecuencia, se extinguen. Sin embargo, ambos contratos suelen confundirse. Si el contrato prometido es consensual, como una compraventa de bienes muebles, la promesa puede equivaler al contrato prometido.

1.4 Reglamentación del Código Civil.



El CC se ocupa de la promesa en general, sin referirla a un determinado contrato. Las reglas generales son aplicables, pues, a cualquiera que sea el contrato que se prometa celebrar. Con todo, la regla del artículo 1554 del CC no puede referirse sino a la promesa de celebrar un contrato, real o solemne. Así se explica que el número 4 establezca que debe especificarse cabalmente el contrato prometido, de modo que sólo falte para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Si el contrato no es real ni solemne, la cabal especificación del contrato prometido, el cabal acuerdo acerca de sus estipulaciones, trae como consecuencia que el contrato quedará perfecto desde ya, o en otros términos, la promesa se identificará con el contrato prometido.

1.5 Requisitos de la Promesa.

El artículo 1554 dispone: “La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes: 1° que la promesa conste por escrito; 2° que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces; 3° que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato, y, 4° que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que sólo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban”.

De la disposición transcrita resulta que la promesa requiere de los siguientes requisitos:

- a) Que conste por escrito.
- b) Que el contrato prometido sea válido.
- c) Que se convenga un plazo o condición para fijar la época en que el contrato prometido debe celebrarse.
- d) Que el contrato prometido se especifique de tal modo que para su perfeccionamiento falte sólo la tradición de la cosa o las solemnidades legales.

1.6 La promesa debe constar por escrito.

Es suficiente una escritura privada aunque el contrato prometido requiera para su perfeccionamiento que se otorgue escritura pública. El número 4 del artículo 1554 del CC es concluyente y pone de manifiesto que el legislador no ha intentado someter a las mismas solemnidades la promesa y el contrato que se promete. Por otra parte, cuando el legislador ha querido que la promesa conste por escritura pública, lo ha dicho expresamente, como por ejemplo, el artículo 1787 del CC que dispone que las promesas que se hacen los esposos en consideración al matrimonio deban constar en escritura pública. El contrato de seguro es otra

excepción, pues el artículo 515 del CCO establece que ajustado verbalmente vale como promesa con tal que los contratantes hayan convenido formalmente en la cosa, riesgo y prima.

1.7 El contrato prometido debe ser válido.

Se requiere que el contrato prometido no sea de aquellos que la ley declara ineficaces o, más exactamente, que sea válido, que no adolezca de nulidad. La ley se refiere ciertamente a la nulidad del contrato prometido por omisión de requisitos intrínsecos o de fondo. Se comprende que los requisitos de forma deberán observarse cuando llegue el momento de su celebración.

Promesa de compraventa de bienes embargados. **La promesa es válida y debe entenderse celebrada bajo la condición de que los bienes pueden ser enajenados en el momento de la celebración del contrato prometido.**

1.8 Estipulación de un plazo o condición.

Las obligaciones del contrato de promesa siempre quedarán diferidas para después de su celebración. Es indispensable, por lo mismo, establecer cuando deberán las partes cumplir las obligaciones que la promesa les impone, en qué momento debe celebrarse el contrato prometido. Este tiempo puede señalarse de dos maneras: mediante la fijación de un plazo o por medio de la estipulación de una condición. Pero no es preciso que el plazo o condición marque el instante preciso en que el contrato debe celebrarse; basta que por medio de estas modalidades se señale la época de su celebración.

1.8.1 Estipulación de un plazo para fijar la época de la celebración del contrato prometido.

El plazo posterga la exigibilidad de las obligaciones derivadas de la promesa y es, por lo tanto, un plazo suspensivo. El contrato prometido deberá verificarse una vez expirado el plazo. Vencido el plazo, por consiguiente, los contratantes podrán deducir las acciones pertinentes para obtener que se celebre el contrato prometido. La Corte Suprema se ha inclinado a considerar que el plazo es extintivo, interpretación que pareciera ser inadmisibles. Podrá ciertamente estipularse que el contrato deberá precisamente celebrarse dentro del plazo y que, expirado éste, quedará sin efecto la promesa. Tal estipulación importaría un pacto comisorio.

1.8.2 Estipulación de una condición para fijar la época de celebración del contrato prometido.

La condición debe ser tal que sirva efectivamente para señalar esa época. La Corte Suprema ha resuelto, generalmente, que dicha condición debe ser determinada, esto es, que deba realizarse dentro de cierto plazo. Ha negado valor a promesas en que se estipuló una condición indeterminada.

1.9 Especificación del contrato prometido.

La especificación del contrato significa que éste se individualice de tal modo que se sepa de qué contrato se trata y se precisen sus características para que no se confunda con otro. La especificación del contrato que se promete se justifica sobradamente. La promesa, de otro modo, sería prácticamente ineficaz; quedaría abierta la puerta para futuras discusiones acerca del alcance de lo estipulado. La especificación del contrato garantiza el cumplimiento de la obligación u obligaciones de las partes y hace posible, en su hora, recabar la ejecución compulsiva.

1.10 Promesa unilateral de celebrar un contrato bilateral.

La jurisprudencia se ha inclinado resueltamente por la nulidad de tales promesas y parte de la doctrina la acompaña. Se argumenta que la ley exige la especificación y ésta no sería lo cabal que la ley exige si no consta en la promesa el propósito recíproco de obligarse. Por otra parte, la promesa antedicha sería nula conforme al artículo 1478 del CC pues su obligación estaría sujeta a una condición potestativa dependiente de su sola voluntad.

La mayor parte de la doctrina acepta su validez pues la especificación del contrato prometido tiende a individualizarlo y hacerlo inconfundible con otro, lo que se cumpliría. La exigencia de que las partes contraigan en la promesa las obligaciones que son propias del contrato prometido importa asumir de antemano las obligaciones de un contrato aun inexistente. Si el legislador hubiera entendido que era menester que ambas partes en las promesas contrajeran obligaciones recíprocas ciertamente lo habría expresado. En fin, no se perciben razones morales o jurídicas para prohibir las promesas unilaterales que responden a una sentida necesidad en la vida de los negocios. El Código de Minería las acepta expresamente en su artículo 76.

1.11 Efectos de la promesa.

El artículo 1554 concluye que, concurriendo los requisitos legales, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. Esta referencia al artículo 1553 pone de manifiesto que de la promesa nacen obligaciones de hacer. Por lo tanto, podrá el acreedor instar por que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido o para que se le indemnicen los perjuicios derivados de la infracción del contrato. El artículo 531 del CPC establece que si el hecho debido consiste en la suscripción de un documento o en la constitución de una obligación, podrá el juez proceder a nombre del deudor cuando éste es requerido y no lo hace dentro del plazo que le señale el tribunal.

Tema 2: La Compraventa.

2.1 Generalidades.

2.1.1 Concepto.

Introducida la moneda como medida de valores, el primitivo trueque es reemplazado por el cambio de cosas por dinero que, facilitando las transacciones, ha permitido que el intercambio adquiriera las vastísimas proyecciones que exige el desenvolvimiento de la vida contemporánea.



El artículo 1793 del CC define el contrato de compraventa: **“La compraventa es en contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero”.**

2.1.2 Caracteres del contrato de compraventa.

Es un contrato bilateral, oneroso, regularmente conmutativo, principal y normalmente consensual. Puesto que las partes se obligan recíprocamente, el contrato de compraventa es bilateral, conforme a lo dispuesto en el artículo 1493 del CC. Las principales obligaciones que las partes contraen son dar, el vendedor, la cosa vendida; y pagar, el comprador, el precio. Son de su esencia y sin ellas el contrato no produce efectos civiles o degenera en otro contrato diferente, conforme al artículo 1444 del CC.

Debido precisamente a las prestaciones mutuas que engendra, el contrato de compraventa es un contrato oneroso. Cada parte reporta en el contrato utilidad de la obligación que para con ella se contrae y se grava con la que toma a su cargo.

La compraventa reviste, por lo general, el carácter de un contrato conmutativo. Las prestaciones a que recíprocamente se obligan comprador y vendedor se miran como equivalente, conforme al artículo 1441 del CC. Por excepción, el contrato puede ser aleatorio; la conmutatividad, por tanto, no es de la esencia de la compraventa. En aleatoria la compraventa de cosas que no existen pero que se espera que existan, conforme al artículo 1813 del CC.

La compraventa es un contrato principal porque subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención, conforme a lo señalado en el artículo 1442 del CC.

En fin, salvo las excepciones legales, el contrato de compraventa es consensual y se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, conforme al artículo 1443 del CC. El artículo 1801 expresa, en efecto, que la compraventa se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio. Por excepción la compraventa es solemne; la solemnidad consiste, por lo común, en el otorgamiento de escritura pública.

2.1.3 La compraventa es un título translativo de dominio.

De acuerdo a lo prevenido en los artículos 675 y 703 del CC, la compraventa es un título translativo de dominio, esto es, por su naturaleza sirve para transferirlo. La compraventa, pues, no transfiere el dominio, el comprador no se hace dueño de la cosa vendida y el vendedor del

precio en virtud del contrato, sino de la tradición subsiguiente. Mientras la tradición no se efectúe, comprador y vendedor son solamente acreedores de la cosa y del precio. El contrato sólo genera obligaciones.

2.1.4 Elementos del contrato de compraventa.

La compraventa consiste, esencialmente, en un acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio. Hay en el contrato de compraventa, pues, tres elementos esenciales: el consentimiento de las partes, una cosa y un precio. La cosa y el precio constituyen el objeto, respectivamente, de las obligaciones de vendedor y comprador. Las personas que celebren el contrato de compraventa deben ser legalmente capaces; son incapaces para celebrarlo, por de pronto, los que carecen de capacidad para celebrar cualquier contrato.

2.2 Formas del Contrato de Compraventa.

2.2.1 La regla general.

El contrato de compraventa es un contrato consensual, salvo las excepciones legales, y se perfecciona, por tanto, por el solo consentimiento de las partes. El artículo 1801 dispone: “La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones legales”.

El consentimiento debe recaer, en primer término, sobre la cosa que es objeto del contrato. No existirá compraventa cuando las partes padezcan de error, bien sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o bien sobre la sustancia o calidad esencial de la misma. El acuerdo de voluntades, en seguida, debe versar acerca del precio. Finalmente el consentimiento debe recaer sobre la venta misma, esto es, preciso será que una de las partes quiera vender y la otra comprar. Faltará consentimiento cuando las partes sean víctimas de un error sobre la especie de acto o contrato que se celebra.

2.2.2 Consentimiento en las ventas forzadas.

Suele ocurrir que el consentimiento en el contrato de compraventa no se manifieste espontánea y libremente. Tal cosa ocurre en las ventas forzadas como cuando, a instancias de un acreedor, se venden bienes del deudor para pagarse con el producto. Se considera que por el hecho de obligarse el deudor ha consentido de antemano en las consecuencias de la obligación, que otorga al acreedor un derecho de prenda general sobre sus bienes e, implícitamente, ha autorizado al acreedor para hacerlos vender, si la deuda no es pagada.

2.2.3 Por excepción la compraventa es solemne.

No será suficiente, entonces, que las partes convengan en la cosa y en el precio para que el contrato se reputa perfecto. Menester, será, además, que se cumplan las solemnidades o requisitos de forma que la ley prescribe.

2.2.4 Diversas clases de solemnidades.

Pueden ser establecidas por la ley o por las partes contratantes. En otros términos, pueden ser legales o voluntarias. Las solemnidades legales ordinarias son aquellas de que por la ley está revestida la compraventa de cierta clase de bienes, por ejemplo, los bienes raíces. Las solemnidades legales especiales son aquellas que la ley exige para la compraventa en atención a las circunstancias especiales en que se celebra o a las personas que intervienen, por ejemplo, las que acompañan la venta de bienes de un incapaz. Las solemnidades voluntarias son las que establecen las partes, sea añadiéndolas a las que la ley establece, sea para hacer solemne una compraventa que es naturalmente consensual.

a) Solemnidades Legales.

a.1) Solemnidades legales ordinarias.

Consisten en el otorgamiento de escritura pública. La escritura pública es, a la vez, requisito para el perfeccionamiento del contrato y el único medio de probar su existencia. El artículo 1701 del CC previene que la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y su omisión hará que los actos se miren como no ejecutados o celebrados.

• Casos en que la ley exige escritura pública para la validez de la venta.

El artículo 1801 del CC señala: “La venta de los bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas antela ley, mientras no se ha otorgado escritura pública”.

- i. Es solemne la compraventa de bienes raíces.
- ii. Es también solemne la venta de los derechos de servidumbre y de censo.
- iii. En fin, es solemne la venta de una sucesión hereditaria.

• Compraventa por intermedio de mandatarios.

No es necesario que el mandato revista las mismas formas que el contrato encomendado al mandante. El mandato debe constar por escritura pública cuándo la ley exige esta formalidad, como ocurre con el que se otorgue para contraer matrimonio o para parecer en juicio. Sin embargo, la doctrina generalmente estima que es necesaria la forma pública, y la jurisprudencia se ha pronunciado sistemáticamente en el mismo sentido.

• La inscripción no es un requisito de la compraventa de bienes raíces.

No es solemnidad de la compraventa. El contrato está perfecto desde que las partes, convenidas en la cosa y en el precio, otorgan la correspondiente escritura pública. La inscripción es la manera de efectuar la tradición de la cosa vendida, si ésta es un bien inmueble; en otros términos, es la forma como el vendedor cumple con la principal obligación que el contrato le impone.

• Es solemne sólo la venta de un inmueble por su naturaleza.

De este modo, es meramente consensual la compraventa de bienes muebles por anticipación, bienes que se reputan tales, aun antes de su separación, para los efectos de constituir un derecho

a favor de otra persona que el dueño conforme al artículo 571 del CC. Es también consensual la venta de los bienes inmuebles por destinación, esto es, los que se encuentran permanentemente destinados al uso, cultivo y beneficio de un inmueble.

a.2) Solemnidades legales especiales.

La ley reviste de solemnidades especiales la compraventa por las circunstancias en que se celebra el contrato o la calidad de las personas que lo estipulan. Dichas solemnidades suelen ser aplicables, también, a los bienes muebles.

i. Se someten a formalidades especiales las ventas forzadas ante la justicia; la que deberá hacerse previa tasación del inmueble y la publicación de avisos, en pública subasta, ante el juez, conforme a los artículos 485 y siguientes del CPC.

ii. Se someten a formalidades especiales las ventas de bienes pertenecientes a personas incapaces, y las solemnidades que comúnmente acompañan la venta son la autorización judicial y la pública subasta.

b) Solemnidades voluntarias.

Prácticamente la solemnidad consistirá en el otorgamiento de escritura pública o privada cuando la compraventa es puramente consensual. El artículo 1802 señala: “Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que las enumeradas en el artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida”. Es menester que las partes estipularen expresamente que el contrato de compraventa, cuando éste es consensual, no se repute perfecto, sin embargo, si no se otorga escritura pública o privada.

Mientras no se otorgue la escritura el pacto verbal es un simple proyecto; la facultad de retractarse de las partes es un lógica consecuencia de que el contrato no se ha perfeccionado. La facultad de retractación se mantiene hasta que ocurra alguna de las dos circunstancias siguientes: primero, hasta que se otorgue la escritura pública o privada porque, perfecto el contrato, no es lícito a las partes dejarlo unilateralmente sin efecto; o, segundo, hasta que haya principiado la entrega porque el cumplimiento del contrato, sin que se haya otorgado la escritura prevista, importa una tácita derogación de la estipulación que lo hizo solemne.

2.3 Las Arras.

2.3.1 Concepto de las arras y sus clases.

“Son una cantidad de dinero u otras cosas muebles que se dan en garantía de la celebración del contrato, o bien, en parte del precio o en señal de quedar convenidos”. Las arras, por tanto, pueden ser de dos clases y tener una doble

finalidad: primero, sirven como garantía de la celebración o ejecución del contrato; y, segundo, se dan como parte del precio o en señal de quedar las partes convenidas.

2.3.2 Las arras como garantía.

Dadas en garantía de la celebración o ejecución de un contrato, significan que las partes no han entendido ligarse definitivamente, sino que mutuamente se reservan la facultad de desdecirse perdiendo su valor. El artículo 1803 del CC dispone: “Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse; el que ha dado la arras perdiéndolas; y el que las ha recibido, restituyéndolas dobladas”.

2.3.3 Tiempo en que las partes pueden retractarse.

El artículo 1804 señala: “Si las partes no hubieran fijado plazo dentro del cual puedan retractarse, perdiendo las arras, no habrá lugar a la retractación después de los dos meses subsiguientes a la convención, ni después de otorgada escritura pública de la venta o de principiada la entrega”.

2.3.4 Las arras en señal de quedar convenidos o como parte del precio.

Constituyen un testimonio de la celebración definitiva del contrato; en otras palabras, constituyen un medio de prueba de su celebración. Las partes carecen de la facultad de retractarse porque el contrato de compraventa ha quedado perfecto, a menos que se requiera el consentimiento por escritura pública. El artículo 1805 del CC señala: “Si expresamente se dieren arras como parte del precio, o como señal de quedar convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 1801”.

Para que las arras se entiendan dadas en señal de quedar convenidos o como parte del precio es menester la concurrencia copulativa de dos circunstancias: **primero**, que las partes lo convengan expresamente; y, **segundo**, que este convenio conste por escrito. Si así no fuere se entienden las arras dadas en garantía y facultadas las partes para retractarse, conforme al inciso segundo del artículo 1805 que establece: “No constando alguna de estas expresiones por escrito, se presumirá de derecho que los contratantes se reservan la facultad de retractarse según los dos artículos precedentes”.

Las arras en garantía, pues, constituyen la regla general; para que pueda atribuírseles otro caracteres preciso un pacto expreso y escrito. El CCO en sus artículos 107 y 108, establece, por su parte, unas arras con reglas diametralmente opuestas. Las arras se presumen dadas en parte de prueba, salvo estipulación en contrario y no permite a las partes retractarse.

2.4 Gastos del Contrato de Compraventa.

Los gastos que demande el contrato de compraventa han sido tomados en cuenta en el precio y establece el legislador que son de cargo del vendedor salvo estipulación en contrario. El artículo 1806 del CC señala: **“Los impuestos fiscales o municipales, las costas de la escritura y de**

cualesquiera otras solemnidades de la venta, serán de cargo del vendedor, a menos de pactarse otra cosa”. El gasto de mayor entidad que habrá de demandar la venta de bienes raíces es el pago del impuesto llamado de transferencia. La Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado dispone que el impuesto a la compraventa, aplicable sobre el valor del contrato, con mínimo del avalúo vigente, será de cargo de quien otorgue o suscriba el documento gravado, a prorrata de sus intereses, sin perjuicio de que pueda pactarse la división del gravamen en forma distinta.

2.5 La Cosa Vendida.

Si falta la cosa vendida la obligación del vendedor carecería de objeto; tal obligación no podría existir y, por lo mismo, carecería de causa la obligación del comprador.

2.5.1 Requisitos de la cosa vendida.

Debe reunir los requisitos propios del objeto de toda declaración de voluntad: ser lícito, determinado y existir o esperarse que exista.

La cosa vendida debe reunir estos caracteres y, además, los que son peculiares para el contrato de compraventa; tales requisitos son:

a) La cosa vendida debe ser comerciable.

Se pueden vender todas las cosas, tanto corporales como incorporeales, con tal que la ley no prohíba su enajenación. El artículo 1810 dispone que: “Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporeales, cuya enajenación no esté prohibida por la ley”. La compraventa no es propiamente un acto de enajenación puesto que no transfiere el dominio; la cosa se hace ajena por la tradición subsiguiente. La compraventa de cosas cuya enajenación esté prohibida es nula, de nulidad absoluta, porque adolece de ilicitud en el objeto.

b) La cosa vendida debe ser determinada y singular.

b.1) La determinación puede especificarse específica o genéricamente. El artículo 1461 dispone que las cosas que son objeto de una declaración de voluntad es menester que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género.

La cantidad puede ser inicialmente incierta, esto es, no ser determinada sino solamente determinable. La determinación posterior, sin embargo, no podrá quedar entregada a un nuevo acuerdo de las partes, sino que deberá verificarse de acuerdo con las normas señaladas en el contrato mismo. El inciso segundo del artículo 1461 señala que: “La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla”.

b.2) La cosa vendida debe ser singular. El artículo 1811 dispone: “Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de unos y otros, ya se venda el total o una cuota”.

Es válida la venta de todos los bienes de una persona, especificándolos. Todos los bienes de una persona pueden venderse con tal que se individualicen o inventarién en escritura pública. El artículo 1811 señala: “Será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se

designen por escritura pública aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos”. Por lo tanto, la eficacia de la venta está condicionada a los siguientes requisitos: primero, que se especifiquen los bienes vendidos; segundo, que esta especificación se haga en escritura pública; y, tercero, que no se comprendan en la venta objetos ilícitos. Se entienden únicamente vendidos, no obstante cualquier estipulación en contrario, los bienes inventariados.

c) La cosa vendida ha de existir o esperarse que exista.

Conforme al artículo 1461 no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pueden venderse, pues, las cosas presentes y futuras, esto es, las que existen al tiempo de celebrarse el contrato y aquellas cuya existencia se espera en el porvenir.

c.1) Venta de cosa que dejó de existir al tiempo del contrato. Si la cosa no existe en absoluto, no hay ni puede haber compraventa. El artículo 1814 señala: “La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno”. Es indiferente que comprador y vendedor supieran o ignoraren que la cosa no existe; la falta total de objeto hace imposible que el contrato se perfeccione.

Si la cosa existe solo parcialmente el contrato es viable. El inciso segundo del artículo 1814 señala: “Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato o darlo por subsistente, abonando el precio a justa tasación”. Existe jurídicamente el contrato pero toca al comprador decidir si desiste o persevera en él, y en este último caso, le asiste el derecho de que se reajuste debidamente el precio.

c.2) Consecuencias de la mala fe del vendedor. Su conocimiento o ignorancia de la inexistencia de la cosa no influye en la validez del contrato. Pero tiene considerable importancia para otros efectos. Si el vendedor supo que la cosa no existía en todo o en parte debe reparar los perjuicios al comprador que lo ignoraba, conforme al inciso tercero del artículo 1814 que prescribe: “En que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe”.

c.3) Venta de cosa futura o que se espera que exista. La compraventa, en tal caso, se entiende verificada bajo la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir; fallida la condición, o sea, si la cosa no llega a existir, la compraventa no se habrá perfeccionado. El artículo 1813 señala: “La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir”.

c.4) Venta de la suerte. El artículo 1813 del CC dispone: “No se reputará condicional en contrato, subordinado a la condición de que la cosa llegue a existir, cuando se estipule lo contrario, o por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte”. La no existencia de la cosa no influye en la validez del contrato, sino en el provecho que las partes reportarán de él, de modo que si no llega a existir el comprador experimentará sencillamente una pérdida. La venta de la suerte, pues, no es condicional, sino que pura y simple. El contrato, en esta hipótesis, es eminentemente aleatorio.

d) La cosa no debe pertenecer al comprador.

d.1) La compra de cosa propia no vale. El artículo 1816 dispone: “La compra de cosa propia no vale; el comprador tendrá derecho a que se le restituya lo que hubiere dado por ella”. Pero será menester que el comprador tenga sobre la cosa la propiedad plena o absoluta.

d.2) Venta de cosa ajena. El artículo 1815 del CC dispone: “La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo”. Por lo tanto, es válida la compraventa de cosa ajena. Puede el vendedor contraer la obligación de hacer al comprador propietario de una cosa que no le pertenece; la ejecución de la obligación será posible en virtud de un arreglo entre el vendedor y el dueño de la cosa.

d.3) Efectos de la venta de cosa ajena. En lo que respecta a los efectos en relación al dueño de la cosa; éste es totalmente extraño al contrato y a su respecto no produce efecto alguno. No contrae el dueño ninguna obligación y conserva incólume su derecho de propiedad, mientras el comprador no haya llegado a adquirirlo por medio de la prescripción. El derecho del dueño consistirá en reivindicar la cosa contra el comprador, que será regularmente quien la posea.

En los que respecta a los efectos entre las partes; ellos se resumen de la siguiente manera:

- i. La compraventa, seguida de la correspondiente tradición, no dará al comprador el dominio de que el vendedor carecía. Únicamente le transferirá los derechos transferibles del vendedor sobre la cosa, conforme al artículo 682 del CC. Pero el comprador adquirirá la posesión de la cosa y podrá ganarla consecuentemente por prescripción, conforme al artículo 683 del CC.
- ii. Como consecuencia de ser ajena la cosa podrá verse el vendedor en la imposibilidad de entregarla, por ejemplo, por no poder conseguirla del dueño. El comprador en tal caso tiene derecho a demandar el cumplimiento del contrato o su resolución, con indemnización de perjuicios.
- iii. Si entregada la cosa al comprador el dueño de ella la reivindica, el vendedor está obligado a sanear la evicción, esto es, a defenderle en el juicio y a indemnizarle en caso de producirse una privación, total o parcial de la cosa vendida. No tiene el comprador este derecho si compró a sabiendas de ser ajena la cosa, conforme al artículo 1852 del CC.

d.4) Venta de cosa ajena ratificada por el dueño. Si el dueño de la cosa vendida ratifica el contrato, adquirirá el comprador el dominio retroactivamente. El artículo 1818 dispone: “La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta”. La redacción del precepto es confusa: la ratificación hace posible que se transfiera el dominio y, obviamente, éste se entiende transferido desde el momento de la tradición y no de la venta.

d.5) Adquisición ulterior del dominio por el vendedor. El artículo 1819 señala: “Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Por consiguiente, si el vendedor

la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador”.

2.6 El Precio.

El artículo 1793 del CC dice que el precio es: **“El dinero que el comprador da por la cosa vendida”**. Si falta el precio, carece de objeto la obligación del comprador; no puede existir su obligación y, como consecuencia, carecería de causa la obligación del vendedor.

2.6.1. Requisitos del precio.

El precio debe reunir los requisitos o cualidades que siguen:

a) El precio debe consistir en dinero.

El artículo 1793 del CC establece reiteradamente este principio. Si el precio no se estipula en dinero no hay compraventa sino un contrato diverso; el precio en dinero es, pues, un requisito de la esencia del contrato. No obsta para que exista compraventa la circunstancia de que el precio se pacte en dinero, pero que se pague con otra cosa.

a.1) Cuando hay compraventa y cuando hay permuta. El artículo 1794 señala: “Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero; y venta en el caso contrario”.

b) El precio debe ser real y serio.

Significa que exista efectivamente una suma de dinero que se pague a cambio de la cosa. No es real el precio simulado o fingido; no es serio el precio cuando es irrisorio. En relación con la voluntad de las partes, el precio real y serio significa que se tenga efectivamente la intención de pagarse por el comprador y de exigirse por el vendedor. Con relación a la cosa vendida el precio no será real o serio cuando exista entre ambos tal desproporción que resulte puramente irrisorio.

b.1) Precio justo y precio vil. Precio justo es el que equivale al valor de la cosa en oposición al precio vil que no refleja tal equivalencia. El precio vil o insuficiente no importa que la compraventa carezca de precio; la vileza del precio no excluye la existencia del contrato.

c) El precio debe ser determinado.

c.1) Determinación del precio. Es el señalamiento de la precisa cantidad que el comprador debe pagar por la cosa comprada. Esta exigencia es el resultado de la aplicación del principio general que requiere la determinación del objeto de todo acto o declaración de voluntad, contenido en el artículo 1461 del CC. La determinación del precio puede hacerse: primero, por acuerdo de las partes; segundo, por un tercero; y, tercero, no puede dejarse al arbitrio de una de las partes.

c.2) Determinación del precio por las partes. El inciso primero del artículo 1808 del CC señala: “El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes”. Esta determinación se hará regularmente en el contrato; pero no hay inconveniente para hacer la determinación a posteriori, sobre las bases señaladas en el contrato. El inciso segundo del artículo 1808 añade que: “Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones que lo fijen”. Como una aplicación de esta regla, el inciso tercero de la citada disposición señala que: “Si se trata de cosas fungibles y se venden al corriente de la plaza, se entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa”.

El artículo 139 del CCO establece una importante excepción al señalar que verificada la entrega se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y lugar en que se hubiere celebrado el contrato, y si hubiere diversidad de precios en el mismo día, el comprador deberá pagar el precio medio. De esta manera, habría compraventa a pesar de no haberse convenido en el precio, siempre que se entregue la cosa vendida.

c.3) Determinación del precio por un tercero. Puesto que su mandato arranca de la voluntad de las partes, se considera como si ellas mismas hubieran hecho la determinación. El artículo 1809 señala: “Podrá dejarse asimismo el precio al arbitrio de un tercero, y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquier persona en que se convinieren los contratante, en caso de no convenirse no habrá venta”. El contrato, en tal caso, es condicional, sujeto a la condición de que el tercero efectúe la determinación del precio.

2.7 Capacidad para Celebrar el Contrato de Compraventa.

2.7.1 Reglas Generales.

El artículo 1445 del CC establece: “**Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es menester que sea legalmente capaz**”. El artículo 1446 añade que: “Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces”. Para la compraventa como para todo contrato la capacidad es la regla general y la incapacidad constituye la excepción. Dispone el artículo 1795 del CC: “Son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato”.

Son incapaces para celebrar el contrato de compraventa, en primer término, las personas afectas a una incapacidad general para contratar. Tales son los pródigos interdictos, los sordomudos analfabetos, los menores de edad y las mujeres casadas no divorciadas ni separadas totalmente de bienes, conforme al artículo 1447 del CC.

Son incapaces, además, aquellas personas afectas a ciertas incapacidades particulares del contrato de compraventa.

2.7.2 Clasificación de las incapacidades.

Las incapacidades especiales del contrato de compraventa pueden ser dobles o simples. A ciertas personas les está vedado en absoluto celebrar el contrato de compraventa: se les prohíbe comprar y vender. A otras personas les está solamente prohibido comprar o vender.

a) Incapacidades de comprar y vender.

a.1) Compraventa entre cónyuges. El artículo 1796 del CC dispone enfáticamente que es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. Solamente es lícito celebrar entre sí el contrato de compraventa a los cónyuges perpetuamente divorciados. Los motivos de esta prohibición los encontramos, primero, en que la ley prohíbe las donaciones irrevocables entre los cónyuges y por medio de un contrato de compraventa simulado o hecho a precio vil se burlaría fácilmente la prohibición; y, segundo, los cónyuges podrían mediante una venta simulada sustraer bienes de la persecución de los acreedores.

a.2) Compraventa entre el padre y el hijo de familia. El artículo 1796 declara igualmente nulo el contrato de compraventa entre el padre o madre y el hijo de familia. Los hijos de familia son aquellos no emancipados sobre los cuales el padre o madre, en su defecto, ejerce la patria potestad. Sin embargo es válido entre el hijo de familia y el padre o madre el contrato de compraventa cuando verse sobre bienes que forman parte del peculio profesional o industrial del primero. Respecto de los bienes que forman este peculio el hijo no está sometido a patria potestad, pero la venta de estos bienes, si se tratare de inmuebles, debe ser autorizada por el juez con conocimiento de causa.

b) Incapacidades para vender.

b.1) Prohibición a los administradores de establecimientos públicos. El artículo 1797 del CC dispone: “Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente”.

c) Incapacidades para comprar.

c.1) Prohibición a los empleados públicos. Prescribe el artículo 1798 del CC: “Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio”. Rige la prohibición aunque la venta se haga en pública subasta.

c.2) Prohibición a los jueces y funcionarios del poder judicial. El artículo 1798 del CC prohíbe comprar: “A los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes en cuyo litigio hayan intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio”. La prohibición rige aunque la venta se haga en pública subasta.

El artículo 321 del COT ha ampliado considerablemente el campo de esta prohibición al señalar: “Se prohíbe a todo juez comprar o adquirir a cualquier título para sí, para su mujer o para sus hijos, las cosas o derechos que se litiguen en los juicios de que él conozca. Se extiende ésta prohibición a las cosas o derechos que han dejado de ser litigiosos, mientras no hayan transcurrido cinco años desde el día en que dejaron de serlo; pero no comprende las adquisiciones hechas a título de sucesión por causa de muerte, si el adquirente tuviere respecto del difunto la calidad de heredero abintestato”.

Las diferencias sustanciales entre ambas disposiciones son: primero, el COT prohíbe la compra aunque no se vendan a consecuencia del litigio y subsiste la prohibición hasta por cinco años; y, segundo, la disposición del COT no se aplica a los abogados y procuradores.

c.3) Incapacidad de los tutores y curadores. El artículo 1799 del CC dispone: “No es lícito a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido en el título De la administración de los tutores y curadores”. Dichas normas establecen que el tutor no puede comprar los bienes muebles del pupilo sino con la autorización de los otros tutores generales que no estén implicados de la misma manera o por el juez en subsidio. En cambio, la compra de bienes raíces del pupilo está radicalmente vedada a los tutores pues se dispone que ni aún con la autorización de los otros tutores generales o del juez en subsidio podrán hacerlo. La prohibición se hace extensiva al cónyuge del tutor o curador, a sus ascendientes, descendientes, etc.



c.4) Incapacidad de los mandatarios, síndicos y albaceas. El artículo 1800 del CC prescribe: “Los mandatarios, los síndicos de los concursos y los albaceas están sujetos, en cuanto a la compra de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud del encargo, a lo dispuesto en el artículo 2144”.

El artículo 2144 dispone que: “No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con la aprobación expresa del mandante”. Las prohibiciones impuestas al mandatario no son absolutas o irremediables; le está permitido obrar del modo prohibido cuando cuente con la autorización expresa del mandante.

Los síndicos no pueden comprar para sí los bienes que, en su carácter de tales, deben vender para hacer pago a los acreedores.

No podrá el albacea, ni las personas ligadas a él, comprar bienes muebles de la sucesión sino con la anuencia de los otros albaceas ni inhabilitados o del juez en subsidio; y los bienes inmuebles en ningún caso.

2.8 Modalidades del Contrato de Compraventa.

2.8.1 Generalidades.

El artículo 1807 dice: **“La venta puede ser pura y simple o bajo condición suspensiva o resolutoria. Puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio. Puede tener por objeto dos o más cosas alternativas. Bajo todos estos respectos se rige por las reglas generales de los contratos en lo que no fueran modificadas por las de este título”**. Pero existen además ciertas modalidades especiales del contrato de compraventa que es menester estudiar y que, como es natural, imprimen al contrato una particular manera de ser.

2.8.2 Venta al peso, cuenta o medida.

La venta será al peso, cuenta o medida cada vez que sea menester pesar, contar o medir para determinar la cosa o el precio. Es necesario formular algunas distinciones:

Se venden ciertas cosas determinadas pero para establecer su precio total es menester pesarlas, contarlas o medirlas. La venta se encuentra perfecta: las partes han convenido en la cosa y en la manera de fijar el precio que consistirá en pesar, contar o medir las cosas vendidas. El inciso primero del artículo 1821 dispone: “Si se vende una cosa de las que suelen venderse a peso, cuenta o medida, pero señalada de modo que no pueda confundirse con otra porción de la misma cosa, como todo el trigo contenido en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora pertenecerá al comprador, aunque dicha cosa no se haya pesado, contado ni medido, con tal que se haya ajustado el precio”.

Se vende una cosa que es preciso contar, pesar o medir para determinarla. La venta se encuentra igualmente perfecta, pero los riesgos serán de cargo del comprador desde que las cosas hayan sido contadas, pesadas o medidas. El inciso segundo del artículo 1821 dispone: “Si de las cosas que suelen venderse a peso, cuenta o medida, sólo se vende una parte indeterminada, como diez fanegas de trigo de las contenidas en cierto granero, la pérdida, deterioro o mejora no pertenecerá al comprador sino después de haberse ajustado el precio y haberse pesado, contado o medido dicha parte”.

La operación de peso, cuenta o medida determina solamente de cargo de quien son los riesgos; pero el contrato se encuentra perfecto. Ello lo demuestra el artículo 1822 del CC que dispone: “Si avenidos vendedor y comprador en el precio, señalaren día para el peso, cuenta o medida, y el uno o el otro no comparecieren en él, será éste obligado a resarcir al otro los perjuicios que de su negligencia resultaren; y el vendedor o comprador que no faltó a la cita podrá, si le conviniera, desistir del contrato”.

2.8.3 Venta a prueba o al gusto.

El artículo 1823 del CC dispone: “Si se estipula que se vende a prueba, se entenderá no haber contrato mientras el comprador no declara que le agrada la cosa de que se trata, y la pérdida, deterioro o mejora pertenece, entre tanto, al vendedor. Sin necesidad de estipulación expresa se entiende hacerse a prueba la venta de todas las cosas que se acostumbran vender de ese modo”. Por lo tanto, la venta será a prueba o a gusto, primero, cuando expresamente lo convinieren las partes; y, segundo, cuando las cosas vendidas son de aquellas que se acostumbre vender de ese modo, aunque no medie estipulación expresa. El comprador puede renunciar a la facultad de gustar las cosas.

2.8.4 Otras modalidades del contrato de compraventa.

La venta puede ser al ensayo, entendiéndose por tal aquella en que el comprador se reserva expresamente la facultad de probar la cosa o ensayarla para verificar si reúne las condiciones requeridas.

La venta puede ser hecha sobre muestras, cuando la cosa comprada se determina con arreglo a una muestra o modelo que el comprador suministra al vendedor, a fin de que aquella reúna las cualidades de dicha muestra o modelo.

2.9 Efectos del Contrato de Compraventa.

Son los derechos y obligaciones que genera para las partes contratantes. Como el contrato es bilateral, ambas partes contraen obligaciones recíprocas. La definición del artículo 1793 del CC enuncia cuales son las obligaciones fundamentales de las partes: dar, el vendedor, la cosa y pagar, el comprador, el precio. Tales son las obligaciones de la esencia del contrato, sin ellas no hay contrato o existe uno diverso. Sin embargo, sin necesidad de estipulación expresa, las partes contraen otras obligaciones; por ejemplo, el vendedor está obligado al saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios. Dichas obligaciones son de la naturaleza del contrato; pueden las partes abolirlas, sin que pierda su peculiar fisonomía, pero para ello será menester una cláusula especial. Por medio de un convenio expreso las partes pueden imponerse de toda clase de obligaciones accidentales; así, el comprador podrá obligarse a levantar determinadas construcciones en el predio que compra, por ejemplo.

2.9.1 Obligaciones del vendedor.

El artículo 1824 del CC señala: “Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida”.

a) Obligación de entregar la cosa vendida.

a.1) Alcance de la obligación del vendedor.



¿Se obliga el vendedor a hacer dueño al comprador de la cosa? ¿Se obliga solamente a procurarle una posesión pacífica y útil?

El artículo 1815 proclama la validez de la venta de cosa ajena al decir que, vendida la cosa ajena, el vendedor cumplirá su obligación entregándola, poniéndola a disposición del comprador para que la goce útil y pacíficamente. El comprador no adquirirá el dominio por la sencilla razón de que el vendedor no era dueño. Por consiguiente, carece el comprador del derecho para pedir la resolución del contrato, pretextando que el vendedor no le ha hecho dueño de la cosa. La acción resolutoria carece, en este caso, de un objetivo práctico pues por su intermedio el comprador perseguiría la abolición del contrato y la restitución de lo que hubiere pagado. Este resultado se obtiene por la acción de saneamiento de la evicción.

En resumen, en nuestro derecho se sigue la tradición romana por la cual el vendedor se obliga a proporcionar al comprador la posesión legal y material de la cosa. La transferencia de dominio se opera como consecuencia de que el vendedor debe dar al comprador la posesión, haciéndole tradición de la cosa vendida. La adquisición del dominio se producirá, consecuencialmente, a condición de que el vendedor sea dueño.

a.2) Forma de la entrega.

Se efectúa de acuerdo con las disposiciones que rigen la tradición. Será menester, por tanto, distinguir si se trata de bienes muebles o inmuebles. La tradición de los bienes muebles se verifica significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando la transferencia por alguna de las maneras que señala el artículo 684 del CC.

La tradición de los bienes muebles por anticipación, como las maderas y los frutos de los árboles, se verifica en el momento de la separación del inmueble. La tradición de los bienes raíces, en general, se efectúa por la inscripción del contrato de compraventa en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces. La regla anterior, relativa a los inmuebles tiene las siguientes excepciones: primero, la tradición del derecho de servidumbre se verifica por escritura pública en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo; y, segundo, la tradición de las minas debe hacerse por la inscripción en el Registro de Propiedades del Conservador de Minas.

a.3) Obligación de entregar materialmente la cosa.

La cosa vendida debe ser puesta materialmente a disposición del comprador; no se entiende cumplida la obligación del vendedor por el hecho de inscribirse el título de inmueble en el registro del Conservador, aunque mediante la inscripción adquiera legalmente el comprador la posesión de la cosa. La posesión legal de la cosa, si no va aparejada de su tenencia material, no brinda al comprador las ventajas que persigue el contrato. La falta de entrega real o material autoriza al comprador para reclamarla o para pedir la resolución del contrato de compraventa.

a.4) Época en que debe efectuarse la entrega.

Debe efectuarse en la época estipulada; a falta de estipulación la entrega es exigible inmediatamente de celebrado el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1826 del CC. La época de la entrega que no es el resultado de una expresa estipulación, puede resultar de las circunstancias del contrato. El plazo de entrega, en este caso, es tácito.

a.5) Derecho de retención del vendedor.

En primer término, no está obligado el vendedor a entregar la cosa cuando el comprador no ha pagado o no está dispuesto a pagar el precio, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1826 del CC que señala: “Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagar a plazo”. Para que el vendedor goce de este derecho legal de retención es menester: primero, que la cosa no haya sido entregada; segundo, que el comprador no haya pagado el precio; y, tercero, que no se haya fijado plazo para el pago.

Aunque se haya convenido un plazo para el pago del precio, puede el vendedor retener la cosa cuando se vea en peligro de perderlo como consecuencia de una disminución considerable de la fortuna del comprador. El inciso cuarto del artículo 1826 del CC señala: “Pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago”. Cesa esta facultad del vendedor cuando el comprador lo cauciona de alguna manera eficaz.

a.6) Lugar de la entrega.

La entrega pues, en primer término, debe hacerse en el lugar convenido. En defecto de estipulación, y si la cosa vendida es una especie o cuerpo cierto, la entrega se hará en el lugar en que se encontraba al tiempo del contrato; si se trata de cosas genéricas, deben entregarse en el domicilio del deudor al tiempo de la venta.

a.7) Gastos de la entrega.

Conforme al artículo 1571, son de cargo del deudor, por lo tanto, serán de cargo del vendedor los que demande la entrega en el lugar debido. En cambio, incumbirán al comprador los gastos en que sea menester incurrir para transportar la cosa ya entregada.

a.8) Qué comprende la entrega.

Debe hacerse al tenor de la obligación y el acreedor no está obligado a recibir cosa diversa de la que se le debe, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida, conforme al artículo 1569 del CC. La regla general está contenida en el artículo 1828 que señala: “El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato”. La cosa vendida debe ser entregada con sus accesorios y frutos.

a.9) Frutos de la cosa vendida.

El artículo 1816 prescribe: “Los frutos naturales, pendientes al tiempo de la venta, y todos los frutos, tanto naturales como civiles, que después produzca la cosa, pertenecerán al comprador, a menos que se haya estipulado entregar la cosa al cabo de cierto tiempo o en el evento de cierta condición; pues en estos casos no pertenecerán los frutos al comprador, sino vencido el plazo, o cumplida la condición. Todo lo dicho en este artículo puede ser modificado por estipulaciones expresas de los contratantes”.

Pertenecen al comprador, pues, los frutos naturales pendientes al momento del contrato, esto es, los que se encuentren aún adheridos a la cosa fructuaria. Igualmente pertenecen al comprador los frutos, tanto naturales como civiles, que la cosa vendida produzca después de celebrado el contrato, salvo cuando: primero, las partes han señalado un plazo para la entrega porque los frutos pertenecen al comprador en tal fruto hasta el vencimiento del plazo; segundo, cuando la cosa debe entregarse cumplida una condición porque los frutos pertenecerán igualmente al vendedor hasta que la condición prevista se cumpla; y, tercero, cuando las partes han estipulado cláusulas especiales.

a.10) Accesorios de la cosa vendida.

El artículo 1830 dispone: “En la venta de una finca se comprenden naturalmente todos los accesorios que según los artículos 570 y siguientes se reputan muebles”. La regla es aplicable también a la venta de bienes muebles.

a.11) Riesgos de la cosa vendida.

De acuerdo con la regla general del artículo 1550, el riesgo de la especie o cuerpo cierto cuya entrega se debe es de cargo del acreedor, al señalar: “La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el momento en que se perfecciona el contrato, aunque no se haya entregado la cosa”.

Si la cosa se ha deteriorado o perecido parcialmente, debe el comprador soportar igualmente el deterioro porque habrá de recibirla en el estado en que se encuentre. Como justa compensación pertenecen al comprador, sin costo alguno, las mejoras de la cosa y, como se dijo, los frutos. La regla es aplicable a la venta de cosas genéricas que se hacen en bloque que deben ser pesadas, contadas o medidas para determinar el precio total.

La regla tiene las siguientes excepciones:

- i. En la compraventa subordinada a una condición suspensiva la pérdida fortuita de la cosa debe soportarla el vendedor, cuando ésta sobreviene pendiente la condición.
- ii. En la venta a peso, cuenta o medida en las que las operaciones de contar, pesar o medir tienen por objeto determinar la cosa vendida, la pérdida, deterioro o mejora pertenecen al comprador sólo desde que tales operaciones se verifiquen.
- iii. En la compraventa al gusto, los riesgos son del comprador desde que ha expresado que la cosa le agrada y, mientras tanto, corresponden al vendedor.

a.12) La entrega en la venta de predios rústicos.

De acuerdo al artículo 1831 del CC, la venta puede verificarse tomando en consideración la cabida del predio o desentendiéndose de ella. Se comprende que si se vende un predio en relación a su cabida o superficie, pueden surgir dificultades con motivo de que la cabida real sea mayor o menor que la expresada en el contrato y que tales dificultades no puedan plantearse si la venta se hace sin tomar en consideración la superficie o cabida del predio.

El inciso segundo del artículo 1831 expresa: “Se vende con relación a la cabida siempre que ésta se exprese de cualquier modo en el contrato, y en todo los demás casos se entenderá venderse el predio o predios como un cuerpo cierto”. En líneas generales, la venta se entiende hecha en relación a la cabida siempre que: primero, la cabida se exprese en el contrato; segundo, el precio se fije con relación a ella; y, tercero, cuando las partes no renuncien a las acciones resultantes de que la cabida real sea diversa de la que reza el contrato. El inciso tercero del artículo 1831 expresa que: “Es indiferente que se fije directamente un precio total o que éste se deduzca de la cabida o número de medidas que se expresa y del precio de cada medida”. En el cuarto inciso añade: “Es asimismo indiferente que se exprese una cabida total o las cabidas de las varias porciones de diferentes calidades y precios que contenga el predio, con tal que de estos datos resulte el precio total y la cabida total”.

En cambio, un predio se entiende vendido como cuerpo cierto cada vez que: primero, la cabida no se exprese en el contrato; y, segundo, las partes mencionen la cabida pero expresa o tácitamente declaren que es un dato puramente ilustrativo y que no hacen cuestión por los defectos de ella. Comúnmente se expresa en el contrato que la venta se hace ad corpus.

➡ **Efectos de la venta con relación a la cabida.**

Si la cabida real, esto es, la superficie que realmente mide el predio, es mayor que la expresada en el contrato, podrá ser mucho o poco mayor, y, naturalmente, las consecuencias serán diferentes. Se considera que la cabida es mucho mayor cuando el precio del sobrante excede de la décima parte del precio de la verdadera cabida. El inciso primero del artículo 1832 establece: “Si se vende el predio con relación a su cabida y la cabida real fuere mayor que la cabida declarada, deberá el comprador aumentar proporcionalmente el precio”. El mismo artículo previene que la regla establecida en su inciso primero no rige en caso que el precio de la cabida que sobre alcance a más de una décima parte del precio de la cabida real; pues en ese caso podrá el comprador a su arbitrio o aumentar proporcionalmente el precio o desistir del contrato, y si desiste, se le resarcirán los perjuicios según las reglas generales.

Si la cabida reales menor que la declarada en el contrato, del mismo modo, podrá ser poco o mucho mayor. El inciso segundo del artículo 1832 señala: “Si la cabida real es menor que la cabida declarada, deberá el vendedor completarla; y si esto no fuera posible o no se le exigiere, deberá sufrir una disminución proporcional del precio”. El mismo artículo concluye: “Si el precio de la cabida que falte alcanza a más de una décima parte del precio de la cabida completa, podrá el comprador, a su arbitrio, o aceptar la disminución del precio o desistir del contrato en los términos del precedente inciso”.

➡ **Efectos de la venta de un predio como cuerpo cierto.**

No plantea ningún problema de cabida; justamente para zanjar toda dificultad al respecto los contratantes realizan la venta ad corpus. El inciso primero del artículo 1833 establece que: “No habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio sea cual fuere la cabida del predio”. El inciso segundo del mismo artículo señala que: “Si se vende con señalamiento de linderos estará obligado el vendedor a entregar todo lo comprendido en ellos; y si no pudiere o no se le exigiere, se observará lo prevenido en el inciso segundo del artículo precedente”. Por lo tanto, será menester averiguar si la parte que falte dentro de los linderos excede o no de la décima parte de lo que en ellos se comprende. Si no excede, el comprador podrá reclamarla o pedir la rebaja del precio; si excediere, podrá pedir la rebaja proporcional del precio o desistir del contrato con indemnización de perjuicios.

➡ **Aplicación de los artículos 1832 y 1833 a cualquier conjunto de mercaderías.** El artículo 1835 dispone que las reglas de los artículos 1832 y 1833 se aplican a cualquier todo o conjunto de efectos o mercaderías.

➡ **Prescripción.** El artículo 1834 señala que las acciones dadas en los dos artículos precedentes expiran al cabo de un año, contado desde la entrega. Las acciones de que se trata son:

- i. La acción del vendedor para exigir un aumento del precio cuando la cabida real es mayor que la declarada.

- ii. La acción del comprador para pedir la rebaja del precio cuando la cabida declarada es menor que la cabida real.
- iii. La acción del comprador para exigir la entrega de la cabida que falta en el mismo caso.
- iv. La acción del comprador para desistir del contrato.

➡ **Acción rescisoria por lesión enorme.** Las acciones especiales otorgadas al comprador y al vendedor no les privan de la acción rescisoria por lesión enorme cuando las diferencias de la cabida sean de tal importancia que constituyan una lesión de esta índole., conforme a los dispuesto en el artículo 1836 del CC.

a.13) Consecuencias de la falta de entrega de la cosa vendida.

Produce las consecuencias que prevé el artículo 1489, o sea, el derecho alternativo para el comprador de pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, con indemnización de perjuicios. El artículo 1826 reproduce la regla general al señalar: “Si el vendedor por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador, a su arbitrio, perseverar en el contrato o desistirse de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas generales”. Como condiciones para que el comprador pueda optar por el ejercicio de estos derechos se señalan: primero, es preciso que el vendedor retarde la entrega por su hecho o culpa o, más exactamente, que se encuentre en mora de cumplir; y, segundo, es menester además que el comprador haya pagado o esté pronto a pagar el precio o haya estipulado plazo para pagarlo.

b) Obligación de saneamiento.

El artículo 1824 señala como segunda obligación del vendedor el saneamiento de la cosa vendida. No basta que el vendedor entregue la cosa vendida; es preciso que la entregue en condiciones tales que el comprador pueda gozar de ella tranquila y útilmente. No logrará el comprador una posesión tranquila o pacífica de la cosa vendida cuando se vea turbado en dicha posesión a consecuencia de los derechos que terceros hagan valer con relación a ella. No obtendrá una posesión útil si la cosa adolece de defectos que la hacen inadecuada para el objeto que tuvo en vista al comprarla.

En uno y otro caso el comprador quedaría defraudado en sus justas expectativas si no dispusiera de recursos para exigir del vendedor que le ampare en la posesión y subsane los vicios y defectos de la cosa. Este recurso es la acción de saneamiento. En virtud del contrato de compraventa, en efecto, el vendedor se obliga a garantizar al comprador la posesión tranquila y útil de la cosa que vende. Se obliga, en otros términos, al saneamiento. El artículo 1837 del CC señala este doble objetivo de la acción de saneamiento: “La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios”.

b.1) Caracteres de la obligación de saneamiento.

- i. La obligación de saneamiento es de la naturaleza del contrato de compraventa; le pertenece sin necesidad de estipulación, pero puede ser modificada y, aun abolida, sin que por ello el contrato deje de existir o degenerar en otro diverso.
- ii. La obligación de saneamiento tiene un carácter eventual; se hace exigible a condición de que ocurran ciertos hechos que pueden suceder o no.

c) Saneamiento de la evicción.

c.1) Objeto de la obligación de saneamiento de la evicción.

El objeto de la obligación de sanear la evicción está señalado en el artículo 1831 que expresa que es: "Amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida". Se traduce en su defensa cada vez que sea víctima de la agresión de terceros que pretendan derechos sobre la cosa, que embaracen su goce y turben su posesión.

Por lo tanto, la obligación de saneamiento de la evicción persigue dos fines o se desarrolla en dos etapas:

- i. Defender al comprador contra los terceros que reclamen derechos sobre la cosa.
- ii. Indemnizar al comprador si la evicción, no obstante, se produce.

c.2) Naturaleza de la obligación de saneamiento.

Es una obligación de hacer. El hecho debido consiste en asumir la defensa del comprador. En cuanto la obligación de saneamiento se convierte en la de indemnizar al comprador evicto, es una obligación de dar. El artículo 1840 señala: "La acción de saneamiento es indivisible. Puede, por consiguiente, intentarse in solidum contra cualquiera de los herederos del vendedor. Pero desde que a la obligación de amparar al comprador en la posesión, le sucede la de indemnizarle en dinero, se divide la acción; y cada heredero es responsable solamente a prorrata de su cuota hereditaria. La misma regla se aplica a los vendedores que por un solo acto de venta hayan enajenado la cosa".

c.3) Requisitos para que sea exigible la obligación de saneamiento.

Es preciso que el comprador se vea expuesto a sufrir evicción de la cosa. No basta, sin embargo, que el comprador sea turbado en el dominio y posesión de la cosa; es necesario que el comprador haga saber al vendedor la turbación de que es víctima para que acuda en su defensa. En otras palabras, es menester que el vendedor sea citado de evicción.

Por lo tanto, para que el vendedor esté obligado al saneamiento se requiere:

- i. Que el comprador se vea expuesto a sufrir evicción de la cosa comprada.
- ii. Que el vendedor sea citado de evicción.

c.4) Concepto de evicción.

El artículo 1838 dispone: "Hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial". La privación que sufra el comprador debe provenir de

una causa anterior a la celebración del contrato de compraventa. Señala el artículo 1839: “El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario”.

c.5) Elementos de la evicción.

- ➡ **Privación total o parcial.** La evicción puede ser, por lo tanto, total o parcial. Cualquiera que sea la magnitud de la turbación que sufra el comprador tiene derecho al saneamiento.
- ➡ **Necesidad de una sentencia judicial.** Supone un proceso y una sentencia que le despoja total o parcialmente de la cosa. Los reclamos extrajudiciales que terceros formulen al comprador, pretendiendo derechos sobre la cosa, no hacen exigible la obligación de saneamiento. El abandono voluntario que haga el comprador al tercero, de todo o parte de la cosa, no obliga al vendedor al saneamiento. Sin embargo, puede darse el caso de que se produzca la evicción sin una sentencia judicial, como lo señala el artículo 1856, que recoge el caso del vendedor que citado en juicio acepta la demanda y se allana a la evicción y el comprador reconociendo la justicia de las pretensiones del tercero restituye la cosa. Solamente está obligado el vendedor al saneamiento de las turbaciones de derecho de que el comprador sea víctima, esto es, aquellos que provengan de derechos que terceros pretendan tener sobre la cosa. No debe el vendedor ninguna garantía en razón de turbaciones de hecho que sufra el comprador, aunque importen despojo.
- ➡ **La evicción debe tener una causa anterior a la venta.** El artículo 1839 señala que: “El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo cuando se haya estipulado lo contrario”. Las evicciones motivadas por causas posteriores a la venta las soporta exclusivamente el comprador. El vendedor es, por completo, extraño a la evicción.

c.6) Citación de evicción.

El artículo 1839 del CC dispone que: “El comprador a quien se demanda la cosa vendida, por causa anterior a la venta, deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderla. Si el comprador omitiere citarle y fuere evicta la cosa, el vendedor no será obligado al saneamiento”.

c.7) Forma y oportunidad de citación.

La citación debe solicitarse por el comprador para que el juez la ordene y deberán acompañarse antecedentes que hagan aceptable la solicitud. La citación debe hacerse antes de la contestación de la demanda. Decretada la citación, el juicio se paraliza por el plazo de diez días si el citado reside en el departamento en que se sigue el juicio, en caso contrario deberá agregarse la tabla de emplazamiento. Vencidos estos plazos sin que el demandado haya hecho practicar la citación, podrá pedir el demandante que se declare caducado el derecho de aquel para exigirla o que le autorice para llevarla a efectos a costa del demandado. Practicada la citación, las personas citadas de evicción dispondrán del término de emplazamiento que corresponda para comparecer en juicio, suspendiéndose por mientras el procedimiento.

La citación de evicción procede en toda clase de juicios y no solamente en el juicio ordinario.

c.8) A quién puede citarse de evicción.

El demandado puede citar de evicción a su vendedor pero también puede citar a los antecesores del vendedor. El artículo 1841 dispone: “Aquel a quien se demanda una cosa comprada podrá intentar contra el tercero de quien su vendedor la hubiere adquirido, la acción de saneamiento que contra dicho tercero competiría al vendedor, si éste hubiese permanecido en posesión de la cosa”. El comprador adquiere sobre la cosa todos los derechos de sus antecesores y, entre ellos, la acción de saneamiento de cada comprador contra su vendedor. El último comprador reúne en sus manos todas estas acciones.

c.9) Desarrollo de la obligación de saneamiento del vendedor citado de evicción.

El vendedor citado de evicción debe defender al comprador y apersonarse en juicio con tal objeto. Violará su obligación si no comparece.

Si el vendedor no comparece vencido el término de emplazamiento de que dispone para comparecer continuará sin más trámite el procedimiento. Su falta de comparecencia acarrea como lógica sanción la responsabilidad del vendedor por la evicción que se produzca. Pero esta regla tiene una justa excepción: el comprador debe hacer lo que esté de su parte para impedir la evicción; si deja de oponer alguna de aquellas excepciones que sólo a él competían y se produce como consecuencia la evicción, no será responsable el vendedor, pese a que fue citado y no compareció al juicio. Tocarà al vendedor, para eximirse de responsabilidad, acreditar que el comprador disponía de una excepción suya que no opuso y que, por esta omisión, la evicción se produjo.

Si el vendedor comparece, se sigue el juicio con él. La defensa del comprador, en otros términos, se traduce en que el vendedor asume, en lo sucesivo, el papel de demandado en el litigio. El comprador, sin embargo, podrá seguir actuando como parte coadyuvante. Aún más, el comprador deberá intervenir en el pleito si dispone de excepciones que no puede oponer el vendedor, bajo pena de no quedar éste responsable si, a causa de la omisión del comprador, la cosa fuere evicta.

c.10) Actitudes que puede adoptar el vendedor que comparece al juicio.

Puede percatarse de la justicia de la demanda, de la esterilidad de sus esfuerzos y allanarse a la evicción. En tal caso, el comprador puede seguir por su cuenta el juicio. Si sobreviene la evicción, el vendedor deberá indemnizarle; pero no se comprenden en la indemnización las costas del pleito, ni los frutos percibidos durante la secuela del litigio pagados al demandante.

El vendedor, asimismo, podrá considerar injusta la agresión de que se ha hecho víctima al comprador y asumir su defensa en el litigio.

c.11) La obligación de indemnizar al comprador evicto.

Si la sentencia es adversa para el tercero y favorable al comprador, la defensa del vendedor habrá sido exitosa y la evicción no habrá llegado a producirse. El artículo 1855 del CC señala: “Si la sentencia negare la evicción, el vendedor no será obligado a la indemnización de los perjuicios que la demanda hubiere causado al comprador, sino en cuanto la demanda fuere imputable al hecho o culpa del vendedor”.

Si, por el contrario, la sentencia es adversa para el comprador y favorable para el tercero, se producirá la evicción. A la obligación de defenderle le sucede la de indemnizarle de la evicción, conforme al artículo 1840 del CC. Las indemnizaciones que debe el vendedor al comprador son diversas según que la evicción sea total o parcial.

c.12) Indemnización en caso de evicción total.

El artículo 1847 señala que la indemnización comprende:

- ➡ **Restitución del precio.** Conforme al primer número del artículo 1847, debe el vendedor restituir el precio aunque la cosa haya disminuido de valor. La regla anterior tiene una justificada excepción: si el menor valor de la cosa proviene de deterioros de que el comprador se haya aprovechado, debe hacerse la correspondiente rebaja de precio conforme al artículo 1848 del CC.
- ➡ **Pago de las costas del contrato.** El segundo número del artículo 1847 señala que la indemnización comprende las costas legales del contrato de venta que hubieren sido satisfechas por el comprador.
- ➡ **Pago de frutos.** El tercer número del artículo 1847 dice que el vendedor debe indemnizar al comprador del valor de los frutos que el comprador hubiere sido obligado a restituir al dueño. La obligación del comprador de restituir los frutos depende de su buena o mala fe y se regula por las reglas de las prestaciones mutuas. No debe el vendedor los frutos posteriores a la fecha en que el vendedor se allanó a la evicción y percibidos durante la secuela del juicio que el comprador se empeñó en seguir adelante, conforme al artículo 1845 del CC.
- ➡ **Pago de las costas del juicio.** Conforme al cuarto número del artículo 1847 del CC la indemnización comprende también las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia y por efecto de la demanda.
- ➡ **Pago del aumento de valor de la cosa.** La indemnización comprende, conforme al quinto número del artículo 1847 del CC, el aumento de valor que la cosa evicta haya tomado en poder del comprador, aun por causas naturales o por el mero transcurso del tiempo. El aumento de valor de las cosas puede provenir de: primero, causas naturales o del simple transcurso del tiempo, y, segundo, de mejoras introducidas por el comprador.

Para determinar en qué términos debe pagar el vendedor los aumentos de valor de la cosa que provienen de causas naturales o del transcurso del tiempo es preciso distinguir si ha tenido buena o mala fe. Si el vendedor está de buena fe el aumento de valor debido a causas naturales o al tiempo no se abonará en lo que excediere a la cuarta parte del precio de la venta, conforme al artículo 1850 del CC. Si el vendedor está de mala fe, debe abonar el total del aumento de valor de la cosa.

En cuanto a los aumentos de valor que provengan de mejoras, es preciso distinguir nuevamente si el vendedor está de buena o mala fe. Si el vendedor está de buena fe debe

abonar el aumento de valor resultante de las mejoras necesarias y útiles que hizo el comprador y que no le hayan sido abonadas por el que hizo la evicción. El vendedor de mala fe debe rembolsar aún las mejoras voluptuarias, conforme al artículo 1849 del CC.

c.13) Evicción parcial.

Es aquella en que se priva al comprador solamente de parte de la cosa vendida.

Para el caso de que la evicción sea de considerable magnitud, el inciso cuarto del artículo 1852 dispone: “Si la evicción no recae sobre toda la cosa vendida y la parte evicta es tal, que sea de presumir que no se habría comprado la cosa sin ella, habrá derecho a pedir la rescisión de la venta”. Tiene el comprador el derecho opcional de pedir la rescisión de la venta o el saneamiento de la evicción. Las relaciones entre el comprador y el vendedor, en el caso que el primero opte por pedir la rescisión del contrato, se regulan de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1853 del CC que dispone: “En virtud de esta rescisión, el comprador será obligado a restituir al vendedor la parte no evicta, y para esta restitución será considerado como poseedor de buena fe a menos de prueba en contrario; y el vendedor, además de restituir el precio, abonará el valor de los frutos que el comprador hubiere sido obligado a restituir con la parte evicta y todo otro perjuicio que de la evicción resultare al comprador”.

Para el caso de que la evicción parcial no sea de tanta magnitud o el comprador no quisiere pedir la rescisión del contrato, el artículo 1854 del CC dispone: “En caso de no ser de tanta importancia la parte evicta, o en el de no pedirse la rescisión de la venta, el comprador tendrá derecho para exigirle saneamiento de la evicción parcial con arreglo a los artículos 1847 y siguientes”. Esta vez el comprador no puede optar entre el saneamiento y la rescisión de la venta; sólo tiene derecho para pedir el saneamiento de la evicción.

c.14) Extinción de la acción de saneamiento.

Puede extinguirse total o parcialmente. Si la extinción es total, el vendedor queda por completo liberado; si es parcial, su responsabilidad se limita a ciertas prestaciones únicamente. La acción de saneamiento por evicción se extingue por la renuncia, por la prescripción, y en los casos especiales previstos por la ley.

➡ **Renuncia de la acción de saneamiento.** La obligación de saneamiento es de la naturaleza del contrato de compraventa. Las partes pueden, por lo tanto, modificarla y hasta abolirla. El artículo 1842 del CC expresa: “Es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del saneamiento de evicción, siempre que en ese pacto haya habido mala fe de parte suya”. Hay mala fe cuando el vendedor conocía la causa de la evicción y, sin darla a conocer al comprador, estipuló su irresponsabilidad.

A contrario sensu, es válido el pacto y la consiguiente renuncia, si el vendedor estaba de buena fe. Pero la renuncia no produce sino efectos limitados, puesto que no exonera por completo al vendedor de la acción de saneamiento; la extinción es sólo parcial porque el vendedor debe siempre restituir el precio recibido, conforme al artículo 1852 del CC que señala: “La estipulación que exime al vendedor de la obligación de sanear la evicción no le exime de la obligación de restituir el precio recibido. Y estará obligado a restituir el precio

íntegro, aunque se haya deteriorado la cosa o disminuido de cualquier modo su valor, aun por hecho o negligencia del comprador, salvo en cuanto éste haya sacado provecho del deterioro”. Solamente en dos casos la renuncia extingue por completo la obligación del vendedor:

- i. Si el que compró lo hizo a sabiendas de ser ajena la cosa.
- ii. Si expresamente tomó sobre sí el peligro de la evicción, especificándolo.

➡ **Prescripción de la acción de saneamiento.** En cuanto se traduce en defensa al comprador, es imprescriptible. En cualquier tiempo en que el comprador sea demandado por terceros que aleguen derechos sobre la cosa vendida, puede citar de evicción al vendedor para que le defienda. La obligación sólo se hace exigible cuando el comprador es demandado.

En cambio, es prescriptible la obligación de saneamiento en cuanto se convierte en la de indemnizar al comprador una vez producida la evicción. El artículo 1856 establece: “La acción de saneamiento por evicción prescribe en cuatro años; más por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según las reglas generales”. En consecuencia, prescriben en cinco años la acción para reclamar la restitución del precio y en cuatro años las acciones encaminadas a reclamar todas las restantes indemnizaciones. El artículo 1856 concluye: “Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción o si ésta no hubiere llegado a pronunciarse, desde la restitución de la cosa”.

➡ **Casos en que se extingue,** por disposición de la ley, la obligación de saneamiento de la evicción.

Se extingue la obligación parcialmente en los siguientes casos:

- i. En las ventas forzadas la indemnización se limita a la devolución del precio conforme al artículo 1851 del CC.
- ii. En caso de que el vendedor se allane al saneamiento y el comprador prosiga por sí sólo el juicio, la indemnización no comprende las costas del pleito en que hubiere incurrido defendiéndose, ni los frutos percibidos durante dicha defensa y satisfechos al dueño, conforme con lo dispuesto en el artículo 1845 del CC.

La obligación de saneamiento se extingue por completo:

- i. En caso de que citado a evicción el vendedor no comparezca, pero el comprador no opone en el juicio alguna excepción suya y por ello fuere evicta la cosa, conforme al artículo 1843.
- ii. Si el comprador y el que demanda la cosa como suya se someten al juicio de árbitros sin consentimiento del vendedor, y los árbitros fallaren contra el comprador, conforme lo dispuesto en el primer número del artículo 1846.
- iii. Si el comprador perdió la posesión por su culpa y de ello se siguió la evicción, conforme lo dispuesto en el segundo número del artículo 1846.

d) Saneamiento de los vicios redhibitorios.

d.1) Objeto de la obligación de saneamiento de los vicios redhibitorios.

La obligación de saneamiento pone al vendedor en la necesidad de amparar al comprador en el dominio y posesión de la cosa y de responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios, conforme al artículo 1837 del CC. Debe el vendedor procurar al comprador la posesión útil de la cosa vendida y entregarla, por lo tanto, en estado de servir para los fines que determinaron su adquisición.

El artículo 1857 dispone: “Se llama acción redhibitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados redhibitorios”

d.2) Concepto de los vicios redhibitorios.

El CC no los ha definido pero el artículo 1858 ha señalado sus características señalando que los defectos de la cosa deben ser contemporáneos a la venta, graves y ocultos. No obstante, las partes pueden otorgar el carácter de redhibitorios a vicios que no reúnan tales requisitos, conforme a lo señalado en el artículo 1863 del CC.

- ➡ El vicio debe ser contemporáneo de la venta. El primer número del artículo 1858 señala que el vicio, para ser redhibitorio, debe “Haber existido al tiempo de la venta”. Bastará que el vicio exista en germen al momento de la venta, aunque posteriormente se manifieste en toda su gravedad.
- ➡ **El vicio debe ser grave.** Señala el segundo número del artículo 1858 que deben “Ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menor precio”. La gravedad del vicio puede resultar de tres circunstancias: primero, que la cosa no sirva para su uso natural; segundo, que sirva para este uso, pero imperfectamente; y, tercero, que, conocidos estos hechos por el comprador, sea presumible que no hubiera comprado o hubiera pagado un precio mucho menor.
- ➡ **El vicio debe ser oculto.** Esto es, ignorados por el comprador. Si el comprador conoció la existencia de los vicios se presume que no les atribuyó importancia, ajustó el precio teniéndolos en cuenta e, implícitamente, renunció a la garantía. Para que los vicios se consideren redhibitorios, conforme al tercer número del artículo 1858, es menester “No haberlos manifestado el vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio”.

En resumen, el vicio no es oculto: primero, cuando el vendedor lo dio a conocer al comprador; segundo, cuando el comprador lo ha ignorado por grave negligencia suya; y, tercero, cuando el comprador experto pudo fácilmente conocerlo en razón de su profesión u oficio.

d.3) Efectos de los vicios redhibitorios.

Autorizan al comprador para ejercitar la acción redhibitoria para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio, conforme al artículo 1857 del CC. En verdad se trata de dos acciones diversas. La acción propiamente redhibitoria que no es sino una acción resolutoria del

contrato de compraventa; y la acción denominada aestimatoria o quanti minoris para pedir la restitución de una parte del precio, proporcional a la disminución del valor resultante del vicio de la cosa.

El artículo 1860 del CC reitera que el comprador dispone de ambas acciones y previene que puede elegir una u otra a su arbitrio al señalar: "Los vicios redhibitorios dan derecho al comprador para exigir o la rescisión de la venta o la rebaja del precio, según mejor le pareciere".

➡ **Casos de excepción.** El artículo 1860 señala la regla general, pero en casos excepcionales, el comprador puede ejercer solamente la acción de rebaja del precio o pedir, además, que se le paguen los perjuicios sufridos:

i. Si los vicios no revisten los caracteres de gravedad que señala la ley, solamente tiene el comprador derecho para pedir una rebaja del precio.

ii. Si el vendedor conoció los vicios o debió conocerlos en razón de su profesión u oficio, será obligado, no sólo a la restitución o la rebaja del precio, sino a la indemnización de perjuicios. En otras palabras, en contra del vendedor de mala fe tiene el comprador, además, la acción de perjuicios, conforme lo señalado en el artículo 1861 del CC.

iii. Si la cosa viciosa perece después de perfeccionado el contrato, aunque haya perecido en poder del comprador y por su culpa, no por eso perderá el comprador el derecho que hubiere tenido a la rebaja de precio. Pero si la cosa pereció por un efecto del vicio inherente a ella, podrá el comprador pedir la resolución del contrato o la rebaja del precio con indemnización de perjuicios en contra del vendedor de mala fe, conforme lo dispuesto en el artículo 1862 del CC.

➡ **Caso en que el objeto vendido se compone de varias cosas.** Conforme al artículo 1864 del CC en tal caso sólo habrá lugar a la acción redhibitoria por la cosa viciosa y no por el conjunto. Pero la regla no es aplicable si aparece que no se habría comprado el conjunto sin esa cosa.

d.4) Extinción de la obligación de saneamiento por vicios redhibitorios.

Se extingue por renuncia y por la prescripción. También cesa esta obligación en las ventas forzadas.

➡ **Renuncia del saneamiento de los vicios redhibitorios.** El saneamiento de los vicios redhibitorios es de la naturaleza del contrato de compraventa, por lo que puede suprimirse o renunciarse, sin que por ello el contrato deje de existir o degenerar en otro diverso. La renuncia sólo produce efectos si el vendedor está de buena fe. Se entiende que está de mala fe cuando conocía de la existencia de los vicios y no los dio a conocer al comprador. El artículo 1859 del CC señala: "Si se ha estipulado que el vendedor no estuviese obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará sin embargo obligado a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al comprador".

➡ **Ventas forzadas.** El artículo 1865 del CC dispone: "La acción redhibitoria no tiene lugar en las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia. Pero si el vendedor, no pudiendo o no

debiendo ignorar los vicios de la cosa vendida, no los hubiese declarado a petición del comprador, habrá lugar a la acción redhibitoria y a la indemnización de perjuicios”.

- ➡ **Prescripción de las acciones que originan los vicios redhibitorios.** El artículo 1866 del CC dispone: “La acción redhibitoria durará seis meses respecto de las cosas muebles y un año respecto de los bienes raíces, en todos los casos en que las leyes especiales o estipulaciones de los contratantes no hubieran ampliado o restringido este plazo. El tiempo se contará desde la entrega real”.

El artículo 1869 agrega: “La acción para pedir rebaja del precio, sea en el caso del artículo 1858, o en el del artículo 1868 prescribe en un año para los bienes muebles y en dieciocho meses para los bienes raíces”.

La acción redhibitoria prescribe pues, en seis meses y en un año; la acción quanti minoris en un año y dieciocho meses. Como es mayor el plazo de prescripción de la acción quanti minoris, subsiste estación después de prescrita la acción redhibitoria, como lo señala el artículo 1867.

Es menester tener presente que el plazo de la prescripción se cuenta desde la entrega real de la cosa pues sólo entonces el comprador podrá percatarse de la existencia de los vicios. Asimismo, las partes pueden restringir y aun ampliar el plazo de prescripción de la acción redhibitoria. Por último, la acción de indemnización de perjuicios prescribe según las reglas generales.

La regla que fija en un año el plazo de prescripción de la acción para la rebaja del precio tratándose de bienes muebles tiene la excepción del artículo 1870 del CC que señala: “Si la compra se ha hecho para remitir la cosa a un lugar distante, la acción de rebaja del precio prescribirá en un año, contado desde la entrega al consignatario, con más el término de emplazamiento que corresponda a la distancia”. Se exige como condición que el comprador, en el tiempo intermedio entre la venta y la remesa haya podido ignorar el vicio de la cosa, sin negligencia de su parte.

2.9.2. Obligaciones del comprador.

La compraventa, como contrato unilateral que es, genera también obligaciones para el comprador. La obligación fundamental del comprador es pagar el precio. Pero como lógica contrapartida a la obligación del vendedor de entregar la cosa, tiene igualmente el comprador la obligación de recibirla.

a) Obligación de recibir la cosa comprada.

a.1) En qué consiste esta obligación. Consiste en hacerse cargo de la cosa comprada, tomando posesión de ella. La manera de cumplirse prácticamente esta obligación variará según la naturaleza de la cosa. La recepción de la cosa puede ser simbólica del mismo modo que puede serlo la entrega.

a.2) Mora en recibir la cosa comprada. Dispone artículo 1827 del CC: “Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas

en que se contenga lo vendido y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa y sólo será ya responsable del dolo o de la culpa grave”.

Dos efectos produce, pues, la mora del comprador en recibir la cosa: primero, debe abonar al vendedor los perjuicios que sean consecuencia de la mora; y, segundo, el vendedor queda descargado del cuidado ordinario de la cosa y sólo responde de los estragos que sufra por su culpa lata o dolo.

No excluye el artículo citado los derechos del vendedor para pedir el cumplimiento o la resolución del contrato, con indemnización de perjuicios, los cuales se encuentran expresamente consagrados en el artículo 153 del CCO para el caso que el comprador rehusare recibir, sin justa causa, la cosa comprada.

b) Obligación de pagar el precio.

El artículo 1871 del CC dispone: “La principal obligación del comprador es la de pagar el precio”. Es una obligación de la esencia del contrato de compraventa.

b.1) Lugar y época del pago del precio. El pago debe hacerse en el lugar señalado en la convención y, a falta de estipulación, cuando la obligación es de género, en el domicilio del deudor, conforme a los artículos 1587 y 1588 del CC. Por otra parte, las obligaciones deben cumplirse de inmediato, si las partes no han postergado expresamente su cumplimiento. El artículo 1872 del CC deroga ligeramente estas normas por lo que toca al lugar y época en que se debe pagar el precio: “El precio deberá pagarse en el lugar y tiempo estipulado, o en el lugar y tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario”.

Por lo tanto, si las partes han guardado silencio, las reglas generales sufren derogación, porque el pago no deberá hacerse de inmediato y en el domicilio del deudor, sino que en el momento y lugar de la entrega. Como consecuencia, fijado un plazo para la entrega, el mismo plazo rige, sin necesidad de estipulación para el pago del precio. Convenido el lugar de la entrega, esta convención se hace extensivo al la obligación de pagar el precio, que ha de verificarse en el mismo lugar.

b.2) Derecho del comprador para suspender el pago del precio.

Puede excusarse de pagar el precio en la época convenida o fijada por la ley, en suma, cuando se ve expuesto a perder la cosa. Es lógico que si le amenaza una evicción y no ha pagado el precio, pueda suspender el pago para evitar una inútil repetición de lo pagado y el riesgo consiguiente. El inciso segundo del artículo 1872 establece: “Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa o probare que existe contra ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el precio con autoridad de la justicia, y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio”.

Por consiguiente, dos son las causas que justifican la suspensión por el comprador del pago del precio: primero, que sea turbado en la posesión de la cosa; y, segundo, que pruebe que existe contra la cosa una acción real de que el vendedor no le dio noticia antes de celebrarse el contrato. Pero el comprador no queda facultado, por estas circunstancias, para retener el precio en su poder. Debe ser depositado, en virtud de una autorización judicial; puede el juez autorizar al

comprador para conservarlo él mismo en calidad de depositario. El propósito termina por: primero, la cesión de la turbación; y, segundo, el otorgamiento de una caución que asegure las resultas del juicio.

b.3) Consecuencias de la falta de pago del precio.

Conforme al precepto general del artículo 1489 del CC autoriza al vendedor para pedir la resolución del contrato o su cumplimiento con indemnización de perjuicios. El artículo 1873 repite esta norma general al señalar: “Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios”. No estará en mora el comprador cuando el vendedor no ha entregado o ha estado llano a entregar la cosa.

b.4) Efectos de la resolución del contrato por falta de pago del precio.

Estos efectos, en gran parte, son la aplicación de los principios generales que regulan los efectos de la condición resolutoria cumplida, con algunas importantes modificaciones.

➡ **Efectos entre las partes.** Las partes tienen derecho a que se les restituya al estado anterior a su celebración.

Con tal objeto, el comprador debe al vendedor determinadas prestaciones:

- i. Tiene derecho el vendedor, en primer término, a que se le restituya la cosa.
- ii. El vendedor igualmente tiene derecho a que se le restituyan los frutos que el comprador hubiere percibido mientras tuvo la cosa en su poder. El artículo 1875 del CC establece que el vendedor tiene derecho a que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad, si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada.
- iii. En caso de haberse dado arras, el vendedor tiene derecho para retener las arras o exigir las dobladas, conforme lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1875.
- iv. Tiene el vendedor derecho para que el comprador le indemnice los deterioros que haya experimentado la cosa. Para estos efectos, se considerará al comprador como poseedor de mala fe a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna y sin culpa de su parte, menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado.
- v. En fin, le asiste al vendedor el derecho de demandar la indemnización de los perjuicios que el incumplimiento del contrato le haya ocasionado, conforme lo dispuesto en el artículo 1873 del CC.

Por su parte, el vendedor debe realizar ciertas prestaciones a favor del comprador:

- i. El comprador tiene derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio, conforme al inciso segundo del artículo 1875.
- ii. Tiene igualmente derecho para que se le abonen las mejoras, reputándosele, para estos efectos, como poseedor de mala fe. Sin embargo, el comprador será reputado de buena fe si

probar que su fortuna, sin culpa suya, ha sufrido menoscabos tan considerables que le hicieron imposible cumplirle contrato, conforme lo señalado en el inciso tercero del artículo 1875.

➡ **Efectos respecto de terceros.** La resolución del contrato no afecta a los terceros de buena fe. El artículo 1876 aplica al contrato de compraventa los principios generales de los artículos 1490 y 1491 al señalar: “La resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino en virtud de los artículos 1490 y 1491”.

En consecuencia, si la cosa vendida es mueble, los terceros deben estar de mala fe, o sea, conocer el hecho de que el comprador adeudaba parte del precio. Si la cosa es inmueble, será menester que en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública, conste la existencia de dicho saldo de precio.

b.5) Declaración en la escritura de venta de haberse pagado el precio.

El inciso segundo del artículo 1876 establece: “Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores”. Cuando en la escritura se declara íntegramente pagado el precio la buena fe de los terceros es indudable.

¿Rige la disposición para accionar al vendedor contra el comprador que conserva la cosa en su poder?

Del contexto de los artículos 1875 y 1876 aparece indudable que se refieren, respectivamente, a los efectos de la resolución del contrato entre las partes y respecto de terceros. La disposición no se justifica sino como una medida de protección a los terceros, ante una eventual colusión de las partes. En fin, la interpretación contraria conduce al absurdo pues no sería siquiera admisible, como prueba para desvirtuar la aseveración de la escritura, la confesión del comprador de no haber pagado el precio. Si el comprador confiesa que no ha pagado el precio, sería insensato negar al vendedor acción para pedir que se le pague o que se resuelva el contrato, a pretexto de que no es admisible otra prueba que la nulidad o falsificación de la escritura.

b.6) Cláusula de no transferirse el dominio sino por el pago del precio.

El artículo 680 dispone: “Verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago”. Sería menester una reserva expresa.

En clara contradicción con el texto legal citado, el artículo 1874 del CC atribuye a la cláusula de no transferirse el dominio sino por el pago un alcance diferente. El dominio, pese a la estipulación, se transfiere al comprador; la falta de pago del precio no impide que se haga dueño, sino que otorga al vendedor el derecho de pedir el cumplimiento del contrato o su resolución, con indemnización de perjuicios. El artículo 1874 dispone expresamente: “La cláusula de no transferirse en dominio sino en virtud de la paga del precio, no producirá otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en el artículo precedente”.



Respuesta

De este modo, mientras el artículo 680 establece que si el vendedor se reserva expresamente el dominio hasta que el precio se pague, la tradición no hará dueño al comprador, el artículo 1874 declara enfáticamente que tal reserva no obsta a la adquisición de la propiedad por el adquirente. El comprador adquiere el dominio, expuesto a resolverse si, constituido en mora de pagar el precio, el vendedor opta por pedir la resolución del contrato.

El artículo 1874 concluye: “Pagando el comprador el precio, subsistirán en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la cosa, o los derechos que hubiere constituido sobre ella en el tiempo intermedio”.

2.10 Pactos Accesorios del Contrato de Compraventa.

El CC reglamenta tres de estos pactos: el **pacto comisorio**, el **pacto de retroventa**, y el **pacto de retracto**.

El artículo 1887 del CC dispone: “Pueden agregarse al contrato de venta cualesquiera otros pactos accesorios lícitos, y se regirán por las reglas generales de los contratos.

2.10.1 Pacto Comisorio.

a) Concepto, sus clases y sus efectos.

El pacto comisorio es la condición resolutoria de no cumplirse lo pactado, expresamente estipulado.



El pacto comisorio simple es aquel en que se estipula, lisa y llanamente, que se resolverá el contrato si no se cumple lo pactado. No difiere en sus efectos de la condición resolutoria tácita. El contrato no se resuelve de pleno derecho. El comprador y el vendedor tienen el derecho alternativo de pedir el cumplimiento o la resolución del contrato.

El pacto comisorio calificado es aquel en que se estipula que el incumplimiento resolverá ipso iure, en el acto o sin más trámite el contrato de compraventa. Tampoco resuelve el contrato de pleno derecho pues el acreedor podrá aun pedir su cumplimiento. El deudor podrá enervar la acción resolutoria pagando dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación judicial de la demanda.

2.10.2 Pacto de Retroventa.

a) Concepto.

Dispone el artículo 1881 del CC: “Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare o, en defecto de esta estipulación, lo que le haya costado la compra”.

El pacto de retroventa importa una condición resolutoria del contrato de compraventa. Se trata de una condición pura o meramente potestativa, porque depende de la sola voluntad del vendedor.

b) Ventajas e inconvenientes del pacto de retroventa.

Es un eficaz medio de procurarse dinero e propietario de una cosa de la que no desea desprenderse definitivamente. Presenta para el vendedor una ventaja sobre otras garantías como la hipoteca pues puede procurarse una mayor suma de dinero porque no contempla los gastos del

cobro del crédito. Para el comprador las ventajas son enormes pues podrá hacer suya la cosa por el solo hecho de que el vendedor deje pasar el plazo sin efectuar el reembolso, la venta se hará entonces, irrevocable.

Sus inconvenientes derivan de que, a menudo, sirve para encubrir un pacto comisorio que la ley terminantemente prohíbe. En el hecho la estipulación puede tener simplemente por objeto permitir al prestamista hacerse pago de su crédito con la cosa dada en garantía.

c) Requisitos del pacto de retroventa.

Para que el pacto de retroventa produzca sus efectos es menester que concurran los siguientes requisitos: primero, la facultad concedida al vendedor de recobrar la cosa; segundo, la obligación del vendedor de rembolsar al comprador; y, tercero, un plazo concedido al vendedor para ejercitar su derecho.

Es esencial, como se comprende, que el vendedor se reserve la facultad de recomprar la cosa vendida. La estipulación de la reserva debe hacerse en el mismo contrato de compraventa; no puede útilmente pactarse después de su celebración. La estipulación posterior importaría una promesa de compraventa.

El artículo 1881 del CC previene que el vendedor debe rembolsar al comprador el precio que se estipulare y, a falta de estipulación, el mismo precio de la venta.

Es indispensable un plazo para que el vendedor ejercite su derecho. El artículo 1885 dispone: “El tiempo en que se podrá intentar la acción de retroventa no podrá pasar de cuatro años, contados desde la fecha del contrato”. Las partes pueden, pues, señalar un plazo que no exceda de cuatro años.

d) Condiciones para ejercitar el derecho que emana del pacto de retroventa.

Para el ejercicio de los derechos que el pacto de retroventa genera para el vendedor y para que se opere la resolución del contrato de compraventa es preciso que concurran las siguientes condiciones: primero, que el vendedor haga valer judicialmente su derecho; segundo, que en el acto de ejercerlo ponga el precio a disposición del comprador; tercero, que el derecho se haga valer en tiempo oportuno; y, cuarto, que se dé el correspondiente aviso al comprador.

Si las partes se avienen a ejecutar la retroventa, el vendedor reembolsa el precio y el comprador restituye la cosa, no pueden suscitarse dificultades. Pero si el comprador se resiste, es indispensable que el vendedor ejercite su derecho acudiendo a la justicia.

En el acto de hacer valer su derecho, el vendedor debe pagar el precio. El término reembolsando indica claramente la idea de simultaneidad entre el ejercicio del derecho y el pago.

El vendedor deberá invocar el pacto de retroventa en tiempo oportuno, esto es, dentro del plazo convenido que no será superior a cuatro años. Expirado este plazo, el derecho del vendedor se extingue.

En fin, para ejercitar el derecho el vendedor debe avisar al comprador con la debida anticipación. El artículo 1885 señala: “En todo caso tendrá derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada, que no bajará de seis meses para los bienes raíces ni de quince días para las cosas

muebles. Si la cosa fuere fructífera, y no diere frutos sino de tiempo en tiempo, y a consecuencias de trabajos e inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada sino después de la próxima percepción de frutos”.

e) Efectos del pacto de retroventa.

Si el vendedor no ejerció su derecho en el plazo convenido o legal, fallará la condición resolutoria del contrato de venta. Caducarán los derechos del vendedor y los del comprador se consolidarán definitivamente.

Por la inversa, si el vendedor ejercita su acción en la debida oportunidad, se habrá cumplido la condición resolutoria, se resolverá el contrato de venta y las cosas volverán al mismo estado en que se encontrarían si no se hubiera contratado.

e.1) Efectos entre las partes.

El comprador está obligado, desde luego, a restituir la cosa con sus accesorios, de acuerdo con lo señalado en el inciso primero del artículo 1883 del CC que previene: “El vendedor tendrá derecho a que el comprador le restituya la cosa vendida con sus accesiones naturales”

El comprador debe indemnizar al vendedor por los deterioros de la cosa, conforme con el inciso segundo del artículo 1883 del CC que señala: “Tendrá asimismo derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables a hecho o culpa del comprador”.

Por su parte, el vendedor debe pagar al comprador las mejoras introducidas en la cosa, conforme al inciso tercero del artículo 1883 del CC que dice: “Será obligado al pago de las expensas necesarias, pero no de las invertidas en mejoras útiles o voluptuarias que se hayan hecho sin su consentimiento”.

e.2) Efectos contra terceros.

La resolución del contrato de compraventa les afectará a condición de que estén de mala fe.

f) El derecho que nace del pacto de retroventa es intransferible.

El artículo 1884 señala: “El derecho que nace del pacto de retroventa no puede cederse”. El derecho del vendedor podría, sin embargo, transmitirse por causa de muerte.

2.10.3 Pacto de retracto.

a) Concepto y efectos.

Se llama pacto de retracto o *adictio in diem* aquel en que las partes convienen que se resolverá la venta si, en un plazo determinado, se presenta un nuevo comprador que ofrezca al vendedor condiciones más ventajosas que el comprador primitivo.

El artículo 1886 dispone: “Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo, que no podrá pasar de un año, persona que mejore la compra se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado; a menos que el comprador o la persona a quien éste hubiere enajenado la cosa, se allane a mejorar en los mismo términos la compra”.

Entre las partes y entre terceros el pacto de retracto produce los mismos efectos que el pacto de retroventa, conforme a lo señalado en los incisos segundo y tercero del artículo 1886.

2.11 De la Rescisión de la Venta por Lesión Enorme.

2.11.1 Concepto y fundamento de la lesión enorme.

La lesión es el perjuicio pecuniario que las partes sufren como consecuencia de la falta de equivalencia de las prestaciones recíprocas de un contrato conmutativo. Una imperiosa necesidad de dinero ha forzado seguramente al vendedor a vender a cualquier precio; su consentimiento se encuentra profundamente viciado y la ley acude en su ayuda autorizándole para pedir aun la rescisión del contrato.

2.11.2 Requisitos de la rescisión por lesión enorme.

Tiene lugar la rescisión de la venta por causa de lesión siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la venta sea susceptible de rescindirse por causa de lesión. En términos generales solo tiene cabida en las compraventa de bienes raíces. No procede la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, como lo señala el artículo 1891 del CC. El artículo 126 del CCO dispone que no procede en los contratos mercantiles. No habrá tampoco lugar a la acción rescisoria en las ventas que se hubieren hecho por el ministerio de la justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 1891 del CC. Por último, no cabe la rescisión por lesión enorme, aunque se trate de inmuebles, en las ventas de minas, conforme al artículo 77 del Código de Minería.

b) Que la lesión sea enorme, en los términos que señala la ley. La desproporción entre las prestaciones de comprador y vendedor debe ser monstruosa; la ley reputa legítima una diferencia moderada. Puede sufrir lesión enorme el comprador y el vendedor.

El artículo 1889 del CC expresa: “El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. El comprador, a su vez, sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato”.

La prueba de la lesión incumbe a aquel de los contratantes que deduce la acción correspondiente.

c) Que la cosa no haya perecido en poder del comprador. El artículo 1893 del CC previene: “Perdida la cosa en poder del comprador no habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato”.

d) Que el comprador no haya enajenado la cosa. El inciso segundo del artículo 1893 señala que ninguno de los contratantes podrá pedir la rescisión de la venta si el comprador hubiere enajenado la cosa. Sin embargo, en caso de que el comprador haya enajenado la cosa

por más de lo que había pagado por ella, podrá el primer vendedor reclamar el exceso, pero sólo hasta la concurrencia del justo valor de la cosa, con deducción de una décima parte.

- e) Que la acción correspondiente se entable en tiempo oportuno.** El artículo 1896 dispone: “La acción rescisoria por lesión enorme espira en cuatro años, contados desde la fecha del contrato”. Como prescripción de corto tiempo, con arreglo al artículo 2524, corre contra toda clase de personas.

La acción rescisoria es irrenunciable porque autorizar la renuncia importaría abolir la acción. El artículo 1892 señala: “Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, no valdrá la estipulación; y si por parte del vendedor se expresare la intención de donar el exceso, se tendrá esta cláusula como no escrita”.

2.11.3 Efectos de la rescisión por lesión enorme.

Sus efectos son los propios de la nulidad, en suma, el vendedor recobrará la cosa y el comprador el precio pagado por ella. La rescisión se funda en la inicua desproporción entre las prestaciones del comprador y del vendedor. El restablecimiento del equilibrio de tales prestaciones desagravia a las partes y de este modo desaparecen sus motivos de queja. Si la víctima de la lesión ha sido el vendedor, podrá el comprador hacer subsistir el contrato aumentando el precio. Si al contrario, la víctima ha sido el comprador, puede hacer lo mismo el vendedor restituyendo parte del precio excesivo.

- a) Efectos si el demandado opta por evitar la rescisión.** Pronunciada la rescisión nace para los contratantes el derecho de enervar el fallo aumentando el precio el comprador o restituyendo parte del mismo el vendedor. El artículo 1890 establece: “El comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá a su arbitrio consentir en ella o completar el justo precio con deducción de una décima parte; el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte”.

La facultad del comprador o vendedor demandados de aceptar o evitar la rescisión pueden ejercerla a su arbitrio. La opción del demandado nace una vez fallado el pleito y declarada la nulidad. Fija la ley la cantidad que debe pagar el demandado para evitar la rescisión. El comprador debe pagar y el vendedor restituir una décima parte menos. En uno y otro caso, comprador y vendedor obtienen una ventaja del 10% sobre el justo precio que la venta reputa legítima.

- b) Frutos y expensas.** El comprador o el vendedor deben abonar frutos e intereses pero sólo desde la fecha de la demanda, conforme al inciso segundo del artículo 1890.

- c) Efectos si el demandado consiente en la rescisión del contrato.** La rescisión de la venta, en principio, da derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubieran celebrado el contrato nulo, con algunas importantes limitaciones:

- i. El comprador debe restituir la cosa y el vendedor el precio con intereses y frutos, pero sólo desde la demanda.
- ii. Las partes no están obligadas a pagar las expensas del contrato.
- iii. El artículo 1894 señala: “El vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los deterioros que haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se hubiere aprovechado de ellos.
- iv. La rescisión de la venta no afecta a los terceros adquirentes.
- v. No afecta tampoco a los terceros en cuyo favor hubiere constituido el comprador algún derecho real, conforme al artículo 1895 que dispone: “El comprador que se halle en el caso de restituir la cosa, deberá previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en ella”. La disposición deja en claro que las hipotecas y demás derechos reales no se extinguen de pleno derecho por la rescisión del contrato.

Tema 3: El Mandato.

3.1 Definición.

El artículo 2116 del CC dispone: **“El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante y la que lo acepta apoderado, procurador y, en general, mandatario. Puede haber uno o varios mandantes y uno o más mandatarios”.**

3.2 Caracteres del contrato.

Es un contrato generalmente consensual, por su naturaleza oneroso y bilateral. Rasgo característico del mandato es que el mandatario actúa por cuenta y riesgo del mandante.

3.2.1 El mandato es generalmente consensual.

Se perfecciona por el solo consentimiento del mandante y del mandatario. La voluntad del mandante de confiar la gestión de un negocio al mandatario y la voluntad de éste de aceptar el encargo puede manifestarse tácitamente.

El artículo 2123 del CC, dispone que el encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo inteligible, y aun por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra.

El artículo 2124 del CC, previene que el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. La aceptación del mandatario puede ser expresa o tácita. Importa aceptación tácita, conforme al artículo 2124 inciso segundo del CC, todo acto en ejecución del mandato. Sin

embargo, por excepción, el silencio del mandatario puede importar que acepta el encargo. El artículo 2125 del CC dispone que las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace, y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. Pero aunque rechacen el encargo las personas que se encargan habitualmente de negocios ajenos, deberán tomar las providencias conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda.

Aunque perfecto el mandato por la aceptación del mandatario, puede éste retractarse. No impone la retractación responsabilidad al mandatario si se verifica mientras el mandante se halle todavía en aptitud de ejecutar el negocio por sí mismo o de cometerlo a diversa persona, conforme al artículo 2124 inciso tercero. En caso contrario, es responsable de los perjuicios que ocasione al mandante su retractación. Se explica que el mandatario pueda poner fin al mandato unilateralmente, porque, debido a su peculiar naturaleza, y conforme al artículo 2163 número cuatro, el contrato termina por la renuncia del mandatario.

➡ **El mandato solemne.**

Por excepción el mandato puede ser solemne. El artículo 2123 del CC establece que no se admitirá la escritura privada para acreditarlo cuando las leyes requieran un instrumento auténtico. La norma concuerda con el artículo 1701 del CC en cuya virtud la falta de instrumento público no puede suplirse por ninguna otra prueba en los actos o contratos en que la ley exige esa solemnidad.

- a) Es solemne el mandato judicial; las solemnidades pueden consistir en una escritura pública, un acta extendida ante un juez de letras o un juez árbitro y suscrito por todos los otorgantes o por declaración escrita del mandante y autorizada por el secretario del tribunal que está conociendo de la causa, conforme al artículo 6 del CPC.
- b) También es solemne el mandato para contraer matrimonio, que debe constar por escritura pública.
- c) Debe constar por escritura pública, asimismo, el mandato que confiera la mujer casada para expresar su consentimiento a la enajenación de bienes raíces sociales o inmuebles suyos que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie, conforme a los artículos 1749 y 1754 del CC.

➡ **Mandato para ejecutar actos solemnes.**

La generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia estiman que el mandato para ejecutar actos solemnes debe estar revestido de las mismas solemnidades que éstos. Se dice que el consentimiento del mandante, generador del contrato, debe constar por escritura pública pues la observancia de las formalidades prescritas por la ley es la manera en que se expresa dicho consentimiento. Por otra parte, si bien el mandato es generalmente consensual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2123 del CC se exceptúa el caso en que debe constar de instrumento auténtico y no vale en tal caso la escritura privada.

Se refutan los argumentos anteriores, en primer lugar, porque el mandante no expresa su consentimiento necesario para que se genere el contrato, sino que es el mandatario el que expresa su propio consentimiento y no el del mandante. Quien contrata es el mandatario y sólo en virtud de la representación el contrato surte efectos respecto del mandante como si éste hubiera contratado. Por otra parte, el artículo 2151 del CC establece que el mandatario, en el desempeño del cargo, puede contratar a nombre del mandante o en el suyo propio; en el primer caso se obliga sólo el mandante, en el segundo el mandatario. Por último, el artículo 2123 dispone que el mandato es generalmente consensual. La disposición establece que es de rigor la forma pública cuando la ley exige que el mandato conste de esa manera.

3.2.2 El mandato es oneroso por su naturaleza

De acuerdo al artículo 2117 del CC el mandato puede ser gratuito o remunerado, esto es, oneroso. El mandato es generalmente oneroso; el mandante debe pagar una remuneración al mandatario, aunque no medie una expresa estipulación. Tal conclusión deriva del número tercero del artículo 2158 del CC que señala como una de las obligaciones del mandante la de pagar al mandatario la remuneración estipulada o la usual. La remuneración del mandatario, denominada honorario, se determina en primer término por acuerdo de las partes, anterior o posterior al contrato. Puede determinarse asimismo, conforme al artículo 2117 del CC, por la ley, la costumbre o el juez. La circunstancia de ser el mandato remunerado influye en la responsabilidad del mandatario, ya que conforme al artículo 2129 del CC, el mandatario es responsable de culpa leve, pero esta responsabilidad será más estricta en el mandatario remunerado.

3.2.3 El mandato es un contrato bilateral.

El mandato remunerado es obviamente un contrato bilateral. Pero también es bilateral el contrato gratuito. Se obliga al mandatario a cumplir el encargo y a rendir cuentas de su gestión; y el mandante, a su vez, contrae la obligación de proveerle de los medios necesarios para el desempeño de su cometido. El mandante, además, puede resultar obligado por circunstancias posteriores, con motivo de la ejecución del contrato, por ejemplo, rembolsar al mandatario los anticipos que haya hecho y los perjuicios que haya sufrido.

3.2.4 El mandatario obra por cuenta y riesgo del mandante.

El mandatario gestiona el negocio encomendado como algo ajeno, de manera que serán para el mandante los beneficios que la gestión le reporte y soportará las pérdidas como si tal gestión la realizara personalmente. La gestión del mandatario convierte al mandante en acreedor o deudor; personalmente aquél no se obliga para con terceros ni los obliga con él.

Mandato y representación.

La representación no es de la esencia del mandato. En el desempeño de su cometido el mandatario puede obrar a su propio nombre, y en tal evento no representa al mandante, pues para ello es indispensable que lo haga en nombre del mandante conforme a los artículos 1448 y

2151 del CC. El mandato confiere al mandatario la facultad de representar al mandante; se le entiende facultado para obligarle directamente, y como dicha voluntad no requiere de una especial mención, ha de concluirse que la representación es de la naturaleza del mandato. Si el mandatario obra a su propio nombre, se obliga él y no obliga al mandante. Pero como pese a las apariencias el mandatario actúa por cuenta ajena, sus relaciones con el mandante se rigen por las reglas del mandato. Para los terceros el mandatario es el titular de los derechos emergentes del acto realizado; frente al mandante, continúa siendo mandatario.

3.3 Requisitos del Mandato.

3.3.1 Objeto del mandato. El objeto del mandato debe consistir en la ejecución de actos jurídicos. Se comprueba este aserto si se examinan las facultades que el mandato confiere naturalmente al mandatario. El encargo que consiste en la ejecución de un hecho material, como construir un camino, levantar un muro, no constituye un mandato sino un contrato de arrendamiento de servicios o de confección de obra material.

3.3.2 Servicios Profesionales. El artículo 2118 establece que los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o a que está unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato.

3.3.3 Actos jurídicos a que es aplicable el mandato. Todos los actos jurídicos pueden ser ejecutados por medio de mandatarios. La regla tiene muy contadas excepciones. La más calificada la constituye el testamento, conforme al artículo 1004 del CC que dispone que la facultad de testar es indelegable.

3.3.4 El negocio no debe interesar sólo al mandatario. El mandato se celebra comúnmente en interés exclusivo del mandante. Si el negocio es de mutuo interés para el mandante y el mandatario, del mandante y un tercero, o de un tercero exclusivamente, habrá verdadero mandato. En caso que el mandante obre sin autorización del tercero mediará entre ambos un cuasicontrato de agencia oficiosa, conforme al artículo 2120. Pero no existe mandato si el negocio interesa solamente al mandatario; semejante mandato es un mero consejo que no produce obligación alguna conforme al artículo 2119 del CC. Dado maliciosamente obliga a la indemnización de perjuicios.

3.3.5 Capacidad de las partes.

La capacidad que requieren uno y otro para celebrar el contrato ha de ser necesariamente diversa:

a) Capacidad del mandante.

Basta considerar, en efecto, que es jurídicamente el mandante quien celebra el acto y que el mandatario es sólo un instrumento suyo, su representante. Por tanto, el mandante debe tener la capacidad necesaria para ejecutar el acto a que el mandato se refiere.

b) Capacidad del mandatario.

El artículo 2128 del CC dispone: “Si se constituye mandatario a un menor adulto o a una mujer casada, los actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a éstos y al mandante; pero las obligaciones del mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a los menores y a las mujeres casadas”. Por tanto, a menos que en la aceptación del mandato haya intervenido la autorización del representante legal del incapaz, no serán válidas las obligaciones del mandatario; en definitiva, no podrá reclamársele el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mandato sino en cuanto se hubiere hecho más rico.

3.4 Diversas Clases de Mandato.

Atendida la extensión de los negocios confiados al mandatario, el mandato puede ser general o especial. Desde el punto de vista de las facultades conferidas al mandatario, el mandato puede ser definido o indefinido.

✚ **Mandato general y especial.** El artículo 2130 del CC establece que se llama especial al mandato que comprende uno o más negocios especialmente determinados. Asimismo, será general el mandato que se da para todos los negocios del mandante y también cuando se da para todos con una o más excepciones determinadas. Esta clasificación interesa para determinar en qué clase de negocios puede intervenir legítimamente el mandatario.

✚ **Mandato definido e indefinido.** El mandato puede estar concebido en términos generales o indefinidos, sin precisar los poderes o facultades conferidos al mandatario. Puede, asimismo, estar concebido en términos más o menos precisos y definirse con alguna exactitud las atribuciones del mandatario.

3.5 Facultades del mandatario.

El artículo 2132 del CC dispone: “El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración. Para todos los actos que salgan de estos límites necesitará de poder especial”. El artículo 2133 prescribe que la facultad para obrar como mejor le pareciere no autoriza al mandatario para alterar la sustancia del mandato ni para los actos que exigen poderes o cláusulas especiales. Conforme al artículo 2133 inciso segundo, la cláusula de libre administración confiere sólo al mandatario la facultad de ejecutar los actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula. En suma, por generales que sean los términos del mandato, y aunque se empleen términos enfáticos que sugieran una gran latitud de poderes, no se confiere al mandatario sino la facultad para ejecutar actos administrativos.

➡ **Concepto de acto de administración.**

Administrar es adoptar las medidas de carácter material o jurídico tendientes a conservar los bienes, a incrementarlos y a obtener las ventajas que puedan procurar. El artículo 2132 del CC expresa que el mandato confiere naturalmente al mandatario el poder de ejecutar actos de

administración como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario, perseguir en juicio a los deudores, intentar las acciones posesorias e interrumpir las prescripciones en lo tocante a dicho giro, contratar la reparación de las cosas que administra, y comprar los materiales necesarios para el cultivo o beneficio de las tierras, minas, fábricas, u otros objetos de industria que se le hayan encomendado.

Los actos conservativos pueden ser materiales o jurídicos. Pero la acción de administrar no comprende la ejecución de actos puramente conservativos; abarca, asimismo, la ejecución de actos que tiendan a obtener de los bienes administrados el provecho o rendimiento que están llamados ordinariamente a brindar. Un límite no muy definido separa los actos de administración de los actos de disposición, caracterizados estos últimos porque cambian o alteran la composición del patrimonio.

➡ **Actos que requieren un poder especial.**

El artículo 2132 inciso segundo del CC establece, como regla general, que para todos los actos que salgan de los límites que señala necesita el mandatario de un poder especial o expreso. Se señalan algunos casos para los cuales el otorgamiento de un poder especial es indispensable:

- a) Un poder especial es necesario para transigir, conforme al artículo 2448 del CC, con especificación de los bienes, derechos y acciones sobre que debe versar la transacción.
- b) El artículo 7 del CPC señala que no se entienden conferidas al mandatario sin especial mención las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y transigir.

➡ **Facultades especiales que el CC reglamenta.**

El artículo 2141 establece que la facultad de transigir no comprende la de comprometer y viceversa. Por otra parte, el artículo 2142 establece que la facultad de vender comprende naturalmente la de recibir el precio. La facultad de vender depende de si las cosas vendidas quepan o no al giro ordinario del negocio administrado.

3.6 Obligaciones del Mandatario.

3.6.1 Obligación de cumplir el mandato.

➡ **Ejecución del mandato.**

Debe cumplir el mandato, ejecutar el encargo que se le ha confiado. Toda vez que de la inejecución del mandato se siga un perjuicio para el mandante, tendrá derecho para que el mandatario le indemnice.

➡ **El mandatario debe ceñirse a los términos del mandato.**

Debe conformarse a los términos en que le fue conferido. El artículo 2131 del CC señala: “El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen para obrar de otro modo”. Conforme al artículo 2160 solamente los actos que el mandatario ejecute dentro de los límites del mandato obligan al mandante. El artículo 2134 dispone que “La recta ejecución del mandato comprende no sólo la sustancia del negocio encomendado sino los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo”.

La regla general tiene excepciones, bien porque las instrucciones recibidas resultan impracticables bien porque de su rigurosa aplicación se puede seguir un daño al mandante:

- i. El artículo 2149 dispone que el mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente pernicioso al mandante.
- ii. Conforme al artículo 2150 la imposibilidad de obrar según las instrucciones recibidas permite al mandatario excusarse de cumplirle encargo, con tal que adopte las medidas de conservación necesarias para que no sufran menoscabo los intereses del mandante. Con todo, el precepto añade que si no fuera posible dejar de obrar sin comprometer seriamente al mandante, el mandatario tomará el partido que más se acerque a sus instrucciones y que más convengan al negocio. Concluye el artículo diciendo que toca al mandatario probar las circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que le imposibiliten para llevar a efecto las órdenes del mandante.
- iii. La recta ejecución del mandato comprende los medios por los cuales el mandante ha querido que se lleve a cabo. Pero tales medios pueden resultar inadecuados. En tal caso, podrá el mandatario apartarse de sus instrucciones al respecto y emplear medios equivalentes si la necesidad obligare a ello y se obtuviere completamente de ese modo el objeto del mandato, conforme al artículo 2134 del CC.
- iv. Por último el artículo 2148 consagra que: “Las facultades concedidas al mandatario se interpretarán con alguna más latitud cuando no está en situación de poder consultar al mandante”.

➡ **Pluralidad de mandatarios.**

Plantea la cuestión de averiguar en qué términos dividen entre ellos la gestión del mandato. Desde luego debe seguirse la voluntad del mandante, pero si el mandante no ha expresado su voluntad, podrán los mandatarios dividir entre ellos la gestión, a menos que el mandante haya dispuesto que deban actuar de consuno, conforme al artículo 2127 del CC.

➡ **Prohibiciones impuestas al mandatario en la ejecución del mandato.**

- i. Se prohíbe al mandatario comprar para sí lo que el mandante le ha ordenado vender y vender de lo suyo al mandante lo que se le ha ordenado comprar. La prohibición no es absoluta porque la compra o la venta son viables con la aprobación del mandante, conforme al artículo 2144 del CC.
- ii. Puede el mandatario prestar dinero al mandante que le ha encargado tomar dinero prestado, al interés fijado o, en su defecto, al interés corriente. Pero le está vedado, a la inversa,

tomar para sí el dinero cuya colocación el mandante le ha confiado, a menos que medie la autorización de éste, conforme al artículo 2145 del CC.

iii. Sin la expresa autorización del mandante no es lícito al mandatario colocar a interés dineros del mandante. En caso de colocar el dinero del mandante a un interés superior al designado por éste, debe el mandatario abonárselo, salvo que se le aya autorizado para apropiarse del exceso conforme al artículo 2146 del CC.

iv. Con tal que no se aparte de los términos del mandato, puede el mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar el encargo con mayor beneficio y menor gravamen para el mandante. Pero se le prohíbe apropiarse lo que exceda el beneficio o disminuya el gravamen designado por el mandante, conforme al artículo 2147 del CC. En cambio, si negociare con menos beneficio o más gravámenes que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia.

➡ **Responsabilidad del mandatario.**

Debe emplear en la ejecución del mandato la diligencia de un buen padre de familia. El artículo 2129 del CC señala que “El mandatario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo”. Conforme al artículo 2129 del CC, la indicada responsabilidad recae más estrictamente sobre el mandatario remunerado y será menos estricta si el mandatario ha manifestado repugnancia al encargo y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las instancias del mandante.

➡ **Responsabilidad del mandatario por la insolvencia de los deudores.**

El mandatario no responde de la insolvencia de los deudores. El mandatario es un simple intermediario y los actos que ejecuta generan obligaciones entre el mandante y terceros. Sin embargo, en virtud de una expresa estipulación, puede el mandatario tomar sobre su responsabilidad la solvencia de los deudores y todas las incertidumbres y embarazos del cobro, conforme al artículo 2152 del CC. En verdad, en tal caso, no existe verdadero mandato porque el mandatario no actúa por cuenta y riesgo del mandante. El artículo 2152 del CC previene que como consecuencia de este pacto especial el mandatario se constituye principal deudor para con el mandante y son de su cuenta hasta los actos fortuitos y la fuerza mayor.

➡ **Delegación del mandato.**

La delegación está permitida salvo que el mandante prohíba al mandatario delegar, pero las consecuencias de la delegación son sustancialmente diversas según que el mandante simplemente no la haya prohibido o bien la haya autorizado de un modo expreso:

i. Si la delegación no ha sido autorizada ni prohibida por el mandante; el mandatario puede delegar el mandato pero los terceros carecen de acción contra el mandante por los actos del delegado, conforme al artículo 2136 del CC. El artículo 2135 del CC dispone que el mandatario responderá de los hechos del delegado como de los suyos propios.

- ii. Si la delegación ha sido autorizada sin indicación de la persona del delegado; no es responsable el mandatario de los actos del delegado a menos que haya escogido a una persona notoriamente incapaz o insolvente, conforme al artículo 2135 inciso segundo del CC.
- iii. Si la delegación ha sido autorizada con indicación de la persona del delegado; no responde el mandatario de los actos del delegado porque se entiende constituido un nuevo mandato entre mandante y delegado, conforme al artículo 2137 del CC.
- iv. Si la delegación ha sido prohibida por el mandante; el mandatario no puede delegar y los actos del delegado no obligan al mandante a menos que éste los ratifique. En todo caso, aunque la delegación no haya sido autorizada, el mandante podrá ejercer contra el delegado las acciones del mandatario que le confirió el encargo, conforme al artículo 2138 del CC.

3.6.2 Obligación de rendir cuenta.

Dispone el artículo 2155 del CC que el mandatario es obligado a dar cuenta de su administración. La obligación de rendir cuentas se justifica porque el mandatario no obra por su cuenta, sino por cuenta del mandante. Las partidas importantes de la cuenta deben ser documentadas si el mandante no ha relevado al mandatario de esta obligación. Puede el mandante relevar al mandatario de la obligación de rendir cuentas, pero no que da por ello exonerado de los cargos que contra él justifique el mandante, conforme a lo dispuesto en el artículo 2155 del CC.

- ➡ **El mandatario debe restituir al mandante cuanto hubiese recibido por él en el desempeño del mandato.** El artículo 2157 del CC dispone que el mandatario es responsable de lo que ha recibido de terceros en razón del mandato. La restitución comprende aun lo que el mandatario recibió y que no se debía al mandante. Todavía más, la restitución debe incluir lo que el mandatario ha dejado de recibir por su culpa.
- ➡ **Suerte de las especies metálicas que el mandatario tiene por cuenta del mandante.** El artículo 2153 del CC dispone que tales especies perecen para el mandatario aún por fuerza mayor o caso fortuito, salvo que estén contenidas en cajas o sacos cerrados y sellados sobre los cuales recaiga el accidente o la fuerza o que por otros medios inequívocos pueda probarse incontestablemente la identidad. El mandatario es en verdad depositario de los dineros del mandante; por tratarse de un depósito irregular, a menos que se encuentren en sacos o cajas cerradas y selladas, se hace dueño de estos dineros, con cargo de restituir otro tanto, conforme al artículo 2221 del CC.
- ➡ **Intereses que debe el mandatario.** Intereses sobre los dineros del mandante que haya empleado en su propio beneficio y sobre el saldo que en su contra arroje la cuenta. De este modo, y conforme al artículo 2156 del CC, por los dineros del mandante que empleó en su beneficio debe el mandatario intereses corrientes; por el saldo de cuentas debe, generalmente, intereses legales.

3.7 Obligaciones del Mandante.

Emanan del contrato mismo o de circunstancias posteriores derivadas de su ejecución; estas últimas, en consecuencia, pueden existir o no existir.

3.7.1 Cumplimiento de las obligaciones contraídas por el mandatario.

- ➡ **El mandante debe cumplir las obligaciones que contraiga el mandatario, a su nombre, dentro de los límites del mandato.**

El artículo 2160 dispone: “El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato”. La disposición es una lógica consecuencia de la representación que el mandatario inviste; los actos que ejecute se reputan actos del mandante. Dos condiciones han de reunirse para que el mandante quede colocado en la necesidad de cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario: primero, que el mandatario obre a nombre del mandante; y, segundo, que actúe dentro de los límites del mandato.

- ➡ **El mandatario debe obrar a nombre del mandante.**

Ante terceros, con quienes contrata, el mandatario no representa al mandante y no lo obliga, por consiguiente, sino a condición de obrar en su calidad de tal mandatario. El mandatario que obró a su propio nombre se obliga personalmente a terceros y el mandante no contrae obligaciones. Pero en sus relaciones con el mandante, el mandatario se reputará haber obrado por cuenta de aquel; a ello se obligó al aceptar el mandato. En consecuencia, deberá rendir cuenta de su gestión y el mandante puede exigirle que le ceda las acciones que le competan contra terceros con quienes contrató en su propio nombre.

- ➡ **El mandatario debe obrar dentro de los límites del mandato.**

En cuanto excede de tales límites carece de poder y, por lo mismo, no obliga al mandante. Pero el mandante puede aceptar las obligaciones contraídas por el mandatario fuera de los límites del mandato mediante la ratificación, expresa o tácita, como lo expresa el artículo 2160 del CC. Expresa será la ratificación que se hace en términos formales. Es tácita la ratificación que resulta de la ejecución de actos del mandante que importen un inequívoco propósito de apropiarse de lo hecho por el mandatario.

- ➡ **Efectos de la extralimitación del mandato.**

En principio el mandatario tampoco se obliga personalmente como lo dispone el artículo 2154 del CC. Para que el mandatario responda ante terceros es menester que concurra alguna de las dos siguientes circunstancias: primero, que se haya obligado personalmente; o, segundo, que no les haya dado suficiente conocimiento de sus poderes. Cuando se haya obligado personalmente, será el mandatario responsable ante terceros si ha asumido tal responsabilidad. La circunstancia de no dar a conocer debidamente a terceros sus poderes ha podido inducir a éstos a creer que los límites

del mandato no eran sobrepasados. Es justo que el mandatario responda de las consecuencias de un error que le es imputable.

➡ **Casos en que el mandatario se convierte en agente oficioso.**

En determinadas circunstancias, previstas en el artículo 2122 del CC, el mandatario se convierte en un agente oficioso:

- i. El mandatario que ejecuta de buena fe un mandato nulo.
- ii. El mandatario que se excede en los límites del mandato por causa de una imperiosa necesidad.

➡ **Ejecución parcial del mandato.**

La ejecución parcial del mandato no obliga al mandante sino cuando del cumplimiento del encargo reporta beneficio. El artículo 2161 del CC dispone: “Cuando por los términos del mandato o por la naturaleza del negocio apareciere que no debió ejecutarse parcialmente, la ejecución parcial no obligará al mandante sino en cuanto le aprovechare”. Además el mandatario deberá indemnizar al mandante los perjuicios que la ejecución parcial le irrogaren.

3.7.2 Provisión de lo necesario para cumplir el mandato.

El número primero del artículo 2158 dispone que el mandante es obligado a proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. No está obligado el mandatario a emplear recursos propios en el cumplimiento del encargo. La falta de provisión de fondos autoriza al mandatario para desistir del encargo, conforme al artículo 2159 del CC.

3.7.3 Obligación de indemnizar al mandatario.

El mandante tiene la obligación de procurar que el mandatario quede totalmente indemne de las resultas del desempeño del mandato. La indemnización comprende:

- i. El reembolso de los gastos razonables causados por la ejecución del mandato.
- ii. El reintegro de las anticipaciones de dinero con intereses corrientes.
- iii. El pago de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa y por causa del mandato.

3.7.4 Obligación de remunerar al mandatario.

➡ **Pago de honorarios.**

El mandante tiene la obligación de pagar al mandatario la remuneración estipulada usual, conforme al artículo 2158 del CC. En consecuencia, el mandante debe pagarla remuneración acordada, antes o después del contrato; a falta de estipulación, la remuneración será la usual, esto es, la que se acostumbra pagar por la clase de servicios de que se trate. En caso de desacuerdo de las partes la remuneración será fijada por el juez.

➡ **Ineludibilidad de las obligaciones del mandante.**

El artículo 2158 del CC señala: “No podrá el mandante dispensarse de cumplir estas obligaciones, alegando que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo desempeñarse a menos costo, salvo que pruebe culpa”. Es natural que así ocurra pues el mandatario no se obliga a llevar al éxito el negocio que se le ha encomendado sino a poner lo que esté de su parte para conseguir tal resultado.

➡ **Incumplimiento del mandante.**

Autoriza al mandatario para excusarse del desempeño del cargo. El artículo 2159 del CC dispone: El mandante que no cumple por su parte aquello a que es obligado, autoriza al mandatario para desistir de su encargo”.

➡ **Derecho legal de retención del mandatario.**

El artículo 2162 del CC establece: “Podrá el mandatario retener los efectos que se le hayan entregado por cuenta del mandante para la seguridad de las prestaciones a que éste fuere obligado por su parte”.

3.8 Extinción del Mandato.

3.8.1 Causales de extinción del mandato.

Señala el artículo 2163 del CC que el mandato termina:

a) Por el desempeño del negocio para que fue constituido.

El mandatario ha terminado su misión, pagado su obligación. De esta manera termina, como se comprende, sólo el mandato que se ha otorgado para un negocio concreto y determinado.

b) Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato.

El efecto propio de estas modalidades es la extinción de la relación jurídica en la que inciden.

c) Por la revocación del mandante.

El mandato es un contrato de confianza y, por regla general, cede en exclusivo beneficio del mandante. Ambas circunstancias justifican que el mandante pueda ponerle unilateralmente fin, cuando crea convenirle. Tiene el mandante esta facultad aunque el mandato sea remunerado. En cuanto a sus formas, la revocación del mandato puede ser expresa o tácita, total o parcial. La revocación tácita es la que se produce por el encargo del mismo negocia a distinta persona, conforme al artículo 2164 del CC. Será parcial la revocación si ella se refiere sólo a una parte de los negocios confiados al mandatario. El otorgamiento de un mandato especial después de haberse

conferido uno de carácter general importa revocación del primero solamente en aquello sobre que versa el segundo, conforme al artículo 2164 del CC.

La revocación, bien sea expresa o tácita, produce sus efectos desde el día en que el mandatario ha tenido conocimiento de ella, conforme al artículo 2165 del CC. La noticia al mandatario de la revocación puede darse de cualquier forma, pero será prudente darla por medio de notificación judicial para que de ella quede constancia auténtica. Pero la revocación, aunque notificada al mandatario, no puede oponerse a terceros que, ignorantes de ella, trataron de buena fe con el mandatario. Por éste motivo el mandante tendrá interés en notificar también a los terceros.

Revocado el mandato, el mandante tiene derecho a reclamar del mandatario la restitución de los instrumentos que haya puesto en sus manos para la ejecución del encargo; pero de aquellas piezas que puedan servir al mandatario para justificar sus actos, deberá el mandante darle copia cuando se lo exigieren, conforme a lo dispuesto en el artículo 2166 del CC.

d) Por la renuncia del mandatario.

El mandatario puede unilateralmente poner fin al mandato. La renuncia deberá ponerse en conocimiento del mandante, por cualquier medio, pero no surte sus efectos sino al cabo de un tiempo prudente para que el mandante pueda adoptar las medidas adecuadas para la atención del negocio que le había encargado al mandatario, conforme lo dispuesto en el artículo 2167 del CC. El mandatario que no continúa prestando atención a los negocios que se le encomendaron, deberá indemnizar los perjuicios que la renuncia cause al mandante. Cesa esta responsabilidad cuando la renuncia es motivada por, primero, la imposibilidad en que se encuentra de administrar por enfermedad u otra causa; y, segundo, a consecuencia de que la gestión le causa grave perjuicio en sus intereses propios, conforme al artículo 2167 inciso segundo del CC.

e) Por la muerte del mandante o del mandatario.

El mandante otorga el mandato en razón de la confianza que le inspira el mandatario; el mandatario es movido a aceptar el encargo por la estimación o afecto que le inspira el mandante. La muerte del mandatario pone siempre término al mandato; la muerte del mandante pone fin al mandato salvo excepciones:

- i. No termina por la muerte del mandante el mandato llamado a ejecutarse después de ella; los herederos suceden en los derechos y obligaciones del mandante, conforme al artículo 2169 del CC.
- ii. Tampoco termina por la muerte del mandante el mandato judicial, conforme al artículo 396 del COT.

Pese a que el mandato termina siempre con la muerte del mandatario y que sus obligaciones no pasan a sus herederos, la ley ha adoptado medidas para proveer a que los intereses del mandante no queden abandonados. Con este objeto, los herederos del mandatario que fueren hábiles para la administración de sus bienes, los albaceas, los tutores y curadores y, en general, todos los que

sucedan en la administración de los bienes del mandatario difunto, deberán cumplir una doble obligación:

- i. Dar aviso inmediato al mandante de la muerte del mandatario, y
- ii. Hacer a favor del mandante lo que puedan y lo que las circunstancias exijan.

Las omisiones en que incurran al respecto los harán responsables de los perjuicios que, por tal motivo, sufran los negocios del mandante, conforme al artículo 2170 del CC.

f) Por la quiebra o insolvencia de uno u otro.

No merece confianza como gestor de negocios ajenos quien no ha sido capaz de gestionar los propios. En cuanto al mandante que se encuentra en la misma situación, estará impedido para cumplir las obligaciones del mandato, o, como en el caso de la quiebra, la administración de sus bienes pasa al Síndico de Quiebras.

g) Por la interdicción del uno o del otro.

Se comprende que si el mandatario no puede administrar sus propios bienes tampoco podrá administrar los ajenos. Por lo que toca al mandante interdicto, la administración de sus bienes corresponde a un curador; además como no puede administrar sus bienes personalmente es lógico que tampoco pueda hacerlo por intermedio de un mandatario.

h) Por el matrimonio de la mujer mandataria.

El matrimonio determina, por regla general, la incapacidad de la mujer casada; si bien los actos suyos pueden obligar al mandante para con terceros, las obligaciones entre mandante y mandatario no pueden tener efecto sino según las reglas relativas a las mujeres casadas. Muy diverso es el caso de que se confiera mandato a una mujer actualmente casada; el mandante procede a sabiendas y con conocimiento de los riesgos a que le expone la incapacidad. Preciso, eso sí, es limitar la regla al caso de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal. En cambio, no termina el mandato por la muerte de la mujer mandante, pero el marido podrá revocarlo a su arbitrio, siempre que se refiera a actos o contratos relativos a bienes cuya administración corresponda a éste, conforme lo dispuesto en el artículo 2171 del CC.

i) Por la cesación de las funciones del mandante si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas.

Se comprende que si el mandante cesa en las funciones en cuyo desempeño otorgó el poder se extinga el mandato. De otro modo las funciones en que el mandante cesó, en verdad, se prolongarían en el mandatario.

3.8.2 Falta de uno de los mandatarios conjuntos.

A las causales que señala el artículo 2163 del CC debe añadirse la que señala el artículo 2172 que prescribe: “Si son dos o más los mandatarios y por la constitución del mandato están obligados a

actuar conjuntamente, la falta de uno de ellos por cualquiera de las causas antedichas pondrá fin al mandato”.

3.8.3 Actos ejecutados por el mandatario después de expirado el mandato.

No obligan al mandante, no le son oponibles. Tal es la regla general, sin embargo, este principio tiene excepciones que encuentran su fundamento en la buena fe de los terceros con quienes el mandatario contrata:

- a) Si el mandatario ignora que ha expirado el mandato y cree, por consiguiente, que el mandato subsiste, los actos que ejecute obligarán al mandante para con los terceros que, por su parte, ignoraron la extinción del mandato, conforme al artículo 2173 inciso primero del CC. Se supone en consecuencia que tanto el mandatario como los terceros están de buena fe.
- b) Si el mandatario no ignoraba la expiración del mandato pero esta circunstancia era ignorada por los terceros, se obliga igualmente el mandante conforme al artículo 2173 inciso segundo del CC.

En consecuencia, lo decisivo es la buena fe de los terceros; esta buena fe es la que determina que el mandante se obligue como si subsistiera el mandato. La mala o buena fe del mandatario es indiferente en las relaciones del mandante y terceros. Importa solamente en las relaciones del mandante y mandatario. En ambos casos el mandante deberá cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario, pero tiene derecho a demandar perjuicios al mandatario de mala fe. Toca al juez decidir acerca de la buena o mala fe de los terceros. El artículo 2173 concluye que: “Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere sido notificado al público por periódicos y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero, podrá el juez en su prudencia absolver al mandante”.

Unidad 3: Contratos Accesorios o de Garantía.

Tema 1: Generalidades.

1.1 El derecho de prenda general de los acreedores.

Los acreedores pueden perseguir la ejecución de sus créditos sobre todos los bienes del deudor, presentes o futuros, raíces o muebles, exceptuando los inembargables, conforme al artículo 2465 del CC. Los bienes que el deudor ha enajenado escapan a la persecución de los acreedores, salvo que éstos, por medio del ejercicio de la acción adecuada, logren reintegrarlos al patrimonio del enajenante. En compensación, la ejecución recae también sobre los bienes futuros, o sea, aquellos que el deudor adquiera después de que contrajo la obligación.

1.2 Imperfecciones del derecho de prenda general.

No brinda a los acreedores sino una garantía relativa porque vale exactamente lo que vale el patrimonio del deudor. El deudor que se obliga no abdica de la facultad de disposición de sus bienes ni de contraer nuevas obligaciones. De este modo, el patrimonio del deudor puede experimentar alternativas, sea por la enajenación de bienes, sea por el hecho de contraer nuevas obligaciones. El derecho de prenda general, en resumen, constituye una garantía para los acreedores en la medida de la solvencia del deudor.

1.3 Derechos auxiliares del acreedor.

La ley dota a los acreedores de un conjunto de recursos para velar por la integridad del patrimonio del deudor con miras a la realización posterior de los bienes que lo integran.

Con las medidas conservativas o de precaución pretenden los acreedores impedir que los bienes del deudor se menoscaben, deterioren o enajenen.

La acción oblicua o subrogatoria tiende a incrementar el patrimonio del deudor mediante el ejercicio de derechos suyos que éste negligentemente deja de ejercitar.

Por medio de la acción pauliana o revocatoria, tratan los acreedores de reintegrar al patrimonio del deudor bienes que éste hizo salir fraudulentamente, provocando su insolvencia o acrecentando una insolvencia anterior.

1.4 Las garantías.

Las garantías encaminadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones pueden revestir variadas formas. Las más importantes garantías obedecen a la denominación genérica de cauciones. El artículo 46 del CC las define y expresa que caución es cualquiera obligación que se

contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena, señalando como ejemplos la fianza, la prenda y la hipoteca.

Pero las garantías pueden adoptar muchas otras formas:

- i. Constituye una importantísima garantía la solidaridad, puesto que permite al acreedor reclamar el pago íntegro de su crédito a cada uno de los varios codeudores.
- ii. La cláusula penal es otra importante garantía, pues por ella se estipula que el deudor o un tercero pagarán una pena en caso de no cumplirse la obligación principal o de retardarse el cumplimiento.
- iii. La anticresis es otra garantía por la que se entrega al acreedor un bien raíz para que se pague con sus frutos.
- iv. Especial mención merece el derecho real de retención que autoriza a una persona para conservar en su poder un bien que debe restituir mientras no se efectúen determinadas prestaciones en su favor.
- v. La indivisibilidad de pago también es una eficaz garantía para el acreedor, en la que el causante y su acreedor convienen que la obligación pueda reclamarse íntegramente as los herederos; a falta de tal estipulación cada heredero deberá pagar la deuda a prorrata de su cuota hereditaria.
- vi. Las arras dadas en prenda de la celebración del contrato otorgan a las partes la facultad de retractarse, perdiendo las arras el contratante que las dio, y el que las recibió, restituyéndolas dobladas.

1.5 Garantías personales y reales.

Las garantías personales se caracterizan porque el acreedor dispone de otro patrimonio, además del patrimonio del deudor, para perseguirle cumplimiento de la obligación. Dispone, puede decirse, de dos derechos de prenda general.

Pero más eficaces son las garantías reales que se caracterizan porque afectan determinados bienes al cumplimiento de la obligación. Las garantías reales más importantes y típicas son la prenda y la hipoteca. Estas garantías otorgan al acreedor dos inestimables ventajas: el derecho de persecución y el derecho de pago preferente.



1.6 Las preferencias.

Es una clara ventaja para el acreedor la facultad de pagarse de su crédito con anterioridad a otros acreedores, especialmente cuando los bienes del deudor son insuficientes para satisfacerlos a todos. En principio tienen un carácter personal, no pasan contra terceros, en virtud de lo prescrito en los artículos 2473 y 2486 del CC.

Los privilegios pasan excepcionalmente a terceros: primero, pasa contra terceros el privilegio de cuarta clase contra el propietario de un piso o departamento por expensas comunes, porque siempre sigue al dominio de su piso o departamento; y, segundo, pasa igualmente contra terceros el privilegio de primera clase del Fisco en contra del deudor de impuesto a la renta que cesa en sus actividades por venta, cesión, traspaso de sus bienes, negocio o industria.

Tema 2: La Hipoteca.

2.1 Generalidades.

2.1.1 Concepto.

El artículo 2407 del CC señala: “La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor”. No es conveniente definir la hipoteca como un contrato; el derecho de hipoteca suele no tener un origen contractual. Existen hipotecas legales y judiciales. Por eso, es preferible definir la hipoteca como un derecho real, carácter que presenta en cualquiera que sea su origen.

La hipoteca es un derecho real que grava un inmueble que no deja de permanecer en poder del constituyente, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de quienquiera que la posea y de pagarse preferentemente con el producto de su realización. La hipoteca consiste esencialmente, pues, en afectar preferentemente y sin desplazamiento un determinado bien inmueble a la ejecución de una obligación.

2.1.2 Importancia de la hipoteca.

Es la más importante de las cauciones, tanto por la magnitud de los créditos que garantiza como por el valor de los bienes raíces que grava.

Para cumplir su finalidad la inscripción conservatoria debe reunir una doble condición:

- i. Todas las hipotecas, sin excepción alguna, deben inscribirse, o sea, la publicidad de las hipotecas debe ser general. No deben existir hipotecas ocultas.
- ii. La hipoteca debe ser especial, es decir, limitada a la vez en cuanto a los inmuebles que grava y a las obligaciones que garantiza.

La publicidad de las hipotecas pone en evidencia los gravámenes y da la medida en que pueden disponer del inmueble para nuevos empréstitos. En fin, el público en general está interesado en un buen régimen hipotecario porque fomenta el crédito, reprime la usura y permite obtener mayores créditos con garantía de los bienes raíces.

2.2 Caracteres de la hipoteca.

En un derecho real e inmueble; es igualmente un derecho accesorio. Genera un derecho de preferencia y es indivisible.

2.2.1 La hipoteca es un derecho real.

El artículo 577 del CC enuncia la hipoteca entre los derechos reales. Consecuencia de este carácter es el derecho de persecución de que está dotado el acreedor hipotecario que le habilita para perseguir la finca en manos de quienquiera que la posea y a cualquier título que la haya adquirido, conforme a lo dispuesto en el artículo 2428 del CC. Sin embargo, la hipoteca presenta diferencias con respecto a los otros derechos reales. No hay una relación directa entre la cosa y el titular del derecho. La hipoteca es, por así decirlo, un derecho real de segundo grado. Es un derecho real que recae sobre otro derecho real. El derecho real de hipoteca se traduce en la facultad del acreedor impago para vender la cosa hipotecada y pagarse con el producto.

2.2.2 La hipoteca es un derecho inmueble.

Tiene la hipoteca carácter inmueble cualquiera sea la naturaleza del crédito garantizado. La regla no es absoluta. Son susceptibles de hipoteca las naves que expresamente el artículo 825 del CCO reputa muebles.

2.2.3 La hipoteca es un derecho accesorio.

La hipoteca es siempre un derecho accesorio, destinado a asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Se sigue principalmente como consecuencia del carácter accesorio de la hipoteca su extinción por todas las causas que extinguen la obligación principal, conforme lo dispuesto en el primer inciso del artículo 2434 del CC. Por este mismo motivo el derecho de hipoteca pasa con el crédito a los sucesores a título universal o singular del acreedor, según lo dispuesto en el artículo 1906 del CC. La hipoteca puede garantizar toda clase de obligaciones, cualquiera sea su fuente; la obligación a que accede la hipoteca puede ser pura y simple o sujeta a modalidad, civil o puramente natural.

i) Relativa independencia de la hipoteca respecto de la obligación principal.

Por de pronto, la hipoteca puede garantizar obligaciones futuras, conforme al artículo 2413 que dispone que la hipoteca podrá otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba.

La persona que hipoteca un bien propio en garantía de una deuda ajena no se obliga personalmente a menos que así se estipule expresamente. La obligación principal, en tal caso, se separa de la hipoteca; las acciones personal y real deberán dirigirse contra distintas personas.

Aun se concibe la subsistencia de la hipoteca después de extinguida la obligación principal, pues las partes pueden convenir en una reserva de hipoteca, esto es, que la misma hipoteca con su primitiva fecha subsista para garantizar la nueva obligación.

ii) Hipoteca abstracta.

Se concibe perfectamente que la hipoteca tenga una vida totalmente independiente de una obligación principal. Puede constituirse por el propietario de un inmueble en previsión de sus

futuras necesidades de crédito, antes e independientemente de toda obligación para con un determinado acreedor.

iii) La finca permanece en poder del deudor.

Por la constitución del gravamen los inmuebles no dejan por eso de permanecer en poder del deudor, conforme al artículo 2407 del CC. Esta característica de la hipoteca constituye una positiva ventaja para el deudor pues éste conserva la facultad de gozar de la finca y aun de disponer de ella.

iv) Preferencia de la hipoteca.

La hipoteca otorga al acreedor la facultad de pagarse preferentemente con el producto de la realización de la finca hipotecada. El artículo 2470 del CC señala entre las causas de preferencia el privilegio y la hipoteca y el artículo 2477 del CC menciona la hipoteca entre los créditos de la tercera clase.

v) Indivisibilidad de la hipoteca.

Se traduce en que el inmueble, en su totalidad y cada una de sus partes, está afecto al pago integral de la deuda y de cada fracción de la misma. El artículo 2408 señala que: “La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella”.

Que el inmueble hipotecado y cada una de las partes en que se divida respondan del total de la obligación, implica una serie de consecuencias:

- i. Por de pronto, en caso de ser varios los deudores, el acreedor podrá dirigir la acción hipotecaria contra aquel de los codeudores que posea, en todo o parte, la finca hipotecada, conforme al primer número del artículo 1526.
- ii. En caso de dividirse la finca hipotecada, cada uno de los lotes o hijuelas queda gravado con el total de la deuda.
- iii. Si son varios los inmuebles hipotecados, el acreedor puede instar por la realización de cualquiera de ellos para conseguir el pago de su crédito, conforme el artículo 1365 del CC.

La extinción parcial del crédito no libera proporcionalmente el inmueble hipotecado. La extinción parcial de la deuda deja subsistente la hipoteca en su totalidad. El primer número del artículo 1526 señala: “El codeudor que ha pagado su parte de la deuda, no puede recobrar la prenda u obtener la cancelación de la hipoteca, ni aun en parte, mientras no se extinga el total de la deuda; y el acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito, no puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca, ni aun en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores”.

2.3 Clases de hipoteca.

Para el CC todas las hipotecas son convencionales. El CPC creó una hipoteca legal en el caso previsto en el artículo 662. La hipoteca judicial es desconocida en nuestra legislación.

2.3.1 Hipotecas legales y judiciales en el derecho francés.

Las hipotecas legales, como se dijo, son aquellas que la ley le atribuye de pleno derecho a ciertos créditos. Se las suele llamar tácitas. Las hipotecas legales garantizan los créditos de la mujer casada contra el marido sobre los bienes de éste, de los pupilos sobre los bienes de los guardadores, y del Estado sobre los bienes de sus recaudadores o administradores. Estas hipotecas legales tienen dos características: primero, son generales, esto es, recaen sobre todos los bienes inmuebles del deudor, inclusive los bienes futuros; y, segundo, son indeterminadas porque garantizan todos los créditos que la mujer llegue a tener contra el marido o el pupilo contra el guardador.

La hipoteca judicial tiene lugar en dos casos: primero, cuando se dicta una sentencia que condena a un deudor a cumplir una obligación; y, segundo, cuando el deudor voluntaria o forzadamente la reconoce en instrumento privado. Sus características particulares son las siguientes: primero, tiene lugar de pleno derecho; segundo, es general en cuanto a los bienes y comprende aun los bienes futuros; tercero, es especial en cuanto al crédito porque sólo se refiere al crédito reconocido; y, cuarto, su eficacia está condicionada a su inscripción.

2.3.2 Las hipotecas legales en la legislación anterior al CC.

De acuerdo con las leyes primitivas, la hipoteca era legal o convencional. La primera, establecida a favor del Fisco, de los establecimientos públicos de caridad o educación, de las mujeres casadas, de los pupilos, etc., era general y oculta. La segunda era especial y pública, porque requería inscripción. La hipoteca general tenía la curiosa peculiaridad de que no daba acción contra terceros poseedores y no era, por lo tanto, una verdadera hipoteca.

El CC abolió estas distinciones y en su Mensaje dice que no se conocen en ese proyecto otra especie de hipoteca que la antes llamada especial y de ahora en adelante simplemente hipoteca.

En lugar de la hipoteca legal, se estableció para esas personas un crédito privilegiado de cuarta clase, conforme al artículo 2481.

2.3.3 La hipoteca legal introducida por el Código de Procedimiento Civil.

El CPC ha creado una hipoteca legal con caracteres sui generis. En efecto, el artículo 660 establece que salvo acuerdo unánime de los interesados, todo comunero que reciba en adjudicación bienes por un valor que exceda al 80% de lo que le corresponda deberá pagar al contado el exceso. El artículo 662 añade: “En las adjudicaciones e propiedades raíces que se hagan los comuneros durante el juicio divisorio o en la sentencia final, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas, para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios, siempre que no se pague al contado el exceso a que se refiere el artículo 660”.

2.3.4 Caracteres de nuestra hipoteca legal.

Nuestra hipoteca legal presenta los siguientes caracteres:

- a) Es especial puesto que recae precisamente sobre el bien adjudicado.
- b) Es determinada porque garantízale alcance.
- c) Es pública porque requiere inscripción.
- d) Por lo demás, está sujeta a las mismas reglas que la hipoteca convencional.

2.4 Elementos de la hipoteca.

La hipoteca debe reunir, como es evidente, los elementos o requisitos de todo contrato. En relación al contrato será menester examinar: primero, la capacidad de los contratantes; segundo, las formas del contrato de hipoteca; tercero, las cosas que pueden hipotecarse; y, cuarto, las obligaciones que pueden garantizarse con hipoteca.

2.4.1 Personas que pueden hipotecar.

➡ Pueden hipotecar los capaces de enajenar.

El inciso primero del artículo 2114 del CC dispone: “No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación”. Conviene destacar que la capacidad para enajenar es diversa de la necesaria para obligarse y puede suceder, por lo mismo, que sea válida la obligación principal y nula la hipoteca porque el constituyente era capaz de obligarse pero no de enajenar.

➡ Forma en que los incapaces suplen su incapacidad para enajenar.

No debe entenderse que a los incapaces de enajenar les está absolutamente vedado hipotecar, sino que pueden hacerlo pero con sujeción a ciertas formalidades que en cada caso señala la ley:

- i. Los inmuebles del hijo de familia no pueden hipotecarse sin autorización judicial, aunque pertenezcan a su peculio profesional, conforme al artículo 254 del CC.
- ii. Análoga regla rige para los pupilos. Sus bienes no podrán hipotecarse sino previo decreto judicial, expedido por causa de utilidad o necesidad manifiesta, conforme lo dispuesto en el artículo 393 del CC.
- iii. Para enajenar los bienes raíces propios de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal, se requiere la voluntad de la mujer conforme al artículo 1754 del CC, la que debe ser específica y otorgada por escritura pública o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el

acto, o por mandato especial otorgado por escritura pública. No procede la autorización del juez en caso de negativa de la mujer.

2.4.2 Formas del contrato de hipoteca.

2.4.2.1 La hipoteca es un contrato solemne.

El inciso primero del artículo 2409 dispone: “La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser una misma escritura en que conste la hipoteca y el contrato al que accede”. El artículo 2410 añade: “La hipoteca deberá además ser inscrita en el Registro Conservatorio, sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha sino desde la inscripción”.

2.4.2.2 Rol que desempeña la inscripción en la hipoteca.

Una corriente de opinión pretende que la inscripción es solemnidad del contrato, al igual que la escritura pública. Otra opinión postula que la inscripción sólo desempeña el papel de tradición del derecho real de hipoteca. Esta opinión pareciera ser la correcta por los siguientes argumentos:

- i. De acuerdo al mensaje del CC la escritura pública perfecciona el contrato, pero el derecho real no adquiere vida sino con la inscripción.
- ii. El artículo 2419 del CC declara que la hipoteca de bienes futuros da derecho al acreedor para hacerla inscribir sobre los bienes que el deudor adquiera y a medida que los vaya adquiriendo. Si el contrato no produce ningún efecto sin la inscripción no se puede concebir que el acreedor tenga derecho a obtener que la inscripción se practique.

2.4.2.3 Contrato de hipoteca celebrado en el extranjero.

Sobre bienes situados en Chile, están sujetos a las mismas formas que si se otorgaran en el país. Desde luego, el contrato deberá otorgarse por escritura pública, con arreglo al artículo 18 del CC. El artículo 2411 del CC dispone: “Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero darán hipoteca sobre bienes situados en Chile, con tal que se inscriban en el competente registro”.

2.4.2.4 Enunciaciones de la inscripción.

No ha establecido la ley las enunciaciones de la escritura de hipoteca sino que el artículo 2432 del CC se refiere a las indicaciones de la inscripción. Pero la inscripción deberá hacerse, en general, con los datos que suministre el título. El artículo 82 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces establece que la falta absoluta de alguna de las designaciones legales sólo podrá subsanarse por escritura pública. La inscripción debe expresar:

- i. El nombre, apellido, domicilio y profesión del acreedor y del deudor, y de las personas que como mandatarias o representantes legales suyas requiera la inscripción.
- ii. La naturaleza y fecha del contrato a que accede la hipoteca y el archivo en que se encuentra. Si la hipoteca se ha constituido por acto separado, se expresará igualmente la fecha y el archivo en que se halle.

- iii. La situación de la finca y sus linderos.
- iv. La suma determinada a que se extienda la hipoteca, si las partes se limitan inequívocamente a una determinada cantidad.
- v. La fecha de la inscripción y la firma del Conservador.

Del artículo 2433 del CC se desprende que la fecha y la firma del Conservador son requisitos esenciales de la inscripción. La omisión de las restantes enunciaciones no anulará la inscripción siempre que por medio de ella o del contrato o contratos citados en ella pueda venirse en conocimiento de lo que en la inscripción se eche de menos.

2.4.3 Cosas que pueden hipotecarse.

De acuerdo al artículo 2418 del CC: “La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo o sobre naves”. También son hipotecables las pertenencias mineras conforme al artículo 217 del Código de Minería.

2.4.3.1 Inmuebles que se poseen en propiedad.

El artículo 2418 del CC no hace distinciones y, en consecuencia, puede hipotecarse la propiedad absoluta o fiduciaria, la propiedad plena o nuda.

La hipoteca de la propiedad fiduciaria está sujeta a reglas especiales. Para la constitución de hipotecas y otros gravámenes los bienes poseídos fiduciariamente se asimilan a los bienes de los pupilos y las facultades del propietario fiduciario a las del tutor o curador. Por consiguiente, la hipoteca debe constituirse previa autorización judicial por causa de utilidad o necesidad manifiesta y audiencia de las personas que tienen derecho a impetrar medidas conservativas, entre las que se cuenta, el fideicomisario. La omisión de estas formalidades trae como consecuencia que no será obligado el fideicomisario a reconocerlas.

Cuando se hipoteca la nuda propiedad cabe preguntarse si el gravamen se extiende a la propiedad plena, en caso de extinguirse el usufructo por la consolidación con la nuda propiedad. La hipoteca afecta a la propiedad plena. La nuda propiedad se ha incrementado con las facultades de uso y goce de que estaba separada y la hipoteca se extiende a los aumentos que experimente la cosa hipotecada.

2.4.3.2 Inmuebles que se poseen en usufructo.

El artículo 2418 del CC ha querido significar que es susceptible de hipoteca el derecho de usufructo que recae sobre bienes raíces. A pesar de su analogía con el usufructo no son hipotecables el derecho de uso sobre inmuebles y el derecho de habitación porque, además del silencio que el artículo guarda sobre su respecto, se trata de derechos intransmisibles, intransferibles e inembargables conforme a los artículos 819 y 2466 del CC.

La hipoteca constituida sobre un derecho de usufructo recae sobre el derecho mismo y no sobre los frutos que produzca la cosa. Se diferencian el usufructo de los frutos como el capital de los intereses que produce. El artículo 2423 establece que la hipoteca de un usufructo no se extiende a los frutos percibidos. El acreedor solo tiene el derecho, a falta de pago de su crédito, de hacer vender el usufructo mismo.

La hipoteca del usufructo es precaria; se extingue con la muerte del usufructuario y, en general, por las causas que ponen fin al derecho de usufructo. Sin embargo, el usufructo hipotecario no puede renunciarse en perjuicio de los acreedores conforme al artículo 803 del CC.

2.4.3.3 Hipoteca de naves.

Sólo son susceptibles de hipotecarse las naves mayores, esto es, las de más de cincuenta toneladas de registro grueso. Las naves menores sólo pueden constituirse en prenda. El artículo 866 del CCO dispone que las naves y artefactos navales mayores podrán ser gravados con hipoteca, siempre que se encuentren debidamente inscritos en los respectivos Registros de Matrícula de la República. En conformidad al artículo 868 del CCO la hipoteca naval deberá otorgarse por escritura pública, que podrá ser la misma del contrato a que acceda. El orden de inscripción en el Registro de Hipotecas, Gravámenes y Prohibiciones determinará el grado de preferencia de las hipotecas. Se puede dar en hipoteca también una nave o artefacto naval en construcción.

2.4.3.4 Hipoteca de concesiones mineras.

En conformidad al artículo 218 del Código de Minería, puede constituirse hipoteca sobre concesión minera cuyo título esté inscrito. El artículo 3 del Código de Minería dispone que se reputan inmuebles accesorios de la concesión, las construcciones, instalaciones y demás objetos destinados permanentemente por su dueño a la investigación, arranque y extracción de sustancias minerales. En conformidad al artículo 2423 del CC la hipoteca sobre minas y canteras no se extiende a los frutos percibidos ni a las sustancias minerales una vez separadas del suelo.

2.4.3.5 Hipoteca de bienes futuros.

Teóricamente es posible, pero el derecho de hipoteca requiere de la inscripción, y ésta es impracticable respecto de bienes futuros. Por este motivo, la hipoteca de bienes futuros sólo da al acreedor el derecho de recabar la correspondiente inscripción sobre los bienes que el constituyente adquiera en el porvenir y a medida que la adquisición se produzca. El artículo 2419 del CC dispone: La hipoteca de bienes futuros sólo da al acreedor el derecho de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo sucesivo y en la medida que los adquiera.

2.4.3.6 Hipoteca de cuota.

El artículo 2417 del CC establece que el comunero puede, antes de la división de la cosa común, hipotecar su cuota. Pero la existencia de cuota tiene una existencia precaria. Supone, para que sea eficaz, que se adjudiquen al comunero, en la división de la cosa común, bienes hipotecables. En caso contrario caducará la hipoteca. La eficacia de la hipoteca depende, pues, de los resultados de la partición.

El artículo 2417 del CC establece: “Verificada la división, la hipoteca afectará solamente los bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen si fueren hipotecables. Si no lo fueren, caducará la hipoteca”. La norma es consecuencia del efecto declarativo del acto de adjudicación.

Por lo tanto, si los bienes hipotecables de los que se hipotecó una cuota se han adjudicado a otro u otros comuneros, la hipoteca habrá sido constituida por alguien que no ha tenido nunca ningún derecho. Con todo, podrá subsistir la hipoteca sobre bienes adjudicados a otros partícipes si éstos consintieren en ello, y así constare por escritura pública de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria, conforme al artículo 2417 del CC. En la práctica, para ponerse a cubierto, el acreedor exigirá la aprobación anticipada de todos los copartícipes y su concurrencia al acto constitutivo de la hipoteca.

2.4.3.7 Hipoteca de bienes en que se tiene un derecho eventual, limitado o rescindible.

Obviamente la hipoteca tendrá los mismos caracteres que el derecho del constituyente sobre el bien gravado. Por este motivo, la hipoteca de un derecho de usufructo, derecho de duración necesariamente limitada por un plazo, estará afecta esa misma modalidad. Si el derecho del constituyente está limitado por una condición resolutoria, sin embargo, la resolución de su derecho no extinguirá la hipoteca sino con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1491 del CC, o sea, en perjuicio únicamente del acreedor hipotecario de mala fe.

Las hipotecas constituidas por el donatario cuya donación es resuelta, rescindida o revocada se sujetan a reglas especiales. Habrá acción para demandar la extinción de la hipoteca cuando:

- i. En la escritura pública inscrita de la donación se ha prohibido enajenar o se ha expresado la condición.
- ii. Antes de constituirse la hipoteca se ha notificado al interesado que se prepara una acción rescisoria, resolutoria o revocatoria contra el donatario.
- iii. Se ha constituido la hipoteca después de deducida la acción.

2.4.3.8 Hipoteca de cosa ajena.

Aunque se decida que es válida, es forzoso convenir que no otorga al acreedor el derecho de hipoteca. Como en la venta de cosa ajena, la tradición no dará al adquirente un derecho de que el tradente carecía. La jurisprudencia se inclina, con rara unanimidad, a considerar nula la hipoteca de cosa ajena. El artículo 2414 establece que no puede constituir hipoteca sobre sus bienes sino la persona que es capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para la enajenación. En otros términos, estaría prohibida la hipoteca sobre bienes que no pertenecen al constituyente.

Pero son muchas las razones para considerar válida la hipoteca de la cosa ajena:

- i. Por de pronto, no puede admitirse que el artículo 2414 contenga la prohibición de enajenar la cosa ajena.
- ii. La tradición hecha por quien no es dueño no adolece la nulidad, solamente no transfiere el derecho de que se trata.
- iii. No se divisa una razón plausible para adoptar, en relación con la hipoteca, una solución distinta de la adoptada expresamente para la prenda, conforme al artículo 2390.
- iv. El derecho de hipoteca se adquiere por prescripción, conforme a las mismas reglas que el dominio, conforme lo dispuesto en el artículo 2498.

Las consecuencias prácticas de esta discrepancia de opinión saltan a la vista. Considerada nula la hipoteca, de nulidad absoluta, no podría validarse ni aun por la adquisición posterior del dominio o la ratificación del propietario. Reputada válida, el acreedor adquirirá el derecho por la ratificación o adquisición posterior del dominio. Tal pareciera se la solución más acorde con los principios generales. El artículo 2417 suministra una prueba concluyente de que ésta es la solución correcta al señalar que la hipoteca constituida por el comunero a quien, a la postre, no se adjudican bienes hipotecables, subsiste si los otros partícipes consienten en ello. La hipoteca, pues, constituida por quien no es dueño, y se considera no haberlo sido jamás, tiene pleno valor si es ratificada por el dueño.

2.4.3.9 Especialidad de la hipoteca en relación con el bien hipotecado.

Es preciso que se conozca con exactitud, por una parte, cuales son los bienes gravados con la hipoteca y, por la otra, la naturaleza y monto de los créditos que garantiza. Esta doble especificación realiza lo que se llama especialidad de la hipoteca, que consiste en la indicación precisa del inmueble o inmuebles gravados. Nuestra legislación no conoce sino las hipotecas especiales; no existen hipotecas generales, esto es, que afecten todos los bienes del deudor, aun los bienes futuros. El artículo 2432 del CC consagra implícitamente el principio de la especialidad al señalar las menciones que debe contener la inscripción. En efecto, la inscripción debe individualizar la finca y sus linderos, en la forma que expresa la disposición legal.

2.4.4 Obligaciones susceptibles de caucionarse con hipoteca.

2.4.4.1 Todas las obligaciones son susceptibles de garantizarse con hipoteca.

La obligación a que accede la hipoteca puede ser civil o natural, conforme al artículo 1472 de CC. Pueden, asimismo, caucionarse con hipoteca obligaciones futuras. El inciso tercero del artículo 2413 previene que la hipoteca podrá otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que accede y correrá desde que se inscriba.

2.4.4.2 Especialidad de la hipoteca en cuanto al crédito hipotecario.

Consiste en la determinación de la naturaleza y monto de la obligación que la hipoteca garantiza. La especialidad en cuanto al crédito se justifica sobradamente. Por una parte, permite que el deudor se percate cabalmente del alcance de su obligación hipotecaria, y, por la otra, hace posible que los terceros conozcan con exactitud la medida en que se encuentra comprometido el crédito del deudor; que se formen un concepto claro de su verdadera solvencia.

2.4.4.3 Determinación del monto de la obligación garantizada.



¿Puede constituirse hipoteca en garantía de obligaciones de monto indeterminado?

Desde luego el artículo 2432 no menciona el monto de la obligación principal entre los requisitos de la inscripción, sino que su número cuarto dispone que la inscripción expresará la suma determinada a que se extienda la hipoteca en caso

de que se limite a una determinada suma. Podría ocurrir que la hipoteca se extienda a una suma determinada que deba indicarse en la inscripción, pero la obligación será monto indeterminado. Por otra parte, el artículo 2427 en caso de que la finca se pierda o deteriore en forma de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, permite que el acreedor impetre medidas conservativas si la deuda fuere líquida, condicional o indeterminada. En fin, en numerosos casos es necesariamente indeterminado el monto de la obligación, como por ejemplo, para el discernimiento de las guardas la ley exige que el tutor o curador rinda previamente fianza, que puede reemplazarse por una hipoteca suficiente conforme al artículo 376 del CC.

2.4.4.4 Límite legal de la hipoteca.

¿La indeterminación del monto de la deuda no es una formidable brecha al principio de la especialidad de la hipoteca?

El artículo 2431 tempera las consecuencias al principio de la especialidad de la hipoteca al señalar: “La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se exprese inequívocamente; pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado”. Para evitar una incertidumbre que puede ser gravemente perjudicial para su crédito, el deudor tendrá derecho a que se reduzca la hipoteca a dicho importe, o sea, el doble del valor conocido o presunto de la obligación caucionada. Obtenida la reducción, se hará a costa del deudor una nueva inscripción en virtud de la cual no valdrá la primera sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda.



2.4.4.5 Cláusula de garantía general hipotecaria.

Por ella se constituye hipoteca para garantizar determinadas obligaciones y, además, todas las que se contraigan en el futuro para con el banco. La validez de esta cláusula ha sido definitivamente reconocida por la Corte Suprema. Se basa en el artículo 2413 del CC que señala que la hipoteca puede constituirse antes que la obligación principal, y en el segundo número del artículo 2432 que establece que la inscripción debe expresar la fecha y naturaleza del contrato a que accede la hipoteca, pero la fecha y naturaleza del contrato solo será posible consignarlas en la inscripción cuando el contrato sea contemporáneo o anterior a la hipoteca.

2.4.5 Efectos de la Hipoteca.

Los efectos de la hipoteca son múltiples y deben enfocarse desde diversos puntos de vista, pues ellos dicen relación con: primero, la finca hipotecada; segundo, los derechos del constituyente de la hipoteca; y, tercero, los derechos del acreedor hipotecario.

a) Efectos con relación al inmueble hipotecado.

a.1 Cosas a que se extiende la hipoteca.

La hipoteca constituida sobre la finca se extiende a:

Los inmuebles por destinación. Son aquellos bienes muebles que se encuentran permanentemente destinados al uso, cultivo y beneficio del inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento, conforme al artículo 570 del CC. Aunque nada se exprese en el contrato y aunque la inscripción hipotecaria, por lo mismo, no los menciona, la hipoteca los alcanza. No sólo resultan gravados los inmuebles por destinación que existían en la finca al tiempo de constituirse la hipoteca, sino también los que adquieren este carácter con posterioridad. La ley no distingue. Enajenados estos bienes, dejan de estar al servicio del inmueble, recobran su natural condición de bienes muebles y no les alcanza la hipoteca.

El artículo 4 de la Ley No. 4097 señala que para constituir prenda agraria sobre los inmuebles por destinación, no será necesario el acuerdo del acreedor a cuyo favor exista constituida hipoteca sobre los inmuebles a que se hayan incorporado los bienes materia de la prenda, y el crédito prendario gozará de preferencia en estos bienes sobre el acreedor hipotecario.

Los aumentos y mejoras del inmueble. De acuerdo al artículo 2421 la hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. La hipoteca comprende todo aquello que incremente la cosa hipotecada, sea por causas naturales o a consecuencia de la industria humana. Si se hipoteca la nuda propiedad y luego se consolida con el usufructo, la hipoteca gravará la propiedad plena.

Las rentas de arrendamiento del mismo. La hipoteca, conforme lo dispuesto en el artículo 2422 del CC, se extiende también a las pensiones devengadas por el arrendamiento de los bienes hipotecados. El derecho del acreedor hipotecario sobre las rentas sólo se hace presente cuando, exigible la obligación principal, deduce su acción hipotecaria y embarga las rentas. Con tales rentas podrá hacerse pago y gozará en estos bienes de igual preferencia que respecto de la finca misma.

Las indemnizaciones debidas por los aseguradores. La hipoteca se extiende, asimismo, a la indemnización debida por los aseguradores, conforme al artículo 2422 del CC. El artículo 555 del CCO dispone: "La cosa que es materia del seguro es subrogada por la cantidad asegurada para los efectos de ejercitar sobre ésta los privilegios e hipotecas constituidas sobre aquella". Como consecuencia de esta subrogación real, la hipoteca recaerá sobre un bien mueble, como es la indemnización del seguro. Nada dice la ley acerca de si el derecho de hipoteca se extiende a otras indemnizaciones a que tenga derecho el propietario de la finca. La tendencia de la legislación moderna es hacer extensivo el privilegio a toda clase de indemnizaciones de perjuicios causados a la cosa afecta al gravamen real.

El precio de la expropiación del inmueble.

b) Efectos con respecto del constituyente.

b.1 Restricciones impuestas al dueño de la finca.

No puede disponer de ella en términos que menoscaben la garantía hipotecaria. Por otra parte, sus facultades de uso y goce han de ejercerse en forma que no se provoque una desvalorización y la consiguiente disminución de la eficacia de la caución.

b.2 Limitaciones a la facultad de disposición.

Conserva el dueño la facultad de disponer de la finca, en cuanto no perjudique el derecho del acreedor hipotecario. El artículo 2415 dispone: “El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario”.

Por el mismo motivo, puede constituir el dueño nuevas hipotecas; las hipotecas más antiguas prefieren a las más recientes conforme al artículo 2477 del CC. La constitución de otros derechos reales, como los usufructos, censos y servidumbres, menoscaban la garantía y perjudican al acreedor hipotecario. El dueño de la finca tiene limitado su derecho de dominio por lo que los derechos que constituya deben estar sujetos a la misma limitación.

El artículo 1368 plantea el caso de que el testador constituya un usufructo sobre un bien gravado con hipoteca. El usufructo constituido sobre la finca no afecta al acreedor hipotecario; éste ejercita su derecho sin considerar la existencia del usufructo. Por la inversa, la hipoteca afecta al usufructuario; éste debe pagar y, pagando, se subroga en los derechos del acreedor contra los herederos si la deuda era del testador y este no quiso expresamente gravarle con ella.

b.3 Limitación de las facultades de uso y goce.

Conserva el constituyente la tenencia de la cosa hipotecada y con ello las facultades de uso y goce, pero no le es lícito ejercitar estas facultades en forma arbitraria y perjudicial para el acreedor. El artículo 2427 del CC señala: “Si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente; y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o impetrar las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada”.

Es indiferente que la pérdida o deterioro se produzca por caso fortuito o por hecho o culpa del propietario. La pérdida o deterioro debe hacer insuficiente la garantía hipotecaria.

b.4 Derechos del acreedor en caso de pérdida o deterioro de la finca hipotecada.

La pérdida o deterioro de la finca, en forma que se torne insuficiente para la seguridad de la deuda, otorga al acreedor tres derechos:

- i. Puede el acreedor, en primer término, demandar que se mejore la hipoteca, o sea, que se le dé un suplemento de hipoteca o se le otorgue una nueva hipoteca.
- ii. Podrá igualmente solicitar el acreedor que se le otorgue otra seguridad equivalente.
- iii. A falta de cauciones tiene el acreedor un último camino, variable según las características de la obligación principal. Si la deuda es líquida y no condicional, puede el acreedor demandar el pago inmediato, aunque exista un plazo pendiente. En cambio, si la deuda es ilíquida, condicional o indeterminada, el acreedor podrá impetrar las medidas conservativas que el caso aconseje. La ley acá ha establecido un orden de prelación en el ejercicio de los derechos del acreedor. En consecuencia, a falta de un suplemento de hipoteca o de otra garantía adecuada, queda el acreedor en situación de demandar el pago inmediato o de adoptar medidas conservativas según el caso.

c) Efectos respecto del acreedor hipotecario.

Los derechos que la hipoteca otorga al acreedor hipotecario son, sustancialmente, los siguientes:

c.1 Derecho de venta.

El artículo 2424 del CC dispone: “El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda”.

La realización de la finca hipotecada no está sujeta a ninguna norma especial; se sujeta a las reglas generales que rigen la realización de los bienes inmuebles en el juicio ejecutivo. Los bienes se venden en pública subasta ante el juez que conoce del juicio ejecutivo o ante el tribunal en cuya jurisdicción se encuentren los bienes hipotecados, conforme al artículo 485 del CPC. Es preciso que los inmuebles se tasan; se tendrá como tasación el avalúo vigente, a menos que el ejecutado solicite que se practique una nueva tasación conforme al artículo 486 del CPC. El remate se verificará el día que el juez designe previa publicación de avisos conforme a los artículos 488 y 489 del CPC.

El artículo 2397 del CC otorga al acreedor prendario el derecho, a falta de posturas admisibles, para que la prenda se aprecie por peritos y se le adjudique, hasta la concurrencia de su crédito. Respecto del acreedor hipotecario es manifiesto que la disposición se encuentra derogada pues el artículo 499 del CPC autoriza al acreedor para pedir que la finca se saque nuevamente a remate con rebaja del mínimo, o que se le adjudique por los dos tercios de la tasación.

La aplicación a la hipoteca de la norma del artículo 2397 del CC importa que es igualmente nulo el pacto comisorio en este contrato. Las reglas sobre la realización de la finca hipotecada son de orden público, y el acreedor no puede disponer de ella o apropiársela por otros medios que los que indica la ley.

La hipoteca no excluye el derecho de prenda general del acreedor. El artículo 2425 del CC dispone: “El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica a la acción personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no le han sido hipotecados”. Pero como es lógico, cuando el acreedor persigue otros bienes del deudor no goza de la preferencia que la ley le confiere.

c.2 Derecho de persecución.

El artículo 2428 del CC dispone: “La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido”.

Se llama terceros poseedores a toda persona que detenta, a un título no precario, la finca gravada con hipoteca, sin que se haya obligado personalmente al pago de la obligación garantizada. El único vínculo que les liga al acreedor es la posesión de la cosa afecta al gravamen real. En verdad, el deudor es el inmueble.

Tercer poseedor, por de pronto, es la persona que adquiere la finca con el gravamen hipotecario ya constituido. En términos generales, el adquirente, para quedar obligado solo propter rem ha de ser un adquirente a título singular: comprador, donatario, legatario, etc. Si el inmueble ha sido adquirido a título de herencia el heredero será también un deudor personal como lo era el causante cuyo lugar ocupa, confundándose sus patrimonios. Por lo que toca al legatario, es menester indagar si el testador ha querido o no expresamente gravarle con la deuda garantizada

con la hipoteca. El legatario a quien el testador ha impuesto el pago de la deuda es, obviamente, un deudor personal. En caso contrario, es responsable propter rem y debe considerársele como un tercer poseedor conforme al artículo 1366 del CC.

La persona que constituye hipoteca sobre bien propio en garantía de una deuda ajena es, también, por regla general, un tercer poseedor. El inciso segundo del artículo 2414 del CC autoriza para dar en hipoteca bienes propios para caucionar obligaciones ajenas y añade que no habrá acción personal contra el dueño si éste no se ha sometido expresamente a ella. El primer inciso del artículo 2430 repite innecesariamente la misma regla: “En que hipoteca un inmueble suyo por una deuda ajena, no se entenderá obligado personalmente, si no se hubiere estipulado”. Se obligará personalmente cuando, además de hipotecar un bien suyo, se constituye en fiador, y en tal caso, la fianza se llama hipotecaria, conforme lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 2430 del CC.

La acción hipotecaria dirigida contra el tercer poseedor recibe una denominación especial: acción de desposeimiento. Si se trata de perseguir al deudor personal y el acreedor dispone de un título ejecutivo, cobrará ejecutivamente la obligación principal, embargará la finca hipotecada, procederá a su realización y se hará pago con el producto. En caso de que no disponga de un título ejecutivo, declarada previamente la existencia de la obligación, procederá en la forma sumariamente descrita.

Contra el tercer poseedor, que nada debe personalmente, el procedimiento es distinto; antes de llegar a la realización de la finca, es menester llevar a cabo algunas gestiones preliminares. El artículo 758 del CPC dispone que para hacer efectiva la hipoteca, cuando la finca gravada se posea por otro que el deudor personal, se notificará previamente al poseedor, señalándole un plazo de diez días para que pague la deuda o abandone ante el juzgado la propiedad hipotecaria. En el referido plazo de diez días el tercer poseedor podrá adoptar alguna de las siguientes actitudes: primero, pagar la deuda; segundo, abandonar la finca; y, tercero, guardar silencio, esto es, ni pagar ni abandonar. Propiamente, sólo en éste último caso tiene lugar el desposeimiento.

El tercer poseedor que paga la deuda satisface una obligación ajena y debe ser reembolsado por el deudor personal. El inciso segundo del artículo 2429 del CC establece que haciendo el pago se subroga en los derechos del acreedor en los mismos términos que el fiador. El artículo 1366 aplica esta norma al legatario que, en virtud de una hipoteca constituida sobre la finca gravada, paga una deuda con que el testador no ha querido expresamente gravarle.

El tercer poseedor está obligado en razón de la posesión de la finca hipotecada. Por lo mismo, cesará su responsabilidad desde que la abandona. El artículo 2426 del CC dispone: “El dueño de la finca perseguida por el acreedor hipotecario podrá abandonársela, y mientras no se haya consumado la adjudicación, podrá también recobrarla, pagando la cantidad a que fuere obligada la finca, y además las costas y gastos que este abandono hubiere causado al acreedor”. El abandono de la finca no importa el abandono del dominio de la misma. El tercer poseedor conserva el dominio y aun la posesión de la finca. Dos consecuencias se siguen de que el tercer poseedor conserve el dominio hasta la realización de la finca: primero, puede recobrarla mientras no se haya consumado la adjudicación; y, segundo, si el producto de la realización de la finca abandonada excede el monto de la deuda y gastos, el saldo pertenece al tercer poseedor.

Por último, podrá suceder que el tercer poseedor no pague ni abandone la finca. En este caso, conforme al inciso primero del artículo 759 del CPC, podrá desposeérsele de la propiedad hipotecada para hacer con ella pago al acreedor. Conforme al inciso segundo del artículo 759 del CPC, la acción de desposeimiento de someterá al procedimiento que corresponda según se la calidad del título en que se funde. Efectuado el desposeimiento, se procederá a la realización de la finca para hacerse pago al acreedor.

El tercer poseedor no goza del beneficio de excusión. El inciso primero del artículo 2429 establece que el tercer poseedor no tendrá derecho a que se persiga primero a los deudores personalmente obligados. La regla es aplicable a que hipoteca un inmueble propio en garantía de una deuda ajena.

El tercer poseedor que hace abandono de la finca o es desposeído, debe ser cumplidamente indemnizado por el deudor personal. El inciso tercero del artículo 2429 consagra: “Si fuere desposeído de la finca o la abandonare, será plenamente indemnizado por el deudor, con inclusión de las mejoras que haya hecho en ella”.

Para concluir, debe señalarse que no todo adquirente de una finca gravada con hipoteca está expuesto al derecho de persecución. No tiene lugar el derecho de persecución:

- i. Contra el tercero que adquirió la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez.
- ii. Contra el adquirente de la finca a consecuencia de una expropiación por causa de utilidad pública.

c.3 Derecho de preferencia.

Las causas de preferencia, según el artículo 2470 del CC, son el privilegio y la hipoteca. El derecho de preferencia, junto con el derecho de persecución, otorgan a la hipoteca su extraordinaria eficacia como garantía. La hipoteca pertenece a la tercera clase de créditos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2477. La preferencia de que goza la hipoteca tiene los siguientes caracteres: primero, la preferencia es especial, recae solamente sobre la finca hipotecada y el acreedor no goza de ninguna preferencia cuando persigue otros bienes del deudor y, en caso de ser insuficientes los bienes hipotecados, el saldo insoluto pasa a la quinta clase de créditos; y, segundo, la preferencia pasa contra terceros, como consecuencia del carácter real del derecho de hipoteca.

La preferencia de la hipoteca se hace efectiva, en verdad, sobre el producto de la realización de la finca. La preferencia se extiende asimismo:

- i. A las indemnizaciones del seguro.
- ii. Al valor de la expropiación.
- iii. A las rentas de arrendamiento de la finca y, en general, a todos los bienes a que se extiende la hipoteca de acuerdo con los artículos 2420 a 2422 del CC.

El artículo 2415 del CC establece que el dueño de los bienes hipotecados, no obstante cualquiera estipulación en contrario, puede constituir nuevas hipotecas. Ello es posible porque no lesiona en absoluto los intereses de los acreedores hipotecarios anteriores. El inciso segundo del artículo 2477 del CC dispone que las diversas hipotecas prefieren, unas a otras, en el orden de sus fechas. La fecha de la hipoteca será siempre la de su correspondiente inscripción, conforme lo señalado

en el artículo 2412 del CC. Las hipotecas de la misma fecha preferirán en el orden de las inscripciones.

Por último, la posposición de la hipoteca es el acto por el cual el acreedor hipotecario consiente en que se prefiera a la suya una hipoteca constituida con posterioridad. Nada impide que el acreedor renuncie a la prioridad que la ley le otorga de pagarse de su crédito y acepte voluntariamente desmejorar su situación.

2.4.6 Extinción de la hipoteca.

2.4.6.1 Formas como se extingue la hipoteca.

La hipoteca, como la prenda y la fianza, se extingue por vía principal o consecuencial. Por vía de consecuencia se extingue la hipoteca cada vez que se extinga, por los modos generales de extinguirse las obligaciones, la obligación principal. El inciso primero del artículo 2434 del CC dispone: “La hipoteca se extingue junto con la obligación principal”. Interesa solamente considerar las causas de extinción de la hipoteca que dejan subsistente la obligación caucionada.

2.4.6.2 Resolución del derecho del constituyente.

El inciso segundo del artículo 2434 del CC previene que la hipoteca se extingue por la resolución del derecho del que la constituyó. El artículo 2416 dice que la hipoteca de una cosa en la que se tiene un derecho eventual, limitado o rescindible, se entiende hecha con las condiciones o limitaciones a que el derecho está sometido. Sujeto el derecho a una condición resolutoria, se estará a lo dispuesto en el artículo 1491. En otros términos, se extinguirá la hipoteca siempre que la condición resolutoria conste en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública.

2.4.6.3 Evento de la condición resolutoria o llegada del plazo.

La hipoteca misma puede estar sujeta a modalidades. El artículo 2413 dispone: “La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquier condición, y desde o hasta cierto día”. Como es natural, la hipoteca se extingue por el evento de la condición resolutoria, conforme al inciso segundo del artículo 2434, y por la llegada del día hasta el cual fue constituida, conforme lo señalado en el inciso tercero del artículo 2434 del CC.

2.4.6.4 Prórroga del plazo.

La prórroga del plazo extingue la hipoteca constituida por terceros. El artículo 1649 del CC establece que esta prórroga no importa novación, pero extingue las hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor salvo que el dueño de los bienes hipotecados acceda expresamente a la ampliación.

2.4.6.5 Confusión.

El artículo 2406 del CC establece que la prenda se extingue cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor a cualquier título. Es manifiesto, pese al silencio de la ley, que la hipoteca se extingue igualmente por la confusión de las calidades de dueño de la finca y de

acreedor hipotecario. Sin embargo, aún en nuestro sistema, se da el caso que una persona sea acreedor hipotecario de su propia finca. El número segundo del artículo 1610 del CC establece que opera una subrogación legal a favor del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. Por obra de la subrogación, el subrogado adquirirá el derecho de hipoteca sobre la finca, hipoteca que se pondrá de manifiesto cuando otros acreedores hipotecarios persigan el inmueble, con el objeto de facilitar y asegurar al adquirente el reembolso de lo pagado.

2.4.6.6 Expropiación por causa de utilidad pública.

El expropiado adquiere el inmueble libre de gravámenes y el acreedor hipotecario, como se ha dicho, hará valer su derecho sobre el precio de la expropiación, conforme lo señalado en el artículo 924 del CPC. La indemnización subroga al bien expropiado para todos los efectos legales. De esta manera, la hipoteca subsiste, y el acreedor hipotecario podrá hacer efectivo su derecho de persecución sobre el monto de la indemnización, tal como si se tratara de la finca misma.

2.4.6.7 Cancelación del acreedor.

Se extingue también la hipoteca por la renuncia del acreedor; renuncia que debe constar por escritura pública y anotarse al margen de la inscripción hipotecaria, conforme lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2434 del CC.

2.4.6.8 Purga de la hipoteca.

La hipoteca se extingue también en el caso previsto en el artículo 2428 del CC. La disposición establece que el acreedor carece del derecho de persecución contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez. Cesa el derecho de persecución, se extingue la hipoteca, la hipoteca queda purgada, cuando la finca se vende en las condiciones que señala el artículo 2428 y que son las siguientes:

- i. Que la venta se haga en pública subasta, ordenada por el juez.
- ii. Que se cite personalmente a los acreedores hipotecarios.
- iii. Que la subasta se verifique transcurrido el término de emplazamiento.

El **primer requisito** es que la venta de la finca debe verificarse en pública subasta y esta deberá haber sido ordenada por el juez. En otros términos, debe tratarse de una venta forzada como consecuencia de un litigio. No quedan purgadas las hipotecas si la venta es voluntaria, aunque se verifique ante el juez en subasta pública.

El **segundo requisito** es la citación personal de los acreedores hipotecarios. La citación tiene por objeto que los acreedores adopten las medidas que juzguen adecuadas para que la finca se realice en el mejor precio posible y el producto alcance para satisfacerlos en sus créditos. El inciso tercero del artículo 2428 del CC previene que la subasta debe efectuarse con citación personal de los acreedores, o sea, los acreedores deben ser notificados personalmente conforme las normas del CPC.

El **tercer requisito** es el transcurso del término de emplazamiento. El artículo 2428 del CC establece que la notificación a los acreedores hipotecarios debe hacerse en el término de emplazamiento. La notificación debe lógicamente hacerse antes del remate y con una anticipación adecuada para que cumpla su objetivo. La subasta debe efectuarse una vez transcurrido el término de emplazamiento. En otras palabras, un término igual al de emplazamiento debe transcurrir entre la citación y la subasta. Se ha entendido que el término de emplazamiento a que se refiere es el del juicio ordinario.

El precio de la subasta debe consignarse a la orden del juez por cuya orden se efectuó. Con los fondos consignados los acreedores hipotecarios serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que corresponda, conforme lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 2428 del CC.

Cumplidos los requisitos apuntados, se extinguirán las hipotecas, aunque no hayan conseguido pagarse todos los acreedores hipotecarios con el producto de la subasta.

Las consecuencias que trae consigo la falta de citación oportuna de los acreedores hipotecarios es que subsisten las hipotecas de los acreedores no citados y su derecho, por lo tanto, de perseguir la finca en poder del tercero adquirente. Para este caso rige, precisamente, la regla establecida en el segundo número del artículo 1610 del CC que dispone que el subastador se subroga en los derechos de los acreedores hipotecarios a quienes pagó; rematada nuevamente la finca por el tercer acreedor hipotecario, se pagará el subastador preferentemente y, de este modo, aunque pierda la finca, no perderá el precio pagado por ella.

El artículo 492 del CPC ha modificado ligeramente al artículo 2428 del CC al disponer: “Si por un acreedor hipotecario de grado posterior se persigue una finca hipotecada contra el deudor personal que la posea, el acreedor o los acreedores de grado preferente, citados conforme al artículo 2428 del CC, podrán, o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate según sus grados, o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus créditos no estén devengados”. Consiste la modificación en que los acreedores de grado preferente al actor tienen la facultad de optar entre pagarse de sus créditos con el producto de la subasta o conservar su derecho de hipoteca. Esta facultad no compete a los acreedores de grado posterior a quienes sólo cabe pagarse con el precio del remate, si fuere suficiente para ello. El inciso segundo del artículo 492 del CPC añade: “No diciendo nada, en el término de emplazamiento, se entenderá que optan por pagarse sobre el precio de la subasta”.

Por lo tanto, dos condiciones son indispensables para que los acreedores hipotecarios de grado preferente puedan ejercitar la opción:

- i. En primer término, es menester que se persiga la finca contra el deudor personal que la posea. Por lo tanto, no tiene la opción cabida si se persigue la finca contra un tercer poseedor.
- ii. En segundo lugar, es preciso que el crédito sea exigible. En otros términos, el acreedor cuyo crédito es exigible sólo puede exigir el pago con el producto del remate.

Tema 3: La Fianza.

3.1 Concepto.

El artículo 2335 del CC define el contrato de fianza: **“La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple”.**



La fianza no es una obligación sino que un contrato accesorio que se celebra entre acreedor y fiador. La necesidad en que se encuentra el fiador de satisfacer la obligación, total o parcialmente, en subsidio del deudor principal, es el efecto propio y fundamental de este contrato. El artículo 2336 parece contradecir abiertamente que la fianza es siempre un contrato y justificar que el CC haya preferido calificarla de obligación accesoria. Dispone el artículo 2336: “La fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley, la tercera por decreto del juez”. Por tanto, sería un contrato solamente la fianza convencional. Pero no existe tal contradicción; la fianza es siempre un contrato. Puede ser convencional, legal o judicial el origen de la obligación de procurarse un fiador; el deudor puede resultar obligado a proporcionar un fiador como consecuencia de una convención, de un mandato de la ley o de una orden judicial.

3.2 Caracteres del contrato de fianza.

El contrato de fianza es generalmente consensual, unilateral, gratuito y accesorio.

3.2.1 La fianza es un contrato consensual.

Se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Sin embargo, el contrato de fianza puede ser solemne en los siguientes casos:

- i. La fianza que deben rendir los tutores y curadores para que se discierna el cargo debe constituirse por escritura pública conforme al artículo 855 del CPC.
- ii. La fianza mercantil debe otorgarse por escrito, conforme al artículo 820 del CCO.
- iii. El aval, especie de fianza, por medio de la cual un tercero se obliga solidariamente al pago de una letra de cambio o pagaré también presenta características peculiares. La sola firma en el anverso de la letra o pagaré, o de su hoja de prolongación, en su caso, constituye aval, a menos que esa firma sea del girador, el que emite la letra, o del librado, el obligado al pago, conforme a lo señalado en el artículo 46 de la Ley No. 18.092.
- iv. La fianza que se rinda para garantizar la libertad provisional de los procesados debe constituirse por escritura pública, o por un acta firmada ante el juez por el procesado y fiador, conforme lo señalado en el artículo 369 del CPP.

3.2.2 La fianza es un contrato unilateral.

Porque sólo una parte se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna. De la propia definición del artículo 2335 del CC se desprende que quien se obliga es el fiador para con el acreedor a cumplir la obligación, en todo o en parte, si no la cumple el principal deudor. El deudor es extraño al contrato. Así se explica la regla del artículo 2345 que señala: “Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia y contra la voluntad del principal deudor”. La fianza sería bilateral si el acreedor se obligara a pagar una remuneración al fiador por el servicio que le presta, pero en tal caso la fianza degenera en otro contrato distinto: el contrato de seguro.

3.2.3 La fianza es un contrato gratuito.

Tiene el contrato por objeto sólo la utilidad de una de las partes, sufriendo el gravamen únicamente el fiador. Se dice que la gratuidad no es de la esencia del contrato de fianza. El artículo 2341 del CC dispone: “El fiador puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio que le presta”. Aunque gratuita, la fianza no importa una donación. El artículo 1397 del CC dispone: “No hace donación a un tercero el que a favor de éste se constituye fiador. Tampoco dona el que exonera de sus obligaciones al fiador, o remite una prenda o hipoteca, mientras está solvente el deudor”. Pese a su carácter gratuito y que no reporta ningún beneficio, el fiador responde de culpa leve. El artículo 2351 del CC señala: “El fiador es responsable hasta de la culpa leve en todas las prestaciones a que fuere obligado”.

3.2.4 La fianza es un contrato accesorio.

Es la característica más saliente de la fianza. Su finalidad es procurar al acreedor una garantía y supone necesariamente una obligación principal a que acceda. La suerte de la fianza está íntimamente ligada a la suerte de la obligación principal. Se siguen de este carácter accesorio de la fianza numerosas e importante consecuencias:

- i. Extinguida la obligación principal se extingue igualmente la fianza conforme al artículo 2381 del CC. La regla sufre excepción cuando la nulidad proviene de la relativa incapacidad del deudor principal. Desde luego, conforme al artículo 2354 el fiador no puede invocar la nulidad. El legislador considera que el fiador que cauciona la deuda de un incapaz entiende precisamente garantizar al acreedor del riesgo a que le expone la incapacidad del deudor.
- ii. Otra consecuencia importante es la facultad del fiador de oponer al acreedor todas las excepciones que derivan de la naturaleza de la obligación principal.
- iii. Una tercera consecuencia del carácter accesorio de la fianza es que la obligación del fiador no puede ser más gravosa que la del deudor principal.

3.3 El fiador no puede obligarse a más que el deudor principal.

El artículo 2343 previene que: “El fiador no puede obligarse a más de lo que el deudor principal, pero puede obligarse a menos”. El artículo 2344 añade: “El fiador no puede obligarse en términos más gravosos que el principal deudor, pero puede obligarse en términos menos gravosos”.

La obligación del fiador puede ser mayor o más gravosa en cuanto a la cantidad o cuantía, al tiempo, al lugar, a la condición, al modo, a la pena impuesta en caso de incumplimiento, conforme se señala:

- i. La obligación del fiador excederá relativamente a la cuantía si se obliga a pagar una suma mayor que el deudor; si la obligación principal no produce intereses y el fiador se obliga a pagarlo; o si debe pagar intereses más elevados que el deudor.
- ii. En cuanto al tiempo, la obligación del fiador será más gravosa si se obliga pura y simplemente y la obligación del deudor es a plazo o si el plazo para la obligación del fiador es menor.
- iii. En lo tocante al lugar, la obligación del fiador será más gravosa si, mientras el deudor se obligó a pagar en su domicilio, el fiador debe hacerlo en el domicilio del acreedor.
- iv. Será más gravosa en cuanto a la condición si la obligación del deudor es condicional y pura y simple la obligación del fiador.
- v. Más gravosa en cuanto al modo es la obligación del fiador que se obliga a pagar en un determinado tipo de moneda mientras que el deudor no tiene tal limitación.
- vi. Por fin, en cuanto a la pena, la obligación del fiador será más gravosa si se sujeta a una pena que no afecta al deudor o al pago de una pena superior.

El artículo 2344 dispone: “La obligación del fiador no puede ser más gravosa no sólo con respecto a la cuantía sino al tiempo, al lugar, a la condición o al modo del pago, o a la pena impuesta por la inejecución del contrato a que accede la fianza”. La fianza que, en el hecho es más gravosa que la obligación principal, no adolece de nulidad; la ley ha señalado una sanción diversa: la fianza que excede bajo cualquiera de los respectos indicados a la obligación del deudor, deberá reducirse a los términos de la obligación principal, conforme al inciso tercero del artículo 2344 del CC. El inciso cuarto de la norma citada concluye que en caso de duda se adoptará la interpretación más favorable a la conformidad de las dos obligaciones principal y accesoria.

3.3.1 El fiador puede obligarse en términos más eficaces.

El inciso segundo del artículo 2344 del CC dispone: “Podrá, sin embargo, obligarse de un modo más eficaz, por ejemplo, con una hipoteca, aunque la obligación principal no la tenga”.

3.4 Modalidades de la fianza.

El artículo 2340 del CC dispone: “La fianza puede otorgarse hasta o desde cierto día, o bajo condición suspensiva o resolutoria”. La obligación del fiador estará sujeta a modalidad, además, cuando lo esté la del principal obligado. Las modalidades de la obligación principal pasan a la fianza como consecuencia de que el fiador no puede obligarse en forma más gravosa que el deudor.

3.5 Fianza a favor del fiador.

El inciso segundo del artículo 2335 del CC dispone: “La fianza puede constituirse no sólo a favor del deudor principal, sino de otro fiador”. En general, el subfiador está sometido a las mismas disposiciones que el fiador; a su respecto, éste es considerado como deudor principal.

3.6 Clasificaciones de la Fianza.

La fianza puede ser legal, judicial y convencional; personal e hipotecaria o prendaria; limitada o ilimitada; simple y solidaria.

3.6.1 Fianza convencional, legal y judicial.

No se refieren al origen de la obligación del fiador, que es invariablemente convencional, sino al origen de la obligación del deudor principal de rendir fianza.

Como ejemplos de fianza legal pueden citarse la que están obligados a rendir los poseedores provisorios conforme al artículo 89, los tutores y curadores conforme a los artículos 374 y 376, y los usufructuarios conforme a los artículos 775 y 777 del CC. Por lo que toca a la fianza legal, debe dejarse claro que el juez, para ordenar su constitución, debe apoyarse en un texto expreso de la ley. Tal es el caso de los propietarios fiduciarios conforme al artículo 775, del dueño de la obra ruinosa conforme al artículo 932, y de los albaceas conforme a los artículos 1292 y 1313 del CC.

La fianza judicial y la legal se rigen, en general, por las mismas reglas que la convencional. El artículo 2336 dispone: “La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en cuanto la ley que la exige o el Código de Enjuiciamiento dispongan otra cosa”. Dos diferencias importantes se pueden anotar:

- i. Si la fianza es legal o judicial puede sustituirse a ella una prenda o hipoteca, aun contra la voluntad del acreedor, conforme lo dispuesto en el artículo 2337 del CC. Ello no ocurre en la fianza convencional contra la voluntad del acreedor.
- ii. Cuando la fianza es exigida por el juez, el fiador no goza del beneficio de excusión, conforme lo dispuesto en el cuarto número del artículo 2358 del CC.

3.6.2 Fianza personal e hipotecaria o prendaria.

Fianza personal es aquella en que el fiador obliga a todos sus bienes, indistintamente, al cumplimiento de la obligación. La fianza hipotecaria o prendaria es aquella en que, además, constituye una prenda o hipoteca. En la fianza personal, el acreedor dispone de dos acciones personales, contra el deudor personal y contra el fiador, para conseguir el pago de su crédito en los bienes de uno y otro, con excepción de los inembargables. Cuando la fianza es hipotecaria o prendaria dispone el acreedor, todavía, de una acción real contra el fiador, que le permite pagarse preferentemente con los bienes hipotecados o empeñados.

Si el acreedor ejercita contra el fiador la acción real, debe tenerse presente:

- i. Que no puede oponer el fiador el beneficio de excusión conforme a lo señalado en el inciso primero del artículo 2429 y el inciso segundo del artículo 2430 del CC.
- ii. Que la indivisibilidad de la prenda y de la hipoteca impedirá igualmente a los fiadores invocar el beneficio de división conforme al primer número del artículo 1526 y a los artículos 2405 y 2408 del CC.

3.6.3 Fianza limitada e ilimitada.

La fianza es definida o limitada cuando en el contrato se determinan las obligaciones concretas que el fiador toma sobre sí o cuando se limita a una cantidad fija de dinero. La fianza es indefinida o ilimitada cuando no se determinan las obligaciones que garantízale fiador o la cuantía de su responsabilidad.

Cuando la fianza se limita en cuanto a la cantidad, lógicamente responde el fiador sólo hasta la suma convenida y no más, conforme lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2367 del CC. Si la fianza es ilimitada, sin embargo, tiene un límite; no se extiende a más que la obligación principal conforme lo señalado en los artículos 2343 y 2344 del CC. El artículo 2347 del CC dispone: “La fianza no se presume, ni debe extenderse a más que el tenor de lo expresado; pero se supone comprender todos los accesorios de la deuda, como los intereses, las costas judiciales del primer requerimiento hecho al principal deudor, las de intimación que en consecuencia se hiciere al fiador, y todas las posteriores a esta intimación, pero no las causadas en el tiempo intermedio entre el primer requerimiento y la intimación antedicha”. El fiador, en consecuencia, está obligado a:

- i. El pago del capital de la obligación.
- ii. El pago de los intereses.
- iii. El pago de las costas.

3.6.4 Fianza simple y solidaria.

La estipulación de la solidaridad en la fianza produce como efecto fundamental privar al fiador del beneficio de excusión. Tal estipulación es, en efecto, una enérgica renuncia de tal beneficio. En caso de ser varios los fiadores, como consecuencia de la solidaridad, quedarán igualmente privados del beneficio de división. Suele estipularse que una persona se obligue como fiador y codeudor solidario; en tal evento regirán las reglas de las obligaciones solidarias. La estipulación no es ociosa sin embargo, porque deja claramente establecida, de antemano, la falta de interés

del codeudor en la obligación. Frente al acreedor es un codeudor solidario; ante los codeudores es un fiador.

3.7 Requisitos del Contrato de Fianza.

La fianza debe reunir los requisitos de todo contrato: consentimiento, capacidad, objeto y causa. Como consecuencia de su carácter accesorio, la fianza requiere, además, la existencia de una obligación principal.

3.7.1 El consentimiento en la fianza.

La fianza es regularmente un contrato consensual, que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. La ley no se contenta, sin embargo, con un consentimiento tácito. El artículo 2347 establece: “La fianza no se presume, ni debe extenderse a más que el tenor de lo expreso”. La ley ha exigido que el consentimiento del fiador debe ser expreso. La fianza no puede resultar de un simple consejo o recomendación, de ningún acto ejecutado por el fiador, por significativo que sea de su intención de obligarse como tal. En cuanto a la prueba la fianza está sujeta a las reglas generales.

3.7.2 Capacidad del fiador.

El inciso primero del artículo 2350 del CC señala: “El obligado a prestar fianza debe dar un fiador capaz de obligarse como tal”.

Para obligarse el pupilo como fiador, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 440 del CC, se requiere: **primero**, que medie una previa autorización judicial; **segundo**, que la fianza se otorgue a favor del cónyuge, de un descendiente o ascendiente legítimo o natural; y, **tercero**, que se invoque una causa urgente y grave.

La fianza, como los demás actos que otorgue el hijo de familia, deben ser autorizados o ratificados por el padre conforme lo dispuesto en el artículo 254 del CC. La fianza obliga directamente al padre y subsidiariamente al hijo, hasta la concurrencia del beneficio que reporte. La responsabilidad del hijo es remota porque la fianza es por su naturaleza gratuita.

La mujer casada en régimen de sociedad conyugal necesita autorización del marido o del juez en subsidio, conforme lo dispuesto en el artículo 1751 del CC. Hoy en día la ley impone también limitaciones respecto del marido. El artículo 1749 del CC dispone que si el marido se constituye avalista, codeudor solidario, fiador u otorga cualquier otra caución respecto de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará a sus bienes propios. Para obligar a los bienes de la sociedad conyugal necesitará autorización de la mujer, la que deberá ser específica y por escrito, o por escritura pública si el acto exigiera tal solemnidad o interviniendo expresa y directamente en el mismo. Podrá prestarse también por mandato especial. La autorización puede ser suplida por el juez, con conocimiento de causa y citación de la mujer, si ésta se negare sin justo motivo. También podrá ser suplida por el juez en caso de impedimento de la mujer. Pero no podrá suplirse dicha autorización si la mujer se opusiere a la donación de los bienes sociales.

En el régimen de participación en los gananciales, ninguno de los cónyuges podrá otorgar cauciones personales a obligaciones de terceros sin el consentimiento del otro cónyuge.

La mujer separada de bienes o la divorciada a perpetuidad, puede obligarse como fiadora sin limitaciones.

3.7.3 Objeto de la fianza.

La obligación principal puede ser de dar, hacer o no hacer, pero la obligación del fiador será siempre de dar y, todavía, de dar una suma de dinero. El inciso segundo del artículo 2343 señala que el fiador puede obligarse a pagar una suma de dinero en lugar de otra cosa de igual o mayor valor; y añade que la obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma de dinero, no constituye fianza. El inciso tercero del artículo 2343 dispone: “Afianzando un hecho ajeno, positivo o negativo, se afianza sólo la indemnización en que el hecho por su inejecución se resuelva”.

3.7.4 La causa en la fianza.

En la fianza gratuita la causa de la obligación del fiador se encuentra en su liberalidad, en su deseo de servir; en la fianza remunerada, la causa se encontraría en la remuneración ofrecida al fiador. Como la fianza es un contrato que se celebra entre el acreedor y el fiador, la causa ofrecería la curiosa peculiaridad de no formar parte del acuerdo de voluntades de los contratantes, acreedor y fiador, y constituiría un elemento extraño al contrato. La obligación del fiador para con el acreedor se encontraría separada de su causa; sería una obligación abstracta.

3.7.5 Existencia de una obligación principal.

Como consecuencia de su carácter accesorio, la fianza requiere de una obligación principal a que acceda. La obligación a que accede la fianza puede ser civil o natural, conforme al artículo 2338 del CC. Tiene la fianza de obligaciones naturales la peculiaridad de que el fiador no goza del beneficio de excusión ni del beneficio de reembolso. La obligación garantizada puede ser pura y simple o sujeta a modalidad de acuerdo al inciso primero del artículo 2339 del CC. Las modalidades de la obligación principal se comunican a la fianza. Se puede, en fin, afianzar obligaciones presentes y futuras.

3.7.6 Fianza de obligaciones futuras.

El artículo 2339 autoriza la constitución de una fianza para garantía de una obligación futura y reglamenta sus consecuencias. De este modo, la fianza puede otorgarse con anterioridad a la constitución de la obligación principal, pues lo que caracteriza el contrato accesorio no es que no pueda existir sin una obligación principal, sino que no pueda subsistir sin ella. La fianza de obligaciones futuras otorga al que afianza la facultad de retractarse mientras no llegue a existir la obligación principal. Pero la facultad de retractarse del fiador tiene una importante limitación pues pese a la retractación queda responsable al acreedor y a terceros de buena fe. En suma, para liberarse de toda responsabilidad, el fiador debe dar aviso de su retractación.

3.8 Obligación de rendir fianza y calidades de fiador.

3.8.1 Personas obligadas a rendir fianza.

Nadie puede estar obligado jamás a constituirse en fiador si no consiente en ello. Pero el deudor suele verse en la necesidad de procurar un fiador a su acreedor, a petición de éste, como en los siguientes casos:

- i. Está obligado a rendir fianza el deudor que lo haya estipulado, conforme al primer número del artículo 2348 del CC.
- ii. Debe rendir fianza el deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación, conforme lo señalado en el segundo número del artículo 2348 del CC.
- iii. Es obligado a rendir fianza el deudor de quien haya motivo de temer que se ausente del territorio nacional con ánimo de establecerse en otra parte, mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones, de acuerdo al tercer número del artículo 2348 del CC.
- iv. Por último, el artículo 2349 del CC dispone que está obligado a rendir fianza el deudor cuyo fiador se torna insolvente.

3.8.2 Calidades que debe reunir el fiador.

Las calidades que debe reunir el fiador se refieren a su capacidad, a su solvencia y a su domicilio. El artículo 2350 del CC dispone: “El obligado a prestar fianza debe dar un fiador capaz de obligarse como tal, que tenga bienes más que suficientes para hacerla efectiva, y que esté domiciliado o elija domicilio dentro de la jurisdicción de la respectiva Corte de Apelaciones”.

3.8.3 Solvencia del fiador.

La solvencia consiste, de acuerdo al artículo 2350, en que tenga bienes más que suficientes para hacer efectiva la fianza. El inciso segundo de dicha disposición establece: “Para calificar la suficiencia de los bienes, sólo se tomarán en cuenta los inmuebles, excepto en materia comercial o cuando la deuda afianzada es módica”. Pero no todos los inmuebles deben ser tomados en cuenta, sino que deben tenerse presente las siguientes reglas:

- i. No se tomarán en cuenta los inmuebles situados fuera del territorio del Estado.
- ii. No se considerarán, tampoco, los bienes sujetos a hipotecas gravosas.
- iii. Se excluyen igualmente los inmuebles sujetos a condiciones resolutorias.
- iv. No se tomarán en consideración los inmuebles embargados.
- v. Tampoco se tomarán en cuenta los inmuebles litigiosos.
- vi. El artículo 2350 concluye: “Si el fiador estuviere recargado de deudas que pongan en peligro aun los inmuebles no hipotecados en ellas, tampoco se contarán éstos.

3.8.4 Domicilio del fiador.

El fiador debe tener o señalar domicilio dentro del territorio jurisdiccional de la respectiva Corte de Apelaciones. El domicilio está íntimamente ligado con el lugar en que debe cumplirse la obligación.

3.9 Efectos de la Fianza.

Los efectos de la fianza deben enfocarse desde un triple punto de vista: primero, los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador; segundo, los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor; y, tercero, los efectos de la fianza entre los cofiadores.

3.9.1 Efectos entre acreedor y fiador.

Los efectos de la fianza anteriores a la reconvención del fiador se refieren a la facultad de éste de pagar la deuda y de exigir que el acreedor, desde que se haga exigible la obligación, proceda en contra del deudor principal. Los efectos posteriores dicen relación con los medios de defensa con que cuenta el fiador.

a) Facultad del fiador de anticiparse a pagar la deuda.

El artículo 2353 del CC dispone: “El fiador podrá hacer pago de la deuda, aun antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiere hacerlo el deudor principal”. El artículo 2373 del CC señala: “El fiador que pagó antes de expirar el plazo de la obligación principal, no podrá reconvénir al deudor, sino después de expirado el plazo”. Por esto, el fiador debe dar aviso al deudor antes de efectuar el pago. La omisión del aviso produce importantes consecuencias:

- i. El deudor puede oponer al fiador todas las excepciones que pudo oponer al acreedor conforme al primer inciso del artículo 2377 del CC.
- ii. Pierde el fiador el derecho para que se le reembolse si el deudor paga la deuda ignorando que el fiador la había satisfecho, conforme al inciso segundo del artículo 2377 del CC.

b) Facultad del fiador de exigir que se proceda contra el deudor.

El artículo 2356 dispone: “Aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acreedor, desde que sea exigible la deuda, para que proceda contra el deudor principal”. De este modo, el deudor puede poner fin a la incertidumbre acerca de su responsabilidad y evitar que la negligencia del acreedor deje transcurrir el tiempo sin perseguir al deudor, con riesgo de que éste caiga en insolvencia, perjudicando su acción de reembolso. Por este motivo, si requerido por el fiador, el acreedor omite perseguir al deudor, no será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal sobrevenida durante el retardo, conforme lo dispuesto en el artículo 2356 del CC.

c) Iniciativa del acreedor.

Puede el acreedor perseguir al fiador desde que la obligación se hace exigible; no es menester que primeramente persiga al deudor principal. El beneficio de excusión o de orden de que goza el

fiador no importa que el acreedor deba necesariamente perseguir primero al deudor; es facultativo para el fiador oponerlo y sólo en caso de que lo invoque, el acreedor debe accionar primeramente contra el deudor principal.

d) Defensas del fiador.

Las defensas del fiador consisten en:

➡ Beneficio de excusión.

El artículo 2357 del CC dispone: “El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda”. Es facultativo para el fiador; podrá exigir que se persiga primero al deudor o abstenerse de hacerlo. Sin embargo, en ciertos casos, el acreedor está obligado a practicar la excusión, como requisito previo indispensable para proceder contra el fiador:

- i. En primer lugar, cuando así se haya estipulado expresamente.
- ii. En segundo lugar, cuando el fiador expresa e inequívocamente no se hubiere obligado a pagar sino lo que el acreedor no pudiese obtener del deudor, conforme lo señalado en el inciso segundo del artículo 2365 del CC. Obligándose de esta manera el fiador no es responsable de la insolvencia del deudor con tal que concurran las siguientes circunstancias: primero, que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse pagar; y, segundo, que haya sido negligente en servirse de ellos.

Los requisitos que hacen procedente el beneficio de excusión son:

- i. Que el fiador no esté privado del beneficio.
- ii. Que lo oponga en tiempo oportuno.
- iii. Que señale al acreedor bienes del deudor para perseguir el cumplimiento de la obligación.

El beneficio de excusión es de la naturaleza de la fianza; puede el fiador, en consecuencia, estar privado de este beneficio sin que por ello resulte ineficaz el contrato o degenera en un contrato diverso. Los casos en que se encontrará privado del beneficio son los siguientes:

- i. No goza del beneficio de excusión el fiador que lo ha renunciado expresamente conforme al primer número del artículo 2358 del CC. El artículo 2360 deja en claro que por la renuncia del fiador principal no se entenderá que renuncia el subfiador.
- ii. Tampoco goza del beneficio el fiador que se ha obligado solidariamente, conforme lo dispuesto en el segundo número del artículo 2358 del CC.
- iii. Tampoco el fiador de una obligación natural, pues, conforme al tercer número del artículo 2358 del CC, es necesario que la obligación principal produzca acción.
- iv. En fin, no dispone del beneficio de excusión el fiador en la fianza judicial pues para que se goce de la ventaja es preciso que la fianza no haya sido ordenada por el juez, conforme lo dispuesto en el cuarto número del artículo 2358 del CC.

En lo relativo a la oportunidad para oponer el beneficio de excusión, el quinto número del artículo 2358 del CC dispone que para gozar del beneficio de excusión es menester que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador; salvo que el deudor al tiempo del requerimiento no tenga bienes y después los adquiera. El CPC, ha precisado la oportunidad en que el beneficio de excusión debe invocarse. Si se tratare de un juicio ordinario, debe oponerse en el término para contestar la demanda y constituye una excepción dilatoria; en el juicio ejecutivo debe hacerse valer en el escrito de oposición a la ejecución. En el caso que el deudor principal adquiera después bienes, el beneficio de excusión debe oponerse como alegación o defensa tan pronto como el fiador tenga conocimiento de haber sobrevenido bienes al deudor.

El sexto número del artículo 2358 del CC exige, como condición del beneficio, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. No se tomarán en cuenta para la excusión los bienes que señala el artículo 2359 del CC, bien por las dificultades de su realización, bien porque resulta problemático que el acreedor pueda satisfacerse con ellos. No se tendrán en cuenta:

- i. Los bienes existentes fuera del territorio del Estado, conforme al primer número del artículo 2359 del CC.
- ii. Los bienes embargados o litigiosos, o los créditos de dudoso o difícil cobro, conforme al segundo número del artículo 2359 del CC.
- iii. Los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria, conforme al tercer número del artículo 2359 del CC.
- iv. Los bienes hipotecados a favor de deudas preferentes, en la parte que pareciere necesaria para el pago completo de éstas, conforme al cuarto número del artículo 2359 del CC.

El artículo 2364 del CC señala: “Si los bienes excutidos no produjeren más que un pago parcial de la deuda, será, sin embargo, el acreedor obligado a aceptarlo y no podrá reconvenir al fiador sino por la parte insoluta”. Pero los bienes excutidos han de ser suficientemente importantes para que pueda obtenerse un resultado apreciable y serio; de otro modo el beneficio de excusión constituiría una burla para el acreedor.

Conforme lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2361 del CC tiene el acreedor derecho para que el fiador le anticipe los costos de la excusión. No está obligado el fiador a proporcionar de inmediato los fondos, bajo pena que se rechace su excepción. El suministro de los costos no es condición o requisito del beneficio de excusión. Debe el fiador anticipar los gastos siempre que el acreedor lo exija. La razón del anticipo de los gastos es porque puede reportar un beneficio al fiador y así se evita que el fiador recurra al beneficio de excusión con fines puramente dilatorios. A falta de acuerdo entre las partes los gastos los fijará el juez. Si el fiador prefiere hacer la excusión por sí mismo dentro de un plazo razonable, será oído.

El artículo 2363 del CC establece perentoriamente que el beneficio de excusión no puede oponerse sino una vez. La regla tiene como única excepción que los bienes hayan sido posteriormente adquiridos por el deudor principal, de acuerdo a lo señalado en el segundo inciso del artículo 2363 del CC.

La regla general es que el fiador debe señalar los bienes del deudor a quien afianzó. La regla sufre excepción en las obligaciones solidarias. El artículo 2362 del CC señala: “Cuando varios deudores

principales se han obligado solidariamente y uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá derecho para que se excutan no sólo los bienes de este deudor, sino de sus codeudores”. El fiador de uno de los deudores solidarios es considerado, en cierto modo, como fiador de todos. Existe entre los artículos 2362 y 2373 una notoria contradicción. Mientras el primero considera al fiador de uno de los varios deudores como fiador de todos; el segundo sólo le da acción de reembolso contra el que expresamente afianzó.

El artículo 2366 del CC prescribe: “El subfiador goza del beneficio de excusión, tanto respecto del fiador como del deudor principal”.

Los efectos del beneficio de excusión se resumen como sigue:

- i. Como excepción dilatoria que es, el beneficio de excusión suspende la entrada a juicio, tanto como el acreedor demore en practicar la excusión. Mientras tanto, el fiador queda liberado de pagar.
- ii. El acreedor queda obligado a practicar la excusión. El inciso primero del artículo 2365 prescribe: “Si el acreedor es omiso o negligente en la excusión, y el deudor cae entre tanto en insolvencia, no será responsable el fiador sino en lo que exceda al valor de los bienes que para la excusión hubiere señalado”.
- iii. Si los bienes excutidos no son suficientes, el acreedor deberá resignarse a recibir un pago parcial. Solamente puede perseguir al fiador por el saldo insoluto, conforme lo señalado en el artículo 2364 del CC.

➡ **Beneficio de división.**

El beneficio de división sólo tiene lugar cuando existe pluralidad de fiadores. El artículo 2367 del CC señala: “Si son varios los fiadores se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa”.

La división de la deuda entre los cofiadores, en nuestra legislación, se opera de pleno derecho. Mientras el beneficio de excusión es una excepción dilatoria, el beneficio de división es una excepción perentoria.

Para gozar los fiadores del beneficio de división se requieren las siguientes condiciones:

- i. Que los fiadores no se hayan obligado solidariamente al pago, conforme lo señalado en el artículo 2367 del CC. La estipulación de solidaridad es una enérgica renuncia al beneficio de división.
 - ii. Que los fiadores lo sean de un mismo deudor y de una misma deuda. El artículo 2368 dispone: “La división prevenida en el artículo anterior tendrá lugar entre los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, aunque se hayan rendido separadamente las fianzas”.
- Por regla general la división de la deuda entre los fiadores se hace por partes iguales o cuotas viriles. La regla tiene dos excepciones:
- i. La división de la deuda se verifica entre los fiadores solventes. El inciso segundo del artículo 2367 dispone: “La insolvencia de un fiador gravará a los otros; pero no se mirará como insolvente aquel cuyo subfiador no lo está”.

ii. Tampoco se verificará por partes iguales la división de la deuda cuando alguno de los fiadores haya limitado su responsabilidad a una determinada suma, conforme lo señalado en el inciso primero del artículo 2367 del CC.

➡ **Excepción de subrogación.**

El fiador que se obliga tiene ciertamente en cuenta que si es obligado a pagar, podrá repetir contra el deudor. El tercer número del artículo 1610 señala que se subroga en los derechos del acreedor. Para que el fiador pueda subrogarse eficazmente es menester que el acreedor conserve sus acciones. Perdidas estas acciones, puesto el fiador en la imposibilidad de subrogarse, queda indefenso para obtener el reembolso de lo que pagó.

El segundo número del artículo 2381 del CC dispone que se extingue la fianza en cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía derecho de subrogarse. La extinción de la fianza será total o parcial según las circunstancias. El artículo 2355 señala: “Cuando el acreedor ha puesto al fiador en el caso de no poder subrogarse en sus acciones contra el deudor principal o contra los otros fiadores, el fiador tendrá derecho para que se le rebaje de la demanda del acreedor todo lo que dicho acreedor hubiera podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal”.

En consecuencia, mediante la excepción de subrogación el fiador puede, según las circunstancias, obtener que se rebaje la demanda del acreedor y, aun, que se le declare libre de toda responsabilidad.

➡ **Excepciones reales y personales.**

El fiador puede oponer al acreedor toda clase de excepciones reales y las personales suyas. Se denominan excepciones reales las inherentes a la obligación principal; y personales las que provienen de circunstancias particulares del obligado.

El artículo 2354 del CC dispone: “El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepciones reales, como las de dolo, violencia o cosa juzgada, pero no las personales del deudor, como su incapacidad para obligarse, cesión de bienes o el derecho que tenga de no ser privado de lo necesario para subsistir”.

Llama la atención que la ley considere excepciones reales las de dolo o violencia o, mejor dicho, las de nulidad relativa que provengan de dolo o violencia. En verdad, tales excepciones son personales porque la nulidad sólo puede pedirla la víctima del dolo. Sin embargo, el fiador puede oponer la excepción de nulidad fundada en estas causales. El carácter accesorio de la fianza justifica esta regla excepcional: anulada la obligación principal, se extingue la fianza.

De acuerdo al artículo 177 del CPC, la excepción de cosa juzgada compete al que la ha obtenido en juicio y a todos aquellos a quienes, según la ley, aprovecha el fallo. El fiador, por lo tanto, puede aprovecharse de la cosa juzgada del fallo que absuelve al deudor principal.

3.9.2 Efectos entre el fiador y el deudor.

El fiador que paga no cumple una obligación propia, en que tenga un personal interés, por consiguiente, debe ser reembolsado. Con este objeto dispone, por derecho propio, de una acción personal contra el deudor; además la ley le subroga en los derechos del acreedor. En principio el fiador no puede accionar contra el deudor, sea ejercitando su acción personal o la acción subrogatoria, sino cuando ha pagado. Sin embargo, en casos excepcionales, la ley acuerda al fiador un recurso anticipado, justamente para evitarse el trance de tener que pagar. Por este motivo, los efectos de la fianza entre deudor y fiados deben considerarse en dos momentos: antes y después de verificado el pago.

3.9.2.1 Derechos del fiador antes del pago.

Ciertas circunstancias pueden sobrevenir que inspiren al fiador el justo temor de que no logrará que se le reembolse una vez efectuado el pago y que sus acciones con tal objeto resultarán ilusorias. En tales circunstancias, el fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago, conforme lo señalado en el inciso primero del artículo 1369 del CC.

En primer lugar, el fiador tiene derecho a que el deudor o tenga que se le releve de la fianza; no puede relevarle él mismo porque es extraño al contrato. Puede, asimismo, exigir que el deudor le caucione las resultas de la fianza. La caución puede consistir en una hipoteca, una prenda o una fianza. Esta fianza se denomina contrafianza. Por último, el fiador puede exigir del deudor que consigne medios suficientes para efectuar el pago. Por tratarse de una obligación alternativa, la elección de las medidas indicadas corresponde al deudor. Es importante recalcar que, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 2369 del CC, no se conceden los derechos indicados al que afianzó contra la voluntad del deudor.

El artículo 2369 enumera taxativamente las circunstancias que autorizan al fiador para ejercitar los derechos anotados:

- i. Cuando el principal deudor disipa o aventura temerariamente sus bienes, conforme al primer número del artículo 2369 del CC.
- ii. Cuando el deudor se obligó a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y éste ha vencido, conforme al segundo número del artículo 2369 del CC.
- iii. Cuando se ha cumplido la condición o vencido el plazo y se hace, en consecuencia, exigible la obligación en todo o en parte, conforme al tercer número del artículo 2369 del CC.
- iv. Cuando hubieren transcurrido cinco años desde el otorgamiento de la fianza, conforme al cuarto número del artículo 2369 del CC. Sin embargo, no podrá hacerlo cuando la fianza se ha constituido por un tiempo determinado más largo o cuando la fianza se contrajo para asegurar obligaciones que no están destinadas a extinguirse en un tiempo determinado.
- v. Cuando haya temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda, conforme al quinto número del artículo 2369 del CC.

Fiador y deudor están obligados, recíprocamente a darse aviso del pago. La falta de oportuno aviso puede traer como consecuencia que uno pague lo que el otro ha pagado y privarles de excepciones que podrían haber hecho valer.

Si el deudor paga sin dar aviso al fiador será responsable para con éste de lo que, ignorando la extinción de la deuda, pagare de nuevo, pero tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido conforme lo dispuesto en el artículo 2376 del CC. El deudor, pues, debe reembolsar al fiador y puede repetir contra el acreedor.

Si paga el fiador sin aviso al deudor, se produce una doble consecuencia: en primer lugar, conforme al inciso segundo del artículo 2377 del CC, en caso que el deudor pague la deuda por su parte no tendrá el fiador recurso alguno contra él pero podrá intentar contra el acreedor la acción del deudor por el pago indebido; y, en segundo lugar, el pago precipitado del fiador puede privar al deudor de las excepciones que pudo oponer al acreedor, pudiendo oponer dichas excepciones al fiador cuando éste intente las acciones encaminadas al reembolso, conforme lo señalado en el primer inciso del artículo 2377 del CC.

3.9.2.2 Acción de reembolso.

Se la denomina acción personal en atención a su origen, porque es propia del fiador, a diferencia de la acción subrogatoria en que el fiador ejercita los derechos de su acreedor, cuyo lugar pasa a ocupar, en virtud de la subrogación que opera en su favor. El fundamento de esta acción es variable. Si la fianza se constituye por encargo del deudor, es el resultado de un mandato. Si la fianza se otorga sin oposición del deudor, puede estimarse que existe una agencia oficiosa. El artículo 2370 del CC dispone: “El fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor”.

La acción de reembolso permite al fiador quedar totalmente indemne de las consecuencias de la fianza. La acción de reembolso comprende:

- i. Debe el deudor reembolsar lo que el fiador haya pagado por él, conforme lo dispuesto en el artículo 2370 del CC.
- ii. Tiene el fiador, asimismo, derecho a que se le paguen los correspondientes intereses.
- iii. La acción de reembolso comprende los gastos.
- iv. También deben pagarse al fiador los perjuicios que haya sufrido.

Cuatro condiciones o requisitos son necesarios para que el fiador pueda ejercitar la acción personal o de reembolso:

- i. Que no se encuentre privado de la acción.
- ii. Que haya pagado la deuda.
- iii. Que el pago haya sido útil.
- iv. Que entable la acción en tiempo oportuno.

Suele el fiador encontrarse privado de la acción de reembolso:

- i. Está privado de la acción, por razones obvias, el fiador de una obligación natural, cuando la obligación del principal deudor es puramente natural y no se haya validado por la ratificación o por el lapso del tiempo, conforme lo señalado en el primer número del artículo 2375 del CC.
- ii. No tiene acción de reembolso el fiador que se obligó contra la voluntad del deudor principal, conforme lo señalado en el segundo número del artículo 2375 del CC.
- iii. No tiene el fiador acción de reembolso cuando paga sin dar aviso al deudor y éste paga igualmente la deuda, conforme al inciso segundo del artículo 2377 del CC.

Para entablar la acción de reembolso es menester que el fiador haya pagado la deuda. Aunque el CC se refiere al pago, es justo hacer extensiva la regla a los casos en que el fiador extinga la deuda por otro medio que le signifique un sacrificio pecuniario, como una dación en pago o una compensación. Si la obligación se extingue por algún medio no oneroso para el fiador, es obvio que no tiene acción de reembolso, conforme lo dispuesto en el artículo 2374 del CC.

Asimismo, el pago del fiador debe ser útil, entendiéndose tal cuando ha sido capaz de extinguir la obligación. Por este motivo, el tercer número del artículo 2375 dispone que el fiador no tiene acción de reembolso cuando por no haber sido válido el pago del fiador no ha quedado extinguida la deuda.

Como es lógico, el fiador debe deducir la acción de reembolso después del pago y, por regla general, podrá hacerlo inmediatamente de haberlo verificado. Por excepción, no podrá entablar la acción cuando la obligación principal no era aún exigible, esto es, si el fiador pagó anticipadamente, conforme lo dispuesto en el artículo 2373 del CC. Por otra parte, el fiador deberá entablar la acción antes de que prescriba. El plazo de prescripción es de cinco años, contados desde el pago o desde que se hizo exigible la obligación principal, en su caso.

La acción de reembolso se dirige contra el deudor, pero es menester hacer algunos distinguos para determinar las condiciones en que el fiador puede ejercerla cuando son varios deudores:

- i. Si la obligación es simplemente conjunta, por la acción de reembolso el fiador sólo podrá reclamar la cuota que corresponda a cada uno de los deudores.
- ii. Si la obligación es solidaria, hay que distinguir dos situaciones: primero, cuando el fiador haya afianzado a todos los deudores podrá pedir el reembolso del total a cualquiera, conforme lo señalado en el artículo 2372 del CC; y, segundo, en caso de haber afianzado a uno de los deudores, el fiador puede reclamar el total al afianzado y nada a los demás deudores, conforme al artículo 2372 del CC. En el segundo caso no tendrá contra los demás sino las acciones que le correspondan como subrogado en las del deudor a quien ha afianzado, de acuerdo al artículo 2372 del CC. Por lo tanto, privado de la acción de reembolso tiene a salvo el fiador, en cambio, la acción subrogatoria, y por su intermedio puede cobrar a cada uno de los restantes codeudores su cuota, como si el pago lo hubiera realizado el deudor afianzado.

3.9.2.3 Acción subrogatoria.

El tercer número del artículo 1610 del CC dispone que se opera la subrogación legal a favor del que paga una deuda ajena a la que está obligado subsidiariamente. Cumplida por el fiador la obligación, se extingue respecto del acreedor satisfecho de su crédito, pero subsiste íntegramente a favor del fiador que efectuó el pago. El fiador que paga, por lo tanto, dispone de dos acciones para lograr el reembolso: la acción personal y la acción subrogatoria. Por lo general, la acción subrogatoria será más ventajosa porque permite al fiador gozar de las diversas garantías, privilegios, prendas e hipotecas, de que gozaba el acreedor.

Por excepción, el fiador no goza de la acción subrogatoria en los siguientes casos:

- i. Como se comprende, no puede ejercer la acción subrogatoria el fiador de una obligación natural.
- ii. Tampoco dispone de esta acción el fiador que pagó sin dar aviso al deudor que, ignorante de la extinción de la deuda, pagare de nuevo. En este caso, el fiador no dispone de ninguna acción contra el deudor, y sólo puede intentar contra el acreedor la acción de pago de lo no debido, conforme a lo dispuesto en el artículo 2377 del CC.

La acción subrogatoria puede el fiador encaminarla contra el deudor principal, contra los codeudores solidarios o contra los cofiadores. Tal es la regla general del artículo 1612 del CC que señala que la subrogación traspasa al fiador que paga todos los derechos del acreedor.

Las diferencias entre la acción de reembolso y la acción subrogatoria son principalmente las siguientes:

- i. La acción personal o de reembolso corresponde al fiador por derecho propio. Por la acción subrogatoria el fiador ejercita los derechos del acreedor como consecuencia que le sustituye y ocupa su lugar.
- ii. La acción personal comprende todo lo que el fiador pagó, con intereses y gastos y aun los perjuicios que hubiere sufrido. La acción subrogatoria sólo faculta al fiador para reclamar, estrictamente, lo que pagó al acreedor.
- iii. La acción personal no tiene garantías de ninguna clase. La acción subrogatoria está rodeada de todas las garantías que aseguraban al acreedor el cumplimiento de la obligación.
- iv. En caso de pago parcial, el fiador que ejercita la acción personal concurre en igualdad de condiciones con el acreedor para el pago del saldo. Ejercitando la acción subrogatoria el primer acreedor goza de preferencia, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1612 del CC.
- v. La prescripción de la acción de reembolso corre desde el pago y, excepcionalmente, desde que la obligación principal se hizo exigible cuando el fiador efectuó un pago anticipado. La prescripción de la acción subrogatoria corre desde que se hizo exigible la obligación principal en manos del primitivo acreedor.

3.9.2.4 Acción del fiador contra su mandante.

El fiador que se obliga por encargo de un tercero dispone, todavía, de una tercera acción: puede accionar contra el tercero por cuyo encargo se constituyó fiador. El artículo 2371 del CC prescribe: “Cuando la fianza se ha otorgado por encargo de un tercero, el fiador que ha pagado tendrá acción contra el mandante, sin perjuicio de la que le competa contra el principal deudor”. Toca al fiador elegir la que juzgue más conveniente de las diversas acciones que le corresponden.

3.9.3 Efectos entre los cofiadores.

Cuando son varios los fiadores la deuda se divide entre ellos, de pleno derecho, en cuotas iguales. La división de la deuda en cuotas iguales no tiene lugar en caso de insolvencia de un cofiador o cuando se ha limitado la responsabilidad a una cuota o suma determinada.

3.9.3.1 Derechos del cofiador que paga más de lo que le corresponde.

El fiador que paga más de lo que le corresponde beneficia a sus cofiadores y tiene derecho a que le reembolsen el exceso pagado. El artículo 2378 del CC dispone: “El fiador que paga más de lo que proporcionalmente le corresponde, es subrogado por el exceso en los derechos del acreedor contra los cofiadores”.

En caso de insolvencia del fiador, la acción respectiva podrá intentarse contra el subfiador. El artículo 2380 del CC dispone: “El subfiador, en caso de insolvencia del fiador por quien se obligó, es responsable de las obligaciones de éste para con los otros fiadores”.

3.9.3.2 Excepciones de los cofiadores.

Los cofiadores pueden oponerse, entre sí, las excepciones reales y las suyas personales. El artículo 2379 del CC expresa: “Los cofiadores no podrán oponer al que ha pagado, las excepciones puramente personales del deudor principal. Tampoco podrán oponer al cofiador que ha pagado, las excepciones puramente personales que correspondían a éste contra el acreedor y de que no quiso valerse”.

3.10 Extinción de la Fianza.

3.10.1 Extinción por vía consecuencial y por vía directa o principal.

Se extingue la fianza por vía de consecuencia cada vez que se extinga, por un medio legal, la obligación principal. La fianza se extingue por vía directa cuando cesa la responsabilidad del fiador, aunque la obligación principal se conserve vigente. La extinción de la fianza, por una u otra vía, puede ser total o parcial.

3.10.2 Extinción de la fianza por vía consecuencial.

Lo accesorio no puede subsistir sin lo principal. Por ende, la extinción de la obligación principal acarrea la extinción de la fianza. El tercer número del artículo 2381 del CC previene que la fianza

se extingue, en todo o en parte, por la extinción de la obligación principal en todo o en parte. Puede el fiador prevalerse, por lo tanto, de la extinción de la obligación principal, cualquiera sea la causa que la produzca: pago, dación en pago, compensación, prescripción, etc. Solamente la nulidad de la obligación principal por la relativa incapacidad del deudor deja subsistente la fianza, por ser la incapacidad una excepción personal que el fiador consecuentemente no puede invocar, conforme lo dispuesto en el artículo 2354 del CC.

3.10.3 Extinción de la fianza por vía principal.

La fianza se extingue, asimismo, por vía directa, por los modos generales de extinguirse las obligaciones, conforme lo dispuesto en el artículo 2381 del CC. Unas veces la causa que extingue la fianza extingue igualmente la obligación principal; así ocurre cuando el fiador paga la deuda. Otras veces la obligación principal subsiste, como cuando el acreedor releva al fiador de la fianza.

La ley se refiere especialmente a la dación en pago y a la confusión como modos de extinguir la fianza. La dación en pago extingue irrevocablemente la fianza, aunque después sobrevenga evicción del objeto dispone el artículo 2382 del CC. En cuanto a la confusión, el artículo 2383 del CC dispone: “Se extingue la fianza por la confusión de las calidades de acreedor y fiador, o de deudor y fiador, pero en este caso la obligación del subfiador subsistirá”.

La fianza tiene, además, modos peculiares de extinguirse:

- i. Se extingue la fianza por el relevo de la fianza en todo o en parte por el acreedor al fiador, conforme lo señalado en el primer número del artículo 2381 del CC. La obligación principal, en tal evento, subsiste.
- ii. Se opera, asimismo, la extinción de la fianza, cuando el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía derecho de subrogarse, conforme lo señalado en el segundo número del artículo 2381 del CC. La fianza, en este caso, se extingue hasta la concurrencia de lo que el fiador hubiera podido obtener del deudor principal o de los otros fiadores por medio de la subrogación legal, conforme lo dispuesto en el artículo 2355 del CC.

Unidad 4: Interpretación de los Contratos.

Tema 1: Generalidades.



Observación

Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones. En primer término, debe advertirse que se distingue en la doctrina internacional dos sistemas generales de interpretación de los contratos. En primer lugar, el llamado **sistema subjetivo de interpretación de los contratos**, que es el vigente en Chile, y que se caracteriza por la búsqueda, a menudo imposible o ficticia, de la voluntad psicológica de las partes. En seguida, también se encuentra el **sistema de interpretación objetiva de los contratos**, el cual rehúye de las intenciones que tuvieron o habrían tenido las partes contratantes, preguntándose, a fin de fijar los efectos del contrato discutido, que es lo socialmente más útil o lo que la justicia indica como lo más saludable.

La interpretación de los contratos reviste enorme importancia práctica. La interpretación del contrato reconoce o determina los efectos jurídicos, o sea, que de ella depende el alcance de la convención. La trascendencia concreta de cualquier contrato sobre el cual las partes discrepan es el resultado de la interpretación.

Tema 2: La Interpretación Concebida Exclusivamente como una Búsqueda de Voluntad.

2.1 Los artículos 1156 y 1560 chileno en cuanto bases del sistema subjetivo de interpretación contractual.

Es sabido que para la doctrina clásica la voluntad es, de algún modo, la causa eficiente de todo el derecho. Es lógico, por tanto, que la teoría tradicional haya prescrito que, en la interpretación de los contratos, el intérprete debe precisar el sentido de las convenciones, de acuerdo a las intenciones de quienes las concluyeron.

El CC francés, haciéndose eco de estas ideas, consagra en su artículo 1156 el sistema clásico de interpretación de los contratos. Esta disposición expresa: **“En las convenciones se debe buscar cuál ha sido la intención común de los contratantes, antes de atenderse al sentido literal de las palabras”**. Por su lado, el artículo 1560 de nuestro CC establece: “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.

Sería erróneo pensar que estos artículos le ordenan al juez exclusivamente la búsqueda de elementos cognoscibles directamente por el examen de la realidad externa, elementos objetivos, perceptibles sin necesidad de inmiscuirse en aquello que hay de más precioso en el individuo: su interioridad, su alma. La verdad es que ellos ordenan al intérprete una investigación psicológica. La voluntad interna del individuo es la meta del intérprete; éste no debe escatimar sus esfuerzos para llegar a ella. Cualquier esfuerzo del legislador por alivianar la función interpretativa del juez mediante la dictación de reglas de interpretación, tocará siempre con las graves limitaciones inherentes al método subjetivo de interpretación: declarar, a posteriori, cuáles fueron las reales intenciones de los contratantes. Resulta casi ocioso señalar que el juez intérprete debe, de todos modos, dar una solución al asunto, y que en ningún caso, por grandes que sean las dificultades, podrá abstenerse de juzgar. En la hipótesis en cuestión el juez deberá buscar la voluntad virtual de las partes.

La doctrina de la voluntad reduce la interpretación a la **simple determinación de la intención de las partes**, lo que es una mera cuestión de hecho, donde el trabajo del intérprete no es el de un jurista que aplica una regla, sino el de un psicólogo que percibe la intención de los contratantes, lo que es una operación de carácter puramente inductivo, tendiente, solamente, a la obtención de un conocimiento preciso de la verdadera intención. En Chile, para que la intención sea preferida a la declaración, debe estarse seguro de aquella. No habría por tanto lugar, como ocurre en el régimen francés, para las voluntades virtuales. En el sistema chileno no procederían las interpretaciones adivinatorias hechas en condicional. En el sistema clásico francés, el intérprete debe siempre buscar la común intención de los contratantes; en Chile, estáoslo interesaría en la medida en que aparezca claramente, en caso contrario, el juez debería considerar exclusivamente la declaración o texto del contrato.

Si ni la intención de las partes, que no se ha logrado conocer con claridad, ni la declaración, oscura o insuficiente, permiten resolver el proceso, el sistema subjetivo se ve compelido a recurrir a voluntades puramente virtuales. En consecuencia, la realidad de los dos países, en la medida en que el sistema clásico subjetivo se mantiene en vigor, no es diferente. En el uno como en el otro, cuando el intérprete no logra reconocer la voluntad psicológica real de los contratantes, se ve en la necesidad de inducir de las circunstancias de cada especie, de los elementos intrínsecos y extrínsecos a la declaración, su voluntad virtual o probable y a dirimir el pleito conforme a ella.

2.2 Como descubrir la voluntad común probable de los contratantes. Circunstancias de la especie.

El juez, examinando todas las circunstancias de la especie y no pudiendo llegar a una certidumbre, deberá esforzarse en inducir lo que fue la voluntad común. A fin de cuentas, la misión del juez consiste en establecer presunciones de la voluntad común.

Así, el juez debe tomar en consideración todas las circunstancias de la especie, todos los hechos susceptibles de esclarecer el sentido de la convención. Tales hechos, una vez probados en el proceso, servirán de base al tribunal para colegir la voluntad común real o virtual de las partes contratantes y permitirán que el litigio o controversia sobre el alcance del contrato sea solucionado. Las circunstancias de la especie constituyen el ambiente general del contrato. Está claro, sin embargo, que tales circunstancias pueden ser anteriores, posteriores o concomitantes a la conclusión de la convención. Hace falta, por el contrario, recalcar, a propósito de la naturaleza de las circunstancias de la especie, que, en un sistema clásico de interpretación de los contratos, ellas pueden diferenciarse según tengan una inclinación objetiva o una inclinación subjetiva.

Tema 3: Condiciones Necesarias para que haya Lugar a Interpretación.

3.1 La oscuridad del contrato como condición de la interpretación. Historia del problema.

El interés teórico de esta materia es evidente pues condiciona el rigor mismo del sistema subjetivo de interpretación de los contratos. Domat estimó que la intención debe prevalecer sobre los términos por claro que sean, pero agregó una condición: para que el juez pueda apartarse de los términos claros es preciso que descubra una intención evidente contraria al texto de la declaración. La misma condición fue acogida por Andrés Bello ya que nuestro artículo 1560 establece que sólo si se averigua claramente la intención de los contratantes se prescindirá de lo literal de las palabras. Ambos están de acuerdo en el predominio de la intención sobre los términos, aun si éstos son claros y precisos. En consecuencia, la oscuridad del texto del contrato no es, en el espíritu de estos autores, una condición necesaria para su interpretación.

3.2 El problema de la oscuridad del contrato ante la doctrina y la jurisprudencia más recientes.

Los civilistas del siglo XIX fueron quienes sostuvieron, de un modo especial, la imposibilidad de interpretar los contratos claros y el deber de los jueces de limitarse a su aplicación textual. En la doctrina francesa posterior, y aun en la doctrina contemporánea, los autores permanecen en desacuerdo. En Chile, al igual que doquiera que la discusión ha surgido, las opiniones son contradictorias, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

3.3 Conclusiones frente al problema de la oscuridad del contrato como requisito de la interpretación.

Las ideas según las cuales el contrato claro no debe ser interpretado, exigirían, para delimitar el demonio de la interpretación, distinguir perfectamente los contratos claros de los contratos oscuros. He ahí la clave del problema. Ahora bien, tal distinción, en nuestra opinión, es punto menos que imposible.

Creemos que la distinción, en los contratos, entre las cláusulas que son claras y aquellas que no lo son es equívoca. Nos manifestamos partidarios de la doctrina de Domat y de Portier: todo contrato puede ser interpretado; la oscuridad no es una condición para que haya lugar a la interpretación. Podría afirmarse que no cabe la interpretación cuando la voluntad o intención de las partes es clara, pero no hay que confundir la voluntad psicológica con las expresiones formales de la voluntad. Que los términos sean claros, no implica necesariamente que la voluntad lo sea. Tras términos claros puede ocultarse una voluntad diferente, que el intérprete debe descubrir.

En consecuencia, la única condición, necesaria y suficiente, para que haya lugar a la interpretación subjetiva de un contrato, es la existencia de una contienda entre las partes.

3.4 Causas de la contienda que toda interpretación contractual presupone.

- a) Ambigüedad en el contrato; una convención es ambigua, cuando admite dos o más sentidos totalmente diferentes entre los cuales se puede dudar.
- b) Oscuridad en el contrato; una convención es oscura cuando no presenta ningún sentido determinado. Es la hipótesis particular de las contradicciones manifiestas.
- c) Los términos del contrato pueden ser claros, pero insuficientes.
- d) Los términos del contrato pueden ser claro, pero excesivos.
- e) Finalmente, los términos pueden ser claros en sí mismos, pero haber sido empleados de manera dudosa.



La conclusión será, pues, que siendo la contienda entre los contratantes la única condición para que el juez pueda interpretar, sus causas son: por una parte, **ambigüedad u oscuridad del contrato**; y, por la otra, **que los interesados ofrezcan demostrar al juez una voluntad psicológica determinada, que permita al intérprete alejarse del texto claro de la convención**. Tocamos así un problema de procedimiento civil: el juez no puede interpretar el contrato de oficio; si lo hiciere, habría ultra petita en su decisión. Pero desde que una de las partes solicita la interpretación, el juez puede comenzar la investigación que el caso requiera, sin necesidad de resolver, previamente, si el contrato es o no claro.

Tema 4: Las Reglas de Interpretación de los Contratos.

4.1 Definición y generalidades.

Las reglas de interpretación son los principios y los moldes que sirven de base, de punto de partida, a los razonamientos del intérprete, y que le ayudan en la búsqueda de la intención común de los contratantes, blanco fundamental de la interpretación subjetiva de las convenciones.

Las reglas de interpretación tienen necesariamente una vocación restringida: su pretensión no puede ser la de señalar al intérprete, siempre y en todo caso, la ruta concreta a seguir para llegar hasta la voluntad común de los contratantes, ya que la multiplicidad y la diversidad de casos desafían toda reglamentación exhaustiva. El intérprete debe servirse, en la medida de lo posible, de estas reglas para realizar su tarea, pero nada impide que tome también en consideración otros principios que no han tenido sanción legal directa.

El artículo 1560 del CC, más que una regla de interpretación, sirve de principio rector a las reglas que le siguen en el CC. Su papel es superior al de una regla de interpretación pues consagra en Chile, por sí sólo, el sistema subjetivo tradicional de interpretación de los contratos, cuyo rasgo fundamental consiste en la búsqueda de la voluntad interna de las partes.

4.2 Casos de interpretación legal.

Las reglas de interpretación de los contratos indican al intérprete cómo debe actuar para llegar a determinar la voluntad psicológica de los contratantes. En cambio, en lo que concierne a los casos de interpretación legal, el legislador va mucho más lejos: no se limita a dar una indicación al intérprete. Al contrario, realiza anticipadamente, en todas sus partes, **la interpretación, dictando una solución que el juez deberá, por consiguiente, aplicar a todas las especies que correspondan a la hipótesis prevista en la ley.** El alcance de los casos de interpretación legal es muy variado. Sin embargo, todos éstos tienen en común lo siguiente: la solución dada por el legislador se reputa corresponder a la voluntad virtual del o de los emisores de la declaración.

Tenemos, en primer lugar, los casos más simples en que el legislador se limita a fijar el sentido que deberá atribuirse a una determinada cláusula dudosa si las partes la introducen en algún acto o contrato sin explicar su extensión, por ejemplo, el artículo 567 del CC en materia de compraventa.

Seguidamente, tenemos los casos en que las partes, al celebrar un contrato, no se pronuncian sobre un aspecto particular de la convención; hay un silencio relativo de los partícipes pues existe una declaración, pero resulta incompleta para sacar todas las consecuencias de derecho que la ley exige, y la ley suple dicho silencio dando la solución que corresponde a la voluntad que las partes habrían tenido si hubiesen previsto la interrogante prevista por el legislador. Es el caso de todos los contratos reglamentados por el legislador.

Tenemos, finalmente, un tercer orden de casos, en que la voluntad de las partes es interpretada por el legislador. Es la hipótesis más osada ya que no hay solamente un silencio relativo sino que un silencio absoluto de los contratantes. Tradicionalmente se han explicado así las normas sobre sucesión intestada y el régimen legal matrimonial entre los cónyuges que no celebraron capitulaciones matrimoniales.

4.3 Reglas de interpretación relativas a los elementos intrínsecos del contrato.

Interpretar a partir de los elementos intrínsecos del contrato significa interpretar el texto del contrato por sí mismo, considerando sólo los elementos que se encuentra, de una u otra manera, en la misma declaración contractual. Al respecto existen tres reglas, contenidas en los artículos 1562, 1563 y 1564 del CC. Es importante destacar que el legislador se abstuvo de fijar un orden de preferencia entre ellos. No podía ser de otro modo pues la aplicación de estas normas ésta subordinada a la forma como el caso litigioso se presenta, a los puntos dudosos, a las posibilidades de descubrimiento de la voluntad interna de los contratantes y, en general, a las circunstancias propias de cada convención.

a) Regla de la armonía de las cláusulas.

La establece el inciso primero del artículo 1564 del CC: “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. El contrato constituye un todo indivisible. Sus cláusulas se encadenan unas a otras y es irracional considerarlas aisladamente.

b) Regla de la utilidad de las cláusulas.

La conságrale artículo 1562 del CC: “El sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. Es razonable suponer que las partes no han querido insertar en el contrato cláusulas inútiles y carentes de sentido.

c) Regla del sentido natural.

La establece el inciso primero del artículo 1563 del CC: “En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. Asimismo, el segundo inciso del artículo 1563 del CC previene: “Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen”.

4.4 Reglas de interpretación relativas a los elementos extrínsecos del contrato.

El contrato es un todo complejo, integrado no solamente por la declaración formal, por un texto o unas palabras, sino que también por otros elementos que no figuran allí y que el intérprete tiene que considerar para estar en situación de llegar a la común intención de las partes. Tales elementos se denominan **extrínsecos** o **circunstancias de la especie**.

Estas acotaciones nos conducen a formular algunas ideas sobre la prueba en relación con la interpretación. Señalaremos antes, que en nuestra opinión las circunstancias de la especie deben ser siempre tomadas en consideración, ya se trate de un acto jurídico consensual o de uno solemne. No hay raspón para introducir la diferencia propuesta por célebres autores entre contratos y testamentos. Por cierto que, no se podría de ningún modo, recurrir a pruebas extrínsecas para crear o desfigurar una cláusula de un acto solemne; pero la finalidad de la interpretación no es ésta: sólo se limita a determinar el alcance del acto jurídico. La interpretación subjetiva no crea nada nuevo, no agrega elementos al texto de la declaración, se limita a reconocer o declarar su sentido. Ahora bien, las circunstancias de la especie, los elementos extrínsecos al contrato, son siempre hechos materiales que también es menester probar, pero sin que sea necesario tomar en cuenta las limitaciones establecidas para la prueba de los actos jurídicos. Si fuere de otro modo, si se exigiera un principio de prueba por escrito para la prueba de cualquier circunstancia, la interpretación extrínseca casi no podría tener lugar y por tanto el intérprete lograría muy difícilmente descubrir la voluntad interna de los contratantes.



Las circunstancias extrínsecas a la declaración, tan importantes para la declaración, deben ser probadas por la parte que las alega, sin que sea necesario, empero, tomar en consideración las limitaciones establecidas por el CC para la prueba de los actos jurídicos. Esto no quiere decir que la interpretación en sí misma deba ser probada; no, la interpretación es, en el proceso, una tarea reservada al juez. Pero, para que éste pueda efectuarla, es preciso suministrarle los medios, demostrarle los supuestos de hecho en que el intérprete apoyará sus razonamientos al dilucidar el sentido de la convención. En este entendido, la prueba de todas las circunstancias de la especie reviste una importancia considerable.

En Chile se ha dado fuerte importancia a la interpretación en función de los elementos extrínsecos a la declaración. El CC ha establecido cuatro reglas, contenidas en los incisos segundo y tercero del artículo 1564 y en los artículos 1561 y 1565.

a) Regla de la aplicación restringida del texto contractual.

El artículo 1561 del CC dispone: “Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre la que se ha contratado”. De este modo, si las partes transigen un juicio y expresan que finiquitan toda dificultad entre ellas, actual o futura, la generalidad de los

términos de la transacción no hace que se entiendan transigidas sino las cuestiones planteadas en el juicio.

b) Regla de la natural extensión de la declaración.

El artículo 1565 del CC dispone: “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extiende”. Por este solo hecho, no se entiende que las partes han querido limitar los efectos del contrato al caso o casos especialmente previstos.

La oposición entre las dos últimas reglas es puramente aparente: estas disposiciones son manifestaciones distintas de un mismo principio general, el que ordena al intérprete considerar todas las circunstancias de la especie.

c) Regla de los otros contratos de las partes sobre igual materia.

El inciso segundo del artículo 1564 del CC dispone: “Las cláusulas de un contrato podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia”. Así, siendo vago un contrato en que el actual demandado se compromete a pagar una comisión por ciertos servicios, debe recurrirse, para interpretarlo, a un convenio que sobre la misma materia celebraron las partes con anterioridad. Puede el juez, por tanto, buscar fuera del contrato mismo que se trata de interpretar elementos para precisar su alcance.

d) Regla de la interpretación auténtica.

El inciso tercero del artículo 2564 del CC dispone: “Las cláusulas de un contrato podrán interpretarse por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra”. En la hermenéutica de los contratos, la inteligencia, el sentido que le dan los contratantes, es el faro más seguro para conocer la voluntad. Es decisiva para precisar su genuino sentido y alcance.

Si a menudo la interpretación hecha por las partes es la manifestación más exacta que puede hallar el intérprete de su voluntad interna, no es menos cierto que la ejecución práctica de la convención puede haber sido el resultado de una equivocación sobre la extensión de las prestaciones. Por esto, el intérprete, máxime si uno de los contratantes alega error, debe inducir sus conclusiones con la mayor prudencia. Debe señalarse, por último, que si la aplicación práctica del contrato implica una confesión de la común intención, ello ocurre sólo a condición de que dicha aplicación haya sido hecha por ambos partícipes o por uno con la aprobación del otro.

4.5 Reglas subsidiarias de interpretación contractual.

Si ni los elementos intrínsecos ni los elementos extrínsecos del contrato permiten al intérprete llegar a precisar el sentido de la convención discutida, será preciso que acuda a los llamados elementos subsidiarios de interpretación, en especial a la costumbre y a la equidad conforme lo

señalado en el Código de Napoleón. En Chile la disposición correspondiente es el artículo 1546 del CC que señala: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”.

a) Regla de las cláusulas usuales.

El inciso segundo del artículo 1563 del CC señala: “Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen”. Se le ha atribuido un sentido muy restringido. En efecto se lo ha explicado de manera que sólo queden involucradas en las cláusulas usuales las cosas llamadas de la naturaleza del contrato, o sea, las cláusulas legales que se entienden incorporadas al contrato sin necesidad de una manifestación expresa de voluntad en tal sentido. Esta encerradura de lo consuetudinario en el terreno interpretativo se ha fundado en que en la legislación civil chilena los usos no juegan sino cuando la ley orden expresamente que se les tenga en cuenta, conforme al artículo 2 del CC. Sirva esto para comprender la poca importancia de los usos en la interpretación de los contratos civiles; en verdad, al intérprete sólo los considera cuando las partes se han referido formalmente a ellos en el texto de la convención o han sido recogidos por las normas legales supletorias de la voluntad.



b) Regla de la última alternativa.

El inciso primero del artículo 1566 del CC dispone: “No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor”. En verdad, esto de que el intérprete, en última instancia deba dar la preferencia al deudor por sobre el acreedor no reposa puramente en la equidad. El artículo 1698 del CC dispone que incumbe probar la obligación al acreedor y también sus términos; de modo que la persistencia de la duda al interpretar implica falta de prueba por parte del acreedor, debiendo, por ende, favorecerse al deudor.

Pero el inciso segundo del artículo 1566 del CC dispone: “Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”. La jurisprudencia chilena ha aplicado directamente esta norma, en particular respecto de los contratos de adhesión.

4.6 Naturaleza de las reglas de interpretación: ¿Son simples consejos o normas imperativas?

Se ha sostenido que serían simples consejos dados al intérprete. Acorde con esta doctrina que, cosa excepcional, no ve en proposiciones legales un mandato del legislador sino que una mera sugerencia, resulta que el juez es soberano en su interpretación, su poder es amplísimo y confiado a su criterio exclusivo, de tal modo que su dictamen sólo puede revisarse por vía del recurso ordinario de apelación pero, en caso alguno, a través del extraordinario de casación. Este criterio,

que hoy ha perdido mucha vigencia, es la exageración de la doctrina que sostiene que la interpretación misma de los contratos, no ya su sujeción a esta o aquella regla, se efectúa privativamente por los jueces del fondo.

Estimo que dicha doctrina está equivocada. Que el legislador no cumple su función dando meros consejos y que no se aprecia fundamento alguno para que lo hiciera. Que las leyes tienen por objeto obligar, siendo esencialmente coercitivas. No se ve por qué no han de ser normas jurídicas positivas, sino reglas dialécticas que deban servir de guía al juez en sus operaciones mentales, ni por qué su aplicación ha de depender de condiciones de hecho, cuya existencia tenga que apreciar a su arbitrio el juez intérprete.

Según otra más reciente doctrina se trata de verdaderas normas jurídicas de carácter imperativo, cuya inobservancia por parte del juez puede ser impugnada en casación. Esta más reciente posición es, en nuestra opinión, la única justa. La doctrina de que la interpretación de los contratos constituye un hecho de la causa que los jueces del fondo pueden apreciar con facultades privativas, no se opone a la obligación que tienen de someter a la ley su criterio jurídico en esta materia, aplicando las reglas especiales establecidas por la propia ley para determinar, en desacuerdo de los contratantes, el verdadero alcance de la convención que ha de surtir efectos entre ellos y que tiene por objeto regular o avaluar su derecho. La infracción de estas reglas puede dar motivo a un recurso de casación en el fondo.

Al fijarse imperativamente las reglas de interpretación se elimina la variabilidad de soluciones que, frente a un punto concreto, acarrea la doctrina opuesta. Así, si el legislador decide que no pudiendo aplicarse otras reglas se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor, resulta la desaparición de la posibilidad de multiplicidad de criterios, desde que ahora el intérprete no las podrá interpretar a favor del acreedor ni tampoco buscar términos medios. En consecuencia, si se viola una regla de interpretación de los contratos se viola una proposición y, por lo tanto, la norma jurídica a que ella pertenece. De lo que se desprende que es factible recurrir de casación en el fondo por haberse infringido, en la sentencia en que se declaró la interpretación hecha, alguna proposición constitutiva de una regla de interpretación de los contratos.

4.7 Reglas no legales de interpretación contractual.

Hay, empero, otras reglas que denominaremos no legales de interpretación de los contratos y que podrían ayudar al intérprete en la fijación del sentido de la convención discutida. En la perspectiva del sistema subjetivo de interpretación es normal que el juez pueda utilizar las reglas no legales. La meta perseguida, la voluntad psicológica de las partes, justifica la consideración de todo principio o directiva existente capaz de servir de base a los razonamientos del intérprete.

Obviamente que las reglas no legales de interpretación, ni directa ni indirectamente sancionadas por el legislador, constituyen meras recomendaciones, pudiendo los jueces prescindir libremente de ellas.

4.8 Misión de la Corte Suprema.

La interpretación del contrato corresponde soberanamente a los jueces del fondo y escapa al control de la Corte Suprema. Si el juez se equivoca al interpretar el contrato, más bien que las normas de que se trata, infringiría el contrato mismo. Los jueces del fondo son soberanos para interpretar la voluntad de los contratantes, indagar cuál ha sido su intención y el sentido que debe darse a las cláusulas de la convención. La Corte Suprema sólo interviene cuando hay violación de ley, que se cometería en las siguientes hipótesis:

- i. Los jueces del fondo establecen la existencia de un contrato determinado, pero le atribuyen consecuencias o efectos diversos de los que prevé la ley. De este modo, desconociendo las necesarias consecuencias del contrato, los jueces del fondo infringen la ley que le atribuye tales efectos.
- ii. Los jueces del fondo, a pretexto de interpretar el contrato, no pueden desnaturalizarlo y rehacerlo. La Corte Suprema está autorizada para actuar y hacer respetar el principio de que el contrato es ley para las partes contratantes.

Tema 5: Crítica Personal al Sistema Subjetivo de Interpretación Contractual.

Aseveramos que el sistema subjetivo de interpretación de los contratos es otra consecuencia de la concepción voluntarista del contrato y el principio o dogma de la autonomía de la voluntad.

5.1 El carácter ficticio del sistema subjetivo de interpretación.

La finalidad perseguida por el régimen tradicional de interpretación de los contratos es descubrir la voluntad subjetiva o interna de las partes contratantes, sus intenciones para zanjar el litigio, la contienda sobre el alcance de la convención, según lo que esa voluntad y esas intenciones establezcan. El intérprete es concebido más como un psicólogo que como un jurista. Perlas voluntades de los seres humanos con demasiada frecuencia son frágiles, contradictorias, inestables, caprichosas, incluso arbitraria. Por otra parte, ni siquiera es nítido el contenido semántico de la voluntad. Asimismo, la voluntad interna, la real voluntad psicológica es incognoscible.

Cualesquiera que sean las circunstancias, se ordena al intérprete buscar la voluntad interna de las partes, aun para resolver la duda más pequeña, siendo muy probable que las partes ni siquiera las

hubieren previsto. Es entonces un engaño de la teoría clásica insistir en la búsqueda de intenciones comunes allí donde sólo pueden encontrarse intenciones divergentes.

Por consiguiente, nos parece que debería eliminarse de la interpretación de los contratos toda referencia a las voluntades tácitas, probables o virtuales de los contratantes. Estas nociones no tienen ningún sentido. O hay elementos de convicción suficientemente fuertes y entonces la voluntad es real, o no los hay, y entonces la voluntad es impenetrable; inútil por ende a la interpretación. Vale decir que llegado el momento de la interpretación, el contrato no interesa como acto genético de constitución de la relación jurídica sino que como relación jurídica ya formada. Al instante de su interpretación el contrato es independiente del pasado, de lo que las partes querían cuando lo celebraron. Tal es nuestra conclusión personal. Otra es la actual realidad en la legislación y jurisprudencia nacional.

5.2 El carácter individualista del sistema subjetivo de interpretación contractual.

El individualismo, es desde el punto de vista jurídico, puede analizarse desde dos aspectos: según se considere **al individuo como fin del derecho o como fuente del derecho**. Que el individuo sea **fin del derecho** es indiscutible para los espíritus no totalitarios. La afirmación de que el individuo sea **la única fuente de derechos y obligaciones** implica rechazar todo vínculo jurídico que no repose en la voluntad humana. Pero lo anterior es una quimera. El contrato es un hecho social. Es una medida que es variable, la voluntad no puede dejar de plegarse a las exigencias del medio social que desarrolla constante influencia sobre los particulares. Sólo aquel que razona a partir del hombre aislado puede afirmar la autonomía del individuo.

El individualismo es una doctrina que, al afirmar que la sola voluntad del individuo, al margen de todo juicio de valor sobre su contenido, es la fuente de los derechos subjetivos, no puede ser aceptada. En lo relativo a la interpretación de los contratos, debería rechazarse el principio de la voluntad soberana, corrigiéndolo mediante la consideración, por el intérprete, de los elementos sociales susceptibles de proveer los modelos aptos para determinar, sin ficciones, los derechos y obligaciones que el contrato interpretado ha hecho nacer.

Unidad 5: Responsabilidad Civil Extracontractual.

Tema 1: Generalidades.

1.1 El hecho ilícito como fuente de obligaciones.

El artículo 1437 del CC previene que las obligaciones nacen de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos. Los delitos y cuasidelitos son, en otros términos, fuente de responsabilidad. Esta responsabilidad se traduce, generalmente, en la necesidad en que se encuentra una persona de indemnizar los daños ocasionados por el delito o cuasidelito. El artículo 2314 del CC establece que el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización.

1.2 Concepto de delito y cuasidelito.

El delito y cuasidelito se caracterizan porque son hechos ilícitos y causan daño. El artículo 2284 del CC advierte: **“Si el hecho es ilícito y cometido con la intención de dañar, constituye un delito; en tanto que si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito”.**

Difieren, por lo tanto, el delito del cuasidelito por un elemento o facto de carácter psicológico. En el delito hay dolo, malicia, intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. En el cuasidelito no hay intención de dañar sino descuido, imprudencia, negligencia, falta de diligencia o cuidado. El delito, pues, es el hecho dañino e intencional; el cuasidelito es el hecho culpable y perjudicial.

1.3 Interés de la distinción.

Es prácticamente ociosa. Sus consecuencias son idénticas, en principio, y obligan en los mismos términos a la reparación del daño causado. La extensión de la obligación de indemnizar perjuicios se mide exclusivamente por la magnitud del daño. El artículo 2329 del CC declara: “Todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”.



1.4 Delito y cuasidelito civil; delito y cuasidelito penal.

El delito y el cuasidelito civil son hechos ilícitos, cometidos con dolo o culpa, y que causan daño. El delito y el cuasidelito penal son igualmente hechos ilícitos, dolosos o culpables, penados por la ley. La ley civil no es casuística y se contenta con una fórmula general; merecen el calificativo de

delito y cuasidelito civil los hechos ilícitos y perjudiciales y se les sanciona, en general, con una pena única: la indemnización de los perjuicios proporcionada al daño causado. Caracteriza al delito y cuasidelito penal, en consecuencia, el hecho de encontrarse penados por la ley. La diferencia de criterios se justifica sobradamente. El hecho civilmente ilícito crea un problema de orden privado y enfrenta al autor del daño con su víctima. El hecho penalmente ilícito pone en conflicto al responsable con la sociedad toda.

Se sigue como consecuencia que un hecho puede constituir, a la vez, delito o cuasidelito civil y penal si, penado por la ley, causa igualmente un daño, como el homicidio, el robo, las lesiones, etc. Pero puede igualmente suceder que el hecho sea solamente delito o cuasidelito penal o exclusivamente delito o cuasidelito civil. Lo será en el primer caso, cuando he hecho, sancionado por la ley penal, no causa un daño, como la mendicidad, la vagancia o las tentativas. Lo será, en el segundo caso, si causa daño y la ley penal no le ha asignado una pena, como la ingratitud del donatario, el fraude pauliano y la generalidad de los cuasidelitos contra las cosas.

1.5 Responsabilidad penal y responsabilidad delictual o cuasidelictual civil.

La **responsabilidad penal** resulta de la comisión de un delito o cuasidelito penal. Se hace efectiva mediante el ejercicio de la acción penal que tiene como objetivo el castigo del culpable, esto es, la aplicación de sanciones de carácter penal. La **responsabilidad civil** es el resultado de que se cometa un delito o cuasidelito civil. Se la persigue ejercitando la acción civil, encaminada, sustancialmente, a la indemnización pecuniaria del daño. Como el hecho suele ser, al mismo tiempo, civil y criminalmente ilícito, ambas responsabilidades pueden coexistir.

Pero ambas responsabilidades son independientes y su coexistencia resulta sólo de que el mismo hecho es, simultáneamente, civil y criminalmente delictuoso. El artículo 2314 del CC dispone: “La obligación de indemnizar perjuicios del que cometió un delito o cuasidelito civil es sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. El artículo 11 del CPP señala: “Del hecho penalmente ilícito nace una acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer acción civil para la restitución de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado”.

Entre las diferencias más destacadas de ambas clases de responsabilidades, encontramos las siguientes:

a) Por de pronto, las sanciones difieren.

Mientras los delitos o cuasidelitos civiles se sancionan con la indemnización o reparación de los daños causados; los delitos o cuasidelitos penales acarream sanciones de carácter represivo, encaminadas a proteger a la sociedad de la acción desquiciadora del delincuente.

b) Diversa es la jurisdicción llamada a conocer y juzgar de una y otra responsabilidad.

De la responsabilidad penal conocen y juzgan los tribunales con jurisdicción en lo criminal, mientras que la responsabilidad civil puede perseguirse ante la justicia civil o criminal, a menos que la acción civil tenga por objeto la restitución de la cosa o su valor porque, en tal caso, debe deducirse ante el juez que conoce del proceso criminal.

c) Distinta es, también, la capacidad necesaria para incurrir en responsabilidad penal y civil.

La capacidad para contraer una responsabilidad penal se adquiere a los dieciséis años, los mayores de esta edad y menores de dieciocho sólo son responsables a condición de que el Juez de Menores declare que han obrado con discernimiento. La plena responsabilidad penal comienza a los dieciocho años. La capacidad para ser responsable civilmente se adquiere a los siete años, los mayores de siete y menores de dieciséis son responsable a condición de que, a juicio del tribunal, hayan obrado con discernimiento. La plena responsabilidad civil comienza a los dieciséis años.

d) Difieren ambas responsabilidades en cuanto a las personas a quienes afectan.

La responsabilidad penal sólo puede afectar a quien ha delinquido, en otros términos, es personalísima. Por la naturaleza de las sanciones sólo puede recaer en una persona natural. La responsabilidad civil puede recaer sobre los herederos y pesa tanto sobre las personas naturales como sobre las personas jurídicas.

e) Distintas son las personas que pueden perseguir la responsabilidad civil y criminal.

Pueden ejercitar la acción penal, salvo que se trate de delitos de acción privada, toda persona y aún de oficio el juez puede perseguir la responsabilidad penal. La acción civil, por su parte, sólo compete al que ha sufrido el daño y a sus herederos.

f) Diferentes son las normas que rigen la prescripción.

La acción penal prescribe en términos que fluctúan entre quince años y seis meses, según la gravedad de la pena aplicable al delito o cuasidelito. La acción civil prescribe cuatro años, contados desde la perpetración del hecho.

1.6 Responsabilidad contractual y responsabilidad delictual o cuasidelictual.

La responsabilidad contractual proviene del incumplimiento de un contrato y consiste en indemnizar los perjuicios resultantes de la infracción. Supone esta responsabilidad un vínculo jurídico preexistente entre el autor del daño y la víctima del mismo. La responsabilidad delictual y cuasidelictual proviene de la ejecución de un hecho ilícito, doloso o culpable. Ningún vínculo

previo ligaba al autor del daño y a quien lo sufre y es el hecho ilícito y perjudicial es que genera la obligación.

Autores de la talla de Planiol combate este concepto dual de la responsabilidad, pues consideran que tiene siempre el mismo origen delictual; dejar de cumplir las obligaciones de un contrato es cometer un hecho ilícito. Ambas clases de responsabilidades suponen una obligación anterior; en el caso de los delitos y cuasidelitos la obligación dañada sería la de no dañar a otro.

Fácil es percibir hondas **diferencias entre ambas clases de responsabilidad:**

a) En relación con la gradación de la culpa.

En materia contractual la culpa admite gradaciones; puede ser grave, leve y levísima, es deudor es responsable cuando incurre en el grado de culpa que corresponda, de acuerdo con la naturaleza del contrato. En materia delictual y cuasidelictual la culpa no admite gradaciones.

b) Sustancial es la diferencia en cuanto al peso de la prueba.

Si se trata de hacer valer una responsabilidad contractual, debe el acreedor simplemente probar la existencia de la obligación; el incumplimiento se presume culpable. Toca al deudor, para exonerarse de responsabilidad, acreditar que ha empleado la debida diligencia o cuidado, conforme lo señalado en el artículo 1547 del CC. La regla es diametralmente opuesta para la responsabilidad delictual y cuasidelictual; el acreedor deberá probar que el daño causado es imputable a culpa del que lo ocasionó, salvo calificadas excepciones.

c) Diversa es igualmente la capacidad, más amplia en materia delictual.

La plena capacidad contractual se adquiere a los dieciocho años. La capacidad plena en materia delictual y cuasidelictual se logra a los dieciséis años; aun el menor de esta edad y mayor de siete, es responsable si el juez estima que obró con discernimiento.

d) Otra importante diferencia dice relación con la solidaridad.

Los varios deudores que violan una obligación derivada de un contrato, no son solidariamente responsables, conforme lo dispuesto en el artículo 1511 del CC. Los varios autores de un delito o cuasidelito son solidariamente responsables del daño causado, conforme lo señalado en el artículo 2317 del CC.

e) Diversas son las reglas que rigen la prescripción de las acciones encaminadas a hacer efectiva una y otra responsabilidad.

La acción para perseguir la responsabilidad derivada del delito y cuasidelito prescribe en cuatro años, contados desde la perpetración del hecho, conforme al artículo 2332 del CC. En cambio, la acción para hacer efectiva la responsabilidad contractual prescribe, regularmente, en cinco años, de acuerdo al artículo 2515 del CC.

1.7 Cúmulo u opción de responsabilidades.

Se traduce en averiguar si el incumplimiento de la obligación emanada de un contrato da origen a una responsabilidad exclusivamente contractual o si, originando igualmente una responsabilidad delictual o cuasidelictual, puede el acreedor elegir una u otra para obtener la reparación del daño. En el terreno de la responsabilidad contractual, gozaría particularmente el acreedor de la inestimable ventaja de no verse obligado a probar la culpa, pero no podría responsabilizar al deudor sino de la clase de culpa que corresponda según la naturaleza del contrato. En el campo de la responsabilidad delictual o cuasidelictual, el acreedor deberá probar la culpa. La doctrina rechaza el cúmulo u opción de responsabilidades y la jurisprudencia de nuestros tribunales se inclina en el mismo sentido.

1.8 Fundamento de la responsabilidad delictual.

Nuestro CC adopta la doctrina llamada clásica. El fundamento de la responsabilidad se encuentra en la culpa del autor del daño. La responsabilidad requiere que el daño sea imputable; si hay culpabilidad hay responsabilidad. Tal es la teoría de la responsabilidad subjetiva, o a base de la culpa; la culpa aquiliana, que es una especie de pecado jurídico.

Diversas disposiciones del CC muestran inequívocamente que se adopta esta concepción clásica:

- i. Por de pronto, queda obligado a la indemnización el que comete un delito o cuasidelito que se definen como actos ilícitos, dolosos o culpables, que causan daño, conforme al artículo 2284 del CC.
- ii. Responden por los incapaces las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2319 del CC; el dueño del edificio es responsable de los daños que ocasione su ruina por haber faltado al cuidado de un buen padre de familia, conforme al artículo 2323 del CC, etc.

1.9 Crítica de la responsabilidad subjetiva y medios de paliar sus inconvenientes.

La crítica fundamental consiste en que no satisface adecuadamente las necesidades de la hora presente. La necesidad de probar la culpa del autor del daño plantea a la víctima un arduo problema. Por otra parte, la causa de numerosos accidentes permanece oscura o simplemente ignorada. En todos los casos en que la víctima no logre probar la culpa del autor del daño, será ella responsable, en definitiva, porque habrá de soportarlo, sin derecho de reclamar contra el causante.

Para paliar estos inconvenientes, las leyes, la doctrina y la jurisprudencia, sin alterar el fundamento subjetivo de la responsabilidad, han adoptado diversas medidas o soluciones:

- i. Para liberar de la prueba de la culpa, el legislador ha establecido en favor de la víctima diversas presunciones legales. Gracias a éste subterfugio, se mantiene el respeto del principio tradicional, pero en el hecho, la responsabilidad se libera de la idea de culpa.
- ii. Por otra parte, la jurisprudencia ha extendido el concepto de culpa cada vez más. De este modo, ha llegado a considerar que el ejercicio abusivo de un derecho puede importar culpa y generar responsabilidad y que puede haber culpa en no ponerse a tono con el progreso.
- iii. En fin, se ha discurrido ampliar el campo de la responsabilidad contractual, más favorable a la víctima porque invierte la carga de la prueba de la culpa. Se supone que, a lo menos ciertos contratos, producen o generan una obligación de seguridad, por ejemplo, el contrato de trabajo. El accidente probaría la infracción de esta obligación de seguridad y posibilitaría el cobro de la respectiva indemnización de modo que a la contraparte le correspondería probar que no se ha debido a su culpa.

1.10 Responsabilidad objetiva o sin culpa.

La reacción contra la concepción subjetiva de responsabilidad se inicia a fines del siglo pasado. Se intenta de eliminar la culpa de la noción de responsabilidad. La responsabilidad es puramente objetiva. Un elemento totalmente diverso sirve de fundamento a la responsabilidad: el riesgo. La responsabilidad es un problema de causalidad y no de imputabilidad. El autor del daño es responsable por el solo hecho de haberse causado. La posesión de ciertos bienes, el ejercicio de determinadas actividades, engendra un riesgo o peligro de causar un daño. De esta manera, quien desarrolla una actividad peligrosa y crea un riesgo, debe soportar las consecuencias, justa contrapartida del beneficio o del agrado que dicha actividad le reporta. La teoría del riesgo inspiró en el pasado a la legislación laboral.

Tema 2: Elementos de la Responsabilidad.

2.1 Enumeración.

El artículo 2284 del CC ha dicho que el hecho voluntario y no convencional de que nace la obligación, si es lícito, constituye un cuasicontrato; y si es ilícito, un delito o cuasidelito. De este modo, la ley caracteriza los delitos y cuasidelitos, en primer término, por su condición de hechos ilícitos. En verdad, el hecho es ilícito por sus consecuencias, por la responsabilidad que genera, especialmente como resultado del daño que causa. Los artículos 2314 y 2329 del CC destacan dos factores esenciales de la responsabilidad: el daño y la culpa o dolo. Es preciso añadir que ente ambos elementos debe mediar una relación de causa a efecto, y todavía, que la persona a quien se trata de hacer responsable por el daño causado por su culpa o dolo esté dotada de capacidad.

Así resulta que son cuatro los elementos o condiciones de la responsabilidad delictual o cuasidelictual:

- i. El daño.
- ii. La culpa o dolo.
- iii. Una relación de causalidad entre el dolo o culpa y el daño.
- iv. La capacidad delictual.

Reunidas estas condiciones el hecho engendra responsabilidad delictual o cuasidelictual, constituye un delito o cuasidelito y, en suma, es ilícito.

2.2 El daño, elemento esencial del delito y cuasidelito.

Para que el hecho constituya un delito o cuasidelito es menester, en primer lugar, que cause daño, conforme a los artículos 1437 y 2314 del CC que lo establecen perentoriamente. La obligación de indemnizar perjuicios supone necesariamente que se haya ocasionado un daño. En suma, el daño es un elemento esencial del delito y cuasidelito civiles.

a) Concepto de daño.

Daño es todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida de un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial. Basta que la víctima haya sido privada, como consecuencia del hecho ilícito, de una legítima ventaja. No implica el daño necesariamente la pérdida de un derecho.

b) Caracteres del daño.

Para que el daño merezca ser indemnizado es preciso que sea cierto. Un perjuicio puramente eventual, un daño meramente hipotético no debe considerarse; mal podría el juez fijar su cuantía y duración. Pero el daño puede ser futuro, el cual se traduce en un lucro cesante.

c) Daño material y daño moral.

El daño material consiste en una lesión de carácter patrimonial. La víctima sufre un perjuicio pecuniario por el menoscabo de su patrimonio o de sus medios de acción. El daño puede afectar a la persona física, como una lesión corporal, o a los bienes de dicha persona, como la destrucción de una cosa de que es dueña.

El daño moral consiste en el dolor, la aflicción, el pesar que causa a la víctima el hecho ilícito; no la lesiona en su patrimonio, sino en sus sentimientos, sus afectos o creencias. El daño moral puede tener, y es lo más frecuente, proyecciones de orden patrimonial. Pero el daño puede ser, también, puramente moral, sin consecuencias o proyecciones de carácter patrimonial.

d) Indemnización del daño moral.

Algunos autores se pronuncian contra la indemnización del daño moral, pero la generalidad admite que es indemnizable y nuestra jurisprudencia está hoy uniformemente acorde con esta doctrina. Se afirma que no sería indemnizable el daño moral porque una indemnización pagada en dinero no repararía un daño de esta clase. Por otra parte, el precio del dolor de la víctima sería siempre caprichosamente fijado.

Hoy en día se piensa que el daño moral, como todo daño, debe ser indemnizado:

- i. Por de pronto, la ley no distingue. El artículo 2314 se refiere al daño sin otro calificativo y el artículo 2329 más explícitamente declara indemnizable todo daño que se pueda imputar a malicia o negligencia de otra persona.
- ii. La regla del artículo 2331, que excluye la indemnización del daño moral, carecería de sentido si tal fuera la regla general.
- iii. La Constitución Política de la República, en su artículo 19 dispone en su letra i que una vez dictado el sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido.
- iv. Por último, el artículo 34 de la Ley No. 16.643 sobre abusos de publicidad, proviene que la indemnización de perjuicios por los delitos en ella contemplados podrá hacerse extensiva al daño pecuniario que fuere consecuencia de la depresión anímica o psicológica sufrida por la víctima o su familia con motivo del delito, y a la reparación del daño meramente moral que tales personas acrediten haber sufrido.

e) Regla especial del artículo 2331 del CC.

Si se trata de atentados contra el honor o crédito de una persona, esto es, calumnias o injurias, que no se han inferido por los medios de publicidad que establece la Ley No. 16.643 sobre abusos de publicidad, rige la regla especial del artículo 2331 del CC que establece: “Las imputaciones injuriosas contra el honor o crédito de una persona no dan derecho para demandar una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pro ni aún entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare la verdad de la imputación”. Por excepción, en este caso, el daño moral no es indemnizable en dinero.

f) Clasificaciones del daño.

i. Daño emergente.

Consiste en la pérdida o disminución patrimonial actual y efectiva que sufre la víctima del accidente. Puede consistir en la destrucción o deterioro de cosas que posean valor económico, en

los costos en que ha de incurrir la víctima a causa del accidente o bien en un perjuicio puramente económico.

ii. Lucro Cesante.

Es la pérdida del incremento neto que habría tenido el patrimonio de la víctima de no haber ocurrido el hecho por el cual un tercero es responsable. Su determinación considera un grado razonable de probabilidad en los ingresos futuros. Será determinado usualmente por medio de presunciones e informes periciales.

iii. Daño Moral.

Es el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida. El CC no contiene una definición de daño moral; la única norma que se refiere a él indirectamente lo hace para excluir su reparación a propósito de la injuria. A pesar de los intentos por definirlo sigue siendo un concepto de límites difusos.

g) Principios que rigen la determinación del daño indemnizable.

- i. La indemnización debe ser completa.
- ii. Solo comprende daños directos.
- iii. El daño debe ser cierto.
- iv. El daño debe probarse.
- v. Sólo comprende los daños sufridos personalmente por la víctima.
- vi. La regulación del monto de la indemnización es facultad privativa de los jueces del fondo.

h) Principios que rigen la determinación del daño moral.

- i. El daño moral no requiere prueba.
- ii. Atendida la naturaleza de los bienes o intereses lesionados, su determinación no está sujeta a parámetros exactos y está entregada a la apreciación prudencial del juez.
- iii. La determinación de la indemnización considera normalmente criterios punitivos, tales como la gravedad de la culpa o la potencia económica del demandado.

i) Consecuencias de que el pago sea completo.

- i. La indemnización comprende tanto el daño material como moral.
- ii. Comprende reajustes e intereses.
- iii. Sólo comprende el daño efectivo y no puede ser fuente de enriquecimiento para la víctima.

2.3 El Dolo y la Culpa.

a) Principio general.

El daño no genera responsabilidad sino a condición de que sea imputable a dolo o culpa. Ejecutado con dolo, el hecho importa un delito; cometido con culpa, constituye un cuasidelito, conforme al artículo 2284 del CC.

b) Concepto de dolo.

El artículo 44 del CC lo define como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Supone un propósito preconcebido de dañar, el deseo de ver realizado el daño que es consecuencia de una acción u omisión. En rigor, si el agente obra a sabiendas de que causará daño, pero sin intención de producirlo, no hay dolo. Pero el acto ejecutado en tales circunstancias será, sin duda, gravemente culpable y la culpa grave, en sus consecuencias civiles, se equipara al dolo.

c) Concepto de culpa.

El CC ha definido igualmente a la culpa en el artículo 44 del CC y aunque hace una clasificación tripartita y distingue entre culpa grave, leve y levísima, se cuida de advertir que culpa o descuido sin otra clasificación, significa culpa o descuido leve. La culpa leve se encuentra definida como la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. En suma, la responsabilidad cuasidelictual requiere que el autor incurra en culpa leve, no emplee elucido ordinario, la diligencia que los hombres emplean normalmente.

d) Infracción de leyes y reglamentos.

La apreciación de la conducta del autor del daño es indispensable para decidir si ha obrado con culpa. Pero el examen de esta conducta resulta inoficioso cuando el daño proviene de actos ejecutados en contravención a las leyes y reglamentos. Tal es la que suele llamarse culpa contra la legalidad. Por ejemplo, la conducta de un automovilista en un accidente será obviamente culpable si éste se produjo con infracción de los reglamentos de tránsito encaminados a prevenirlo.

e) Ley del Tránsito.

El artículo 170 de la Ley No. 18.290 de tránsito señala: “Toda persona que conduzca un vehículo en forma de hacer peligrar la seguridad de los demás, sin consideración de los derechos de éstos o infringiendo las reglas de circulación o de seguridad establecidas en esta ley, será responsable de los perjuicios que de ello provengan”. El artículo 171 de la misma ley dispone en todo caso que el mero de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido.

Sin embargo, en los artículos 172, 173 y 174 se contemplan una serie de presunciones de responsabilidad de los conductores. Así, por ejemplo, el artículo 172 establece entre otras presunciones de responsabilidad del conductor: “Conducir a mayor velocidad que la permitida o a una velocidad no razonable o prudente, conducir contra el sentido de la circulación, conducir en condiciones físicas deficientes o bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes, negarse sin causa a que se le practique el examen de alcoholemia, etc.”

f) Gravedad de la culpa.

Es indudable que la culpa extracontractual no admite las gradaciones de la contractual, pero se añade que en el campo delictual la gravedad de la culpa es indiferente, que la culpa más ligera genera responsabilidad. Esta conclusión, sin embargo, contradice lo dispuesto en el artículo 44 del CC que prescribe que culpa o descuido, en general, significa culpa o descuido leve. Por otra parte, a las personas no puede exigírseles sino un celo, una diligencia, un cuidado medianos. No es razonable que el ciudadano medio deba emplear en sus actos una actividad ejemplar, una diligencia esmerada, como la que un hombre juicioso pone en sus negocios importante.

En Francia no se admite la clasificación tripartita de la culpa, toda culpa genera responsabilidad contractual y es lógico que se considere, asimismo, que cualquiera clase de culpa produce responsabilidad extracontractual. En nuestro CC, si admitimos que toda culpa engendra responsabilidad extracontractual, se establecería una clara e injustificada diferencia para ambas responsabilidades.

g) Culpa en el ejercicio de un derecho o abuso del derecho.

La ejecución de un acto lícito por excelencia, no puede constituir un delito o cuasidelito, esto es, un acto ilícito. Esta conclusión es de una lógica aparentemente irrefutable, pero es jurídicamente inadmisibles. Supone, implícitamente, el absolutismo de los derechos de que el titular de los mismos los puede ejercer libremente, a su entero arbitrio. Pero los derechos no son ni pueden ser facultades arbitrarias; son medios de lograr determinados fines útiles.

De este modo, en suma, el ejercicio de un derecho, desviándolo de su natural destino, importa un abuso, un acto culpable capaz de comprometer la responsabilidad del titular. En lo que va corrido del siglo, la concepción de la relatividad de los derechos y del abuso que es una de sus consecuencias, no ha dejado de ganar terreno.

h) Criterio para juzgar del abuso del derecho.

El abuso del derecho es el resultado de una combinación, en síntesis, de dos factores: un factor que podría llamarse funcional y otro intencional. Debe atenderse a la función o finalidad del derecho. El derecho debe ejercitarse conforme a su destino, al espíritu de la respectiva institución, al fin económico social que persigue. Esta finalidad o función de los derechos es variable. Será preciso atender, igualmente, a los móviles que guían al titular del derecho, a los fines que se propone conseguir ejercitándolo. Si estos fines concuerdan con la función del derecho, éste se

habrá ejercitado normalmente; si no existe tal concordancia, el ejercicio del derecho será abusivo y podrá generar la consiguiente responsabilidad. Entre los móviles o motivos ilegítimos debe contarse, en primer término, la intención de dañar. Los derechos no se confieren para dañar a terceros y su ejercicio intencionalmente dañino no puede constituir un fin lícito, un motivo legítimo. Pero tampoco es legítimo el ejercicio culpable, esto es, negligente o descuidado, que se traduce igualmente en una desviación del derecho de su destino natural.

i) Derechos absolutos.

Se exceptúan de lo dicho ciertos derechos, de carácter absoluto, que su titular puede ejercer arbitrariamente, no importa con qué fin, por ejemplo, la facultad de los ascendientes de negar su consentimiento al matrimonio del menor sin expresar la causa del disenso conforme al artículo 112 del CC; el derecho de pedir la división de los bienes comunes conforme al artículo 1317 del CC; el derecho del propietario de cortar las raíces y ramas del árbol que penetra en su propiedad conforme al artículo 942 del CC, etc. Tales derechos pueden ser ejecutados impunemente, cualquiera que sea el motivo que impulse a su titular.

j) Derecho comparado.

Algunas legislaciones dejan el problema por entero al criterio del juez; otras atienden a la intención dañina; otras, en fin, tienen en cuenta la desviación del derecho de su finalidad natural.

k) El abuso del derecho en nuestra legislación.

Nuestro CC no contiene ninguna disposición de carácter general que consagre la teoría del abuso del derecho. Solamente se encuentran algunas disposiciones aisladas, inspiradas en el principio. Ejemplo de ello, es el artículo 2110 del CC que dispone que la sociedad expira por la renuncia de los socios, pero no es válida aquella que se hace de mala fe o intempestivamente. Un criterio semejante lo encontramos en el artículo 45 de la LDQ que dispone que si la solicitud de quiebra fuera desechada en definitiva, el deudor podrá demandar indemnización de perjuicios al acreedor, si probare que éste ha procedido culpable o dolosamente.

l) La existencia del dolo y culpa es una cuestión de derecho.

Toca a los jueces del fondo decidir soberanamente acerca de los hechos o circunstancias materiales de que se hace derivar la responsabilidad. Tales hechos, a menos que en su establecimiento se violen las leyes reguladoras de la prueba, son intocables por la Corte Suprema. Pero la apreciación o calificación de estos hechos para decidir si son dolosos o culpables, es una cuestión de derecho que cae bajo el control de la Corte Suprema.

El dolo y la culpa son conceptos legales, definidos por la ley; se trata de determinar la fisonomía jurídica de los hechos establecidos por los jueces del fondo para hacerlos calzar con los conceptos legales de culpa y dolo. La culpa suele consistir en la infracción de leyes y reglamentos. El problema, en tal caso, es típicamente una cuestión de derecho.

2.4 Relación de Causalidad entre el Dolo o Culpa y el Daño.

a) La regla general.

No es bastante para incurrir en responsabilidad que el hecho se haya cometido con dolo y culpa y que haya producido un daño. Es menester que el daño sea el resultado de la culpa o dolo, esto es, que medie entre ambos factores una relación de causalidad. Se producirá esta relación de causalidad cuando el dolo o culpa ha sido necesaria del daño, de manera que si no hubiera mediado el daño no se habría producido.

Tradicionalmente se ha sostenido por la doctrina y jurisprudencia que la causalidad exige que entre el hecho y el daño exista una relación necesaria y directa. Que el hecho ilícito sea causa en sentido natural de un daño es condición necesaria pero no suficiente para atribuir el daño a esa conducta.

Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han estimado suficiente para dar por acreditada la causalidad que el hecho sea una condición necesaria del daño, sin el cual éste no se habría producido, aunque concurrieren otras causas. Esta doctrina se conoce como de la equivalencia de las condiciones o *condictio sine qua non*. Señala que todas las causas son equivalente en la medida que individualmente sea condición necesaria para la ocurrencia del resultado dañoso. Así, un daño tendrá tantas causas como hechos hayan concurrido a su ocurrencia. Para determinar si un hecho es condición necesaria basta practicar una supresión hipotética. Aplicando este criterio, si en la producción del daño han intervenido como condición necesaria otros hechos ilícitos atribuibles a otras personas, la persona obligada a indemnizar podrá repetir contra sus autores por la parte que a cada uno corresponda, pero frente a la víctima estará obligada a responder integralmente por el daño causado.

Sólo se indemnizan los daños directos. La pregunta acerca de si un daño es directo o indirecto supone un juicio normativo respecto si el daño puede ser objetivamente atribuible al hecho. No es propiamente un juicio de culpabilidad sino una cuestión normativa que obliga a discernir cuáles consecuencias derivadas causalmente del hecho ilícito resultan relevantes a efectos de dar por establecida la responsabilidad. La exigencia de que el daño sea directo cumple la función de discriminar entre todas las consecuencias dañinas de un hecho aquellas que pueden ser atribuibles al ilícito, estableciendo así un límite a la responsabilidad. La calificación del daño como directo es un juicio que queda sometido al control jurídico por vía de casación.

b) Consecuencias de la necesidad de una relación de causalidad.

Interesa examinar algunas consecuencias de la falta de relación de causa a efecto entre el dolo o culpa y el daño:

- i. La falta de esta relación de causalidad lleva a la exención de responsabilidad cuando el daño es imputable a culpa de la víctima. La culpa de la víctima hace desaparecer total o parcialmente la relación de causalidad y exime de responsabilidad o, cuando menos, la atenúa. Se

producirá la exención de responsabilidad cuando la culpa de la víctima excluya la de su adversario; la responsabilidad quedará atenuada si la culpa de ambos ha concurrido a provocar el daño.

ii. Por la misma razón es problemático obtener la indemnización de daños indirectos. Cuando más se aleja el daño del hecho inicial que lo originó, más difícil resulta establecer entre ambos una relación causal. Llega el momento en que es preciso detenerse en la búsqueda de consecuencias perjudiciales cuya causa primera se hace imposible discernir con certidumbre.

2.5 Capacidad Delictual.

a) El principio general.

Como consecuencia lógica del sistema subjetivo que el CC adopta, es condición esencial de la responsabilidad que el autor del delito o cuasidelito tenga suficiente discernimiento. Desde que el autor está en situación de discernir acerca del sentido de sus actos, responde se sus consecuencias, aunque carezca de la capacidad necesaria para actuar por sí sólo en la vida jurídica. Por este motivo, son plenamente capaces de delito o cuasidelito personas que carecen total o parcialmente de capacidad para contratar.

b) Mayor latitud de la capacidad delictual.

La capacidad delictual y cuasidelictual es más amplia que la capacidad contractual. Diversas razones justifican sobradamente la mayor latitud de la capacidad delictual:

- i. La plena capacidad contractual supone una completa madurez intelectual, mientras que la plena capacidad delictual requiere sólo tener conciencia del bien y del mal, el poder de discernir entre el acto lícito y el acto ilegítimo y perjudicial.
- ii. El delito y el cuasidelito ponen a la víctima ante un inopinado o imprevisto deudor; se elige a los deudores contractuales, pero no se tiene ocasión de elegir a los deudores cuya obligación arranca de un delito o cuasidelito.

c) Personas incapaces de delito y cuasidelito.

En materia delictual la capacidad constituye la regla general y la incapacidad la excepción. El artículo 2319 del CC, que establece las incapacidades, es de derecho estricto. Son incapaces:

- i. Los dementes.
- ii. Los infantes.
- iii. Los mayores de siete años y menores de dieciséis que hayan obrado sin discernimiento.

d) Incapacidad de los dementes.

La expresión demente está tomada en el sentido amplísimo que le atribuye el CC y el Código Penal. La demencia debe ser contemporánea de la ejecución del hecho; la demencia sobreviniente no exime de responsabilidad. Será responsable el demente que ejecuta el hecho en un intervalo lúcido aunque se encuentre en interdicción. Asimismo, la privación de razón ocasionada por la demencia debe ser total.

e) Responsabilidad del ebrio.

El artículo 2318 del CC dispone que el ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasidelito. La ley supone que el ebrio es culpable de su estado de ebriedad.

f) Incapacidad de los infantes.

El artículo 26 del CC dispone que son incapaces los menores de siete años, esto es, los infantes o niños. Se presume de derecho que tales personas carecen de suficiente discernimiento.

g) Incapacidad del mayor de siete años y menor de dieciséis años.

El inciso segundo del artículo 2319 del CC dispone: “Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de dieciséis ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento”.

h) Responsabilidad del que tiene a su cargo al incapaz.

El artículo 2319 del CC dispone: “Serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia”. El guardián no tiene derecho a repetir contra el incapaz. Esta facultad se confiere a quien responde de un hecho ajeno, siempre que el autor del daño estuviere dotado de capacidad, conforme lo dispuesto en el artículo 2325 del CC.

i) Tendencia de la legislación contemporánea.

Tiende a abolir, en mayor o menor grado, la irresponsabilidad del incapaz. En algunas legislaciones el incapaz debe reparar el daño cuando la reparación no ha podido obtenerse de quien lo tiene a su cuidado; otras otorgan al juez la facultad de condenar al incapaz, cuando la equidad lo exija; el incapaz, en fin, suele ser plenamente responsable.



j) Responsabilidad de las personas jurídicas.

El artículo 39 del CPC establece que la responsabilidad criminal sólo puede recaer en las personas naturales. En cambio, las personas jurídicas son plenamente capaces de delito y cuasidelito. Responden las personas jurídicas de los delitos cometidos por sus órganos, esto es, de las personas a través de quienes se expresa su voluntad. Será obviamente necesario que el órgano obre en el ejercicio de sus funciones.

2.6 Presunciones de Culpa.

El CC exige, como condición de la responsabilidad, **prueba de la culpa**. Para asegurar a la víctima una justa reparación del daño, quebrantando el principio, la ley ha venido en su ayuda y establecido ciertas presunciones de culpabilidad. Las presunciones de culpa, como es obvio, dispensan de la carga de la prueba. La víctima debe acreditar las circunstancias que sirven de

fundamento a la presunción. Probadas estas circunstancias, queda establecida la culpa y su relación de causalidad con el daño. Toca a quien se presume culpable probar que el perjuicio proviene de una causa extraña, que ha empleado la debida diligencia o que no existe una relación de causa a efecto entre la culpa que se le imputa y el daño.

Las presunciones de culpa pueden dividirse en tres grupos:

- Por el hecho propio.
- Por el hecho ajeno.
- Por el hecho de las cosas.

2.6.1 Responsabilidad por el hecho propio.

a) La regla general.

El primer inciso del artículo 2329 del CC dispone: “Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser indemnizado por ésta”. La disposición muestra la concepción subjetiva de la responsabilidad que inspira nuestro CC y destaca sus elementos más salientes: el daño y la culpa o dolo.

b) Las excepciones.

Sentada la regla general, el artículo 2329 señala: “Son especialmente obligados a esta reparación las personas que se encuentran en los casos que se enumeran”. Los casos enumerados, pues, se apartan del principio consagrado en el primer inciso. La singularidad de estos casos consiste en que la culpa del autor se presume. Dichos casos son los siguientes:

- i. Se presume la culpa de quien remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche, conforme lo dispuesto en el segundo número del artículo 2329 del CC.
- ii. Se presume, asimismo, la culpa del que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él, conforme al tercer número del artículo 2329 del CC.

Se ha sostenido que el artículo 2329 del CC establece una presunción general de culpabilidad cuando el daño proviene de un hecho que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a dolo o culpa del agente. No compartimos esta opinión, que altera, en el hecho, los fundamentos de la responsabilidad y el sistema mismo del CC.

c) Accidentes causados por vehículos de tracción mecánica o animal.

El artículo 492 del Código Penal dispone que en los accidentes ocasionados por vehículos de tracción mecánica o animal de que resultaren lesiones o la muerte de un peatón, se presumirá la

culpa del conductor del vehículo, dentro del radio urbano de las ciudades, cuando el accidente hubiere ocurrido en el cruce de calzadas o en la extensión de diez metros anterior a cada esquina. Ocurrido en accidente en otro sitio de la calzada, se presume, al contrario, la culpa del peatón.

2.6.2 Responsabilidad por el hecho ajeno.

a) El principio general.

Por la regla general contemplada en el artículo 2316 del CC, es responsable quien causó el daño y sus herederos. Por excepción, sin embargo, una persona puede resultar responsable del hecho de otro. El artículo 2320 del CC establece la norma fundamental: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. El hecho de que ocasione un daño es significativo de que no empleó la debida vigilancia. Por lo mismo, no es bien correcto hablar de responsabilidad por el hecho ajeno: la responsabilidad proviene más bien de un hecho propio, como es la falta de cuidado o vigilancia. En verdad, se funda en la propia culpa, que, en este caso, se presume.

b) Generalidad de las normas sobre responsabilidad por el hecho ajeno.

El artículo 2320 del CC deja suficientemente claro que, en nuestra legislación, la responsabilidad por el hecho de las personas cuyo cuidado se tiene es de carácter general. Los casos enumerados son simples aplicaciones del principio general.

c) Requisitos de la responsabilidad.

Para que tenga lugar la responsabilidad por el hecho ajeno es menester que concurren los siguientes requisitos:

i. Relación de dependencia entre el autor del daño y la persona responsable.

Es necesaria, como se comprende, una relación de dependencia o subordinación; la persona responsable debe estar revestida de cierta autoridad y el autor material del daño, sujeto a su obediencia. La prueba de esta relación incumbe a la víctima.

ii. Que ambas sean capaces de delito o cuasidelito.

Si el que tiene a su cuidado a otra persona es incapaz, lógicamente que es irresponsable. Pero también ha de ser capaz el dependiente o subordinado. No cabe presumir la culpa del que tiene un incapaz a su cargo; para hacerle responsable es menester probar su culpa.

iii. Que se pruebe la culpabilidad del dependiente o subordinado.

La ley presume la culpa de la persona que tiene otra a su cuidado; no se presume y debe consiguientemente probarse la culpa del subordinado.

d) Carácter de la presunción.

La presunción de culpabilidad es simplemente legal. En otros términos, la persona civilmente responsable puede exonerarse de responsabilidad probando que empleó la diligencia o cuidado

debidos. El inciso final del artículo 2320 del CC dispone: “Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.

e) Responsabilidad del subordinado.

La responsabilidad por el hecho ajeno no excluye la del autor directo del hecho nocivo. Ambas responsabilidades coexisten y la víctima puede accionar contra ambos. Sin embargo, esta doble responsabilidad resulta puramente teórica, pues, generalmente, el autor del daño directo será insolvente.

f) Acción de la persona civilmente responsable contra el autor del daño.

La persona civilmente responsable que ha indemnizado el daño tiene derecho para que el autor del mismo le reintegre lo pagado. El artículo 2325 del CC establece: “Las personas obligadas a la reparación de los daños causados por las que de ellas dependen, tendrán derecho para ser indemnizadas sobre los bienes de éstas, si los hubiere”. Este recurso contra el autor no tiene cabida cuando:

- i. Si el que perpetró el daño lo hizo por orden de la persona a quien debía obediencia.
- ii. Si el autor del daño es incapaz.

g) Responsabilidad de los padres.

El artículo 2320 del CC dispone: “El padre y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”. De conformidad al artículo 224 del CC toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos. El cuidado personal del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio corresponde al padre o madre que lo hayan reconocido. Si no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez. El padre, y a falta de éste la madre, es responsable de todo delito o cuasidelito cometido por los hijos en las circunstancias anotadas, sea que se cometan dentro o fuera de la casa paterna.

La presunción de culpabilidad es simplemente legal. Puede desvirtuarse, por lo tanto, probándose que no ha habido culpa, esto es, que con la autoridad y el cuidado que su calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho. Esta regla tiene una excepción calificada en el artículo 2321 del CC que señala: “Los padres serán siempre responsables de los delitos y cuasidelitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”. No será lícito a los padres eximirse de responsabilidad probando que emplearon su autoridad y cuidado para impedir el hecho. Incumbe a la víctima la prueba de que el hijo recibió una mala educación o los padres lo dejaron adquirir hábitos viciosos. Los padres, en este caso, son responsables aunque los hijos no habiten en la misma casa; basta que sean menores de edad.

h) Responsabilidad de los tutores y curadores.

El inciso tercero del artículo 2320 del CC señala que el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. La responsabilidad de ellos requiere que el pupilo viva bajo su dependencia y cuidado, por lo tanto, se aplica sólo a los tutores o curadores generales. Si el pupilo es incapaz, no serán responsables sino probándose culpa, conforme al artículo 2319 del CC. Es guardador podrá eximirse de responsabilidad probando que no pudo impedirle hecho, pese a que ejerció la autoridad derivada de su cargo y empleó el cuidado a que estaba obligado.

i) Responsabilidad de los jefes de colegios y escuelas.

El inciso quinto del artículo 2320 del CC señala que los jefes de colegio y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. Es responsable aunque el discípulo sea mayor de edad. Puede eximirse de responsabilidad probando que no le fue posible impedir el hecho delictuoso.

j) Responsabilidad de los artesanos y empresarios.

El inciso quinto del artículo 2320 del CC dispone que los artesanos o empresarios son responsables del hecho de sus aprendices o dependientes mientras están bajo su cuidado. A la víctima le incumbe probar que el delito o cuasidelito se cometió mientras el autor se encontraba bajo el cuidado del empresario o artesano. Cesa la responsabilidad probando la persona civilmente responsable que no pudo impedir el hecho pese a su cuidado y el empleo de su autoridad.

k) Responsabilidad de los amos.

El artículo 2322 del CC establece que los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista. Se refiere esta disposición a la responsabilidad del empleador o empresario por el hecho de sus dependientes. El amo es responsable solamente de los actos ejecutados por el sirviente o criado a condición de que el hecho ilícito se verifique mientras desempeña sus labores o cumple sus órdenes, en el ejercicio de sus funciones.

El inciso final del artículo 2320 del CC dispone: “Pero no responderán de los que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente”.

l) Responsabilidad del dueño de un vehículo.

El artículo 174 de la Ley No. 18.120 de tránsito, dispone que de las infracciones de los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo. El conductor y el propietario del vehículo, a menos que éste probare que el vehículo fue usado sin su conocimiento o autorización expresa o

tácita, serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del uso del vehículo. Asimismo, hay responsabilidad solidaria del funcionario de la municipalidad que otorga licencias de conducir con infracción a las normas legales, y de los establecimientos de revisión técnica que otorguen permisos de circulación con infracción a derecho. También la Municipalidad o el Fisco en su caso serán responsables de los daños productos de accidentes por mal estado del camino o falta de señalización. La responsabilidad del dueño del vehículo es sin perjuicio de la que le quepa a otras personas en virtud del derecho común. El propietario del vehículo puede eximirse de responsabilidad probando que le fue usado sin su autorización expresa o tácita. De conformidad al artículo 38 de la Ley No. 18.290 se presumirá propietario de un vehículo motorizado a la persona cuyo nombre figure inscrito en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, salvo prueba en contrario.

m) Otros casos de responsabilidad por el hecho ajeno.

Diversas leyes especiales han añadido otros casos de responsabilidad por el hecho ajeno:

- i. Las empresas ferroviarias son responsables por los daños causados por sus dependientes.
- ii. La Ley No. 19.733 hace responsable al director de los medios de comunicación social.
- iii. La Ley sobre Almacenes Generales de Depósito dispone que el almacenista responderá, en todo caso, de la efectividad y veracidad de los hechos y declaraciones que allí se refieren. Asimismo, responderá por las pérdidas o deterioros imputables a culpa suya o de sus empleados dependientes.

2.6.3 Responsabilidad por el hecho de las cosas.

Se es también responsable del hecho de las cosas de que una persona es dueña o que están a su servicio. El propietario o la persona que se sirve de la cosa debe vigilarla y mantenerla en estado de que no cause daños. El daño que la cosa ocasiona muestra una falta de vigilancia o cuidado y, por ende, la ley presume la culpabilidad de quien la tiene a su cargo. El CC no contiene una norma general. Se limita a señalar y reglamentar algunos casos concretos que son consecuencialmente los únicos en que se presume la culpabilidad del dueño de una cosa o de quien se sirve de ella. Aparte de esos casos, será menester probar la culpa del dueño o detentador de la cosa.

Casos en que se presume culpable por el hecho de las cosas.

- Daño causado por la ruina de un edificio.
- Daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio.
- Daño causado por un animal.

a) Responsabilidad por la ruina de un edificio.

El artículo 2323 del CC establece que el dueño de un edificio es responsable de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber omitido las necesarias reparaciones, o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. En caso que la cosa pertenezca a varias personas en común, se dividirá entre ellas la indemnización a prorrata de sus cuotas de dominio. Esta regla constituye una excepción a la norma del artículo 2317 del CC que impone una responsabilidad de carácter solidario cuando el delito o cuasidelito se ha cometido por dos o más personas.

El vecino sólo puede invocar la responsabilidad del dueño del edificio siempre que el daño ocurra después de haberle notificado la querella de denuncia de obra ruinosa. Si no dedujo esta querella no tiene derecho a indemnización, porque el daño se produjo, en cierto modo, por su negligencia en acudir a la justicia para evitarlo.

Si se prueba que la ruina del edificio provino del caso fortuito, el dueño puede eximirse de la responsabilidad. Sin embargo, será responsable aún del caso fortuito si se prueba que el caso fortuito, sin el mal estado del edificio, no lo hubiera derribado.

Si el daño causado por la ruina de un edificio proviniera de un vicio de construcción el responsable de los daños no es el dueño del edificio sino el empresario o arquitecto que tuvo a su cargo la construcción. La ruina del edificio puede provenir no sólo de vicios o defectos de construcción, sino de vicios del suelo o de los materiales. El empresario y arquitecto son responsables siempre que la ruina sobrevenga en el plazo de cinco años desde la entrega del edificio o de la recepción definitiva del mismo por la Dirección de Obras Municipales, en su caso.

El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ellas, sea durante la ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes eran responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan dado origen a los daños y perjuicios.

Todas estas responsabilidades prescriben en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales.

b) Responsabilidad por daño que ocasiona la cosa que cae o es arrojada de la parte superior de un edificio.

El artículo 2328 del CC dispone: “El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio y la indemnización se dividirá entre todas ellas”. La víctima deberá probar que la cosa cayó o fue arrojada de una parte del edificio en que el demandante habita. La ley difunde la responsabilidad por lo difícil que resulta precisar quién es el culpable de la caída o de haber arrojado la cosa. Pero, como es natural, esta presunción de responsabilidad cede ante la evidencia de que el culpable es determinada persona.

El inciso segundo del artículo 2328 del CC dispone: “Si hubiere alguna cosa que, de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado, amenace caída y daño, podrá ser obligado a

removerla el dueño del edificio o del sitio, o su inquilino, o la persona a quien perteneciere la cosa o que se sirviese de ella”. Cualquier persona puede pedir la remoción.

c) Responsabilidad por el hecho de los animales.

El artículo 2326 del CC señala: “El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aún después que se haya soltado o extraviado” La responsabilidad del dueño del animal cesará si prueba que tomó adecuadas precauciones para impedir el daño o, en otros términos, que el daño, soltura o extravío no puede imputarse a culpa suya o del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal. El inciso segundo del artículo 2326 del CC dispone que lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva de un animal ajeno. La persona que se sirve de un animal ajeno puede repetir contra el dueño si el daño ha sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño con mediano cuidado o prudencia debió conocer o prever, y de que no le dio conocimiento.

El artículo 2327 del CC señala que el daño causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, por él debe responder la persona que tenga el animal, aunque no sea su dueño y aunque no se sirva de él. La presunción de culpabilidad, en este caso, es de derecho; si el que tiene el animal alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído.

2.7 Acción para Perseguir la Responsabilidad.

a) Sanción del delito y cuasidelito.

Consiste en la necesidad en que su autor se encuentra de reparar el daño causado. En otros términos, el delito y cuasidelito producen como efecto normal, la obligación de indemnizar perjuicios. El artículo 2314 del CC establece que el que ha cometido un delito o cuasidelito es obligado a la indemnización. Pero el ilícito puede dar origen a otras sanciones: revocación de los actos ejecutados por el deudor con motivo del fraude pauliano, revocación de las donaciones por ingratitud del donatario, etc.

b) Sujeto activo de la acción.

La acción corresponde al que ha sufrido un daño y aun al que puede verse expuesto a sufrirlo. La ley, en efecto, no sólo concede una acción cuando el daño se ha producido. Permite igualmente accionar para impedir un daño posible.

b.1) Medidas para evitar un daño contingente.

Para establecer a quien corresponden las acciones encaminadas a precaver un daño contingente, es preciso distinguir si amenaza a personas determinadas o indeterminadas. En el primer caso sólo podrán accionar las personas amenazadas; en el segundo caso se concede acción popular, conforme al principio general contenido en el artículo 2333 del CC. En caso de ejercitarse las acciones populares referidas, si parecieren fundadas, el actor deberá ser indemnizado de todas las

costas de la acción y se le pagará lo que valgan el tiempo y diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que concede la ley en determinados casos.

b.2) Daños en las cosas.

La acción para reclamar la indemnización respectiva corresponderá a todas las personas que tenían derechos en ella o con relación a ella, que hayan resultado menoscabados conforme lo señalado en el artículo 2315 del CC, el cual contiene una enumeración que no es taxativa. Puede igualmente reclamar indemnización, pero en ausencia del dueño, el que tiene la cosa con obligación de responder de ella, como el arrendatario, el comodatario, el depositario, etc.

b.3) Daños a las personas.

Sea de carácter material o moral, puede intentarla, en primer término, la víctima principal o directa. Podrán igualmente accionar las víctimas indirectas del delito o cuasidelito, esto es, aquellos que sufren un daño material o moral a consecuencia del que ha experimentado la víctima principal o directa. Estas personas accionan por derecho propio; su acción proviene del daño que personalmente experimentan y es independiente de la que corresponde a la víctima directa. También podrán intentar la acción los herederos de la víctima, haciendo valer la que incumbía a su causante, conforme lo señalado en el artículo 2315 del CC. El heredero podrá accionar de dos maneras: primero, invocando la acción que correspondía a su causante, víctima del delito; y, segundo, haciendo valer la acción que, por derecho propio, le corresponda, como víctima indirecta del delito o cuasidelito.

c) Sujeto pasivo de la acción.

La acción de indemnización de perjuicios se puede dirigir contra:

- El causante del daño.
- Las personas civilmente responsables.
- El que se aprovechó del dolo ajeno.
- Los herederos de todas estas personas.

c.1) Autor del daño.

La acción se dirige normalmente contra el autor del daño. El artículo 2316 del CC dispone que es obligado a la indemnización el que hizo el daño. Debe considerarse autores a todos los que han concurrido a provocar el daño, sea como autores propiamente tales, sea como cómplices o encubridores. Todos ellos concurrieron a causar el daño, cada cual en su esfera de acción. El artículo 24 del Código Penal establece: “Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva envuelta la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices, encubridores y demás personas legalmente responsables”. Sería absurdo adoptar un criterio

diverso para los delitos y cuasidelitos puramente civiles. Por otra parte, el artículo 2316 del CC hace responsable, hasta la concurrencia del beneficio que reporte, al que se aprovecha del dolo ajeno, sin ser cómplice en él; a contrario sensu, el cómplice responde del total de los perjuicios.

c.2) Personas civilmente responsables.

Son aquellas que responden por el hecho ajeno, como los padres, guardadores, amos, etc.

c.3) Personas que se aprovechan del dolo ajeno.

El inciso segundo del artículo 2316 del CC establece: “El que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho”. Será menester que esta persona no haya tenido conocimiento del dolo.

c.4) Los herederos.

El artículo 2316 del CC declara obligados a la indemnización al que hizo el daño y a sus herederos. En verdad, la regla es más general: la acción puede intentarse contra los herederos del autor, de la persona civilmente responsable y del que se aprovechó del dolo ajeno. El artículo 40 del CPP establece: “La acción civil puede entablarse contra él personalmente responsable del delito y contra sus herederos”.

c.5) Responsabilidad solidaria de los varios autores de un delito o cuasidelito.

El artículo 2317 del CC establece: “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito”.

Por excepción, no es solidaria la responsabilidad en los siguientes casos:

- i. No es solidaria la responsabilidad de los varios dueños de un edificio que causa un daño con ocasión de su ruina; son responsables a prorrata de sus cuotas de dominio conforme al segundo inciso del artículo 2323 del CC.
- ii. Tampoco es solidaria la responsabilidad por los daños que cause una cosa que cae o es arrojada de la parte superior de un edificio; la indemnización se divide por igual entre las personas que habitan las partes del edificio de donde cayó o fue arrojada la cosa, conforme al primer inciso del artículo 2328 del CC.

c.6) Caso de fraude o dolo.

El segundo inciso del artículo 2317 del CC establece que también produce una obligación solidaria de indemnizar perjuicios todo fraude o dolo cometido por dos o más personas. Habrá de tratarse de actos dolosos que no constituyan un delito civil. Ha de referirse necesariamente, por lo tanto, al dolo que incide en el cumplimiento de las obligaciones. De este modo, si varios contratantes infringen dolosamente una obligación común, son solidariamente responsables de los perjuicios que su incumplimiento ocasiona al acreedor.

d) Extensión de la reparación del daño.

Depende de la magnitud del daño causado y debe resarcirlo totalmente. Para que la indemnización sea integral debe comprender el daño emergente y el lucro cesante.

d.1) Reducción de la reparación por culpa de la víctima.

El artículo 2330 del CC dispone: “La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. El daño no se ha producido por exclusiva culpa del autor; por parte de la víctima ha existido igualmente descuido, negligencia o imprevisión. La culpa de la víctima no exime de responsabilidad al autor del daño, sino que atenúa esta responsabilidad. Para el juez es obligatorio, en tal caso, reducir el monto de la reparación. La regla del artículo 2330 del CC muestra que si bien, en principio, la culpa extracontractual no admite gradaciones y la responsabilidad se mide por la entidad del daño, no es indiferente el grado o gravedad de la culpa cometida. La culpa más grave absorberá a la más leve.

d.2) Cúmulo de indemnizaciones.

Consiste en averiguar si es viable, acumular la indemnización que se deba por el autor del delito o cuasidelito con las prestaciones que se deban a la víctima por terceros, en razón del daño que ha recibido. Una objeción se ofrece de inmediato. Por de pronto, la acumulación importaría un enriquecimiento para la víctima; por otra parte, no habría sufrido un daño, puesto que fue indemnizada; el perjuicio habría desaparecido y con ello un elemento esencial del delito o cuasidelito.

La solución se encuentra indagando si la prestación de tercero significa o no una reparación del daño causado. Ante respuesta afirmativa, no cabría el cúmulo que importaría una doble indemnización o reparación del daño. Por ejemplo, el seguro de daños es un contrato de mera indemnización, que no puede ser jamás para el asegurado ocasión de ganancia. En este caso no cabría el cúmulo. Por otra parte, el seguro de vida de personas no tiene por objeto reparar el daño que significa la muerte u otro accidente. El cúmulo, por tanto, sería admisible.

e) Extinción de la acción.

La acción encaminada a reparar el daño causado por el delito o cuasidelito se extingue por los modos generales en que se extinguen las obligaciones. Merecen considerarse solamente tres modos de extinción de la acción:

- i. La acción civil que nace del delito o cuasidelito es renunciable. La renuncia afecta sólo al renunciante y a sus sucesores y no a otras personas a quienes también corresponda el ejercicio de la acción.
- ii. También se extingue la acción por la transacción. Afecta únicamente a los que transigieron y no aprovecha ni perjudica a otras personas a quienes compete la acción.
- iii. La acción para obtener la reparación del daño prescribe, en general, en cuatro años contados desde la comisión del delito o cuasidelito conforme al artículo 2332 del CC.

e.1) Reglas especiales de prescripción.

- i. La acción contra el empresario o arquitecto por los daños causados por la ruina del edificio, a consecuencia de defectos de construcción, prescribe en cinco años.

- ii. En virtud del contrato de transporte, el transportador es obligado a indemnizar los daños causados con motivo u ocasión del transporte, y esta acción tiene un plazo de prescripción de un año.
- iii. Las Municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por la falta de servicio. No obstante, las Municipalidades tendrán derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal. El plazo de prescripción queda regido por las normas generales.
- iv. El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.
- v. Las acciones para perseguir las responsabilidades por las infracciones a la Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo prescriben en un plazo de seis meses; pero la acción civil para obtener la indemnización de daños y perjuicios derivada de los delitos penados en esa ley se regirán por las reglas generales.

2.8 Causas Eximentes y Atenuantes de Responsabilidad.



El artículo 2329 del CC formula el principio que todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser indemnizado. El autor del daño, sin embargo, puede no encontrarse en la responsabilidad de repararlo. Ello ocurre: primero, **cuando concurre una circunstancia eximente de responsabilidad**; y, segundo, **si se ha estipulado una cláusula de irresponsabilidad**.

a) Eximentes de responsabilidad.

La responsabilidad civil es independiente de la responsabilidad penal. Así se explica que la sentencia absolutoria en materia penal o el sobreseimiento definitivo, fundados en una circunstancia eximente de responsabilidad, no produzca cosa juzgada en materia civil, conforme lo dispuesto en el primer número del artículo 179 del CPC. En materia civil hay una sola y genérica causal eximente de responsabilidad: la ausencia de dolo o culpa del autor.

a.1) Causas que eximen de responsabilidad civil.

Las causales de exención de responsabilidad tienen lugar, cuando el hecho no es imputable al agente:

- i. Exime de responsabilidad el caso fortuito o fuerza mayor, esto es, el imprevisto a que no es posible resistir. El caso fortuito no exime de responsabilidad cuando sobreviene por culpa. Tampoco exime el caso fortuito de responsabilidad cuando la ley así lo establece.
- ii. Exime igualmente de responsabilidad, aunque no constituya caso fortuito, la falta de culpa.
- iii. Es también eximente de responsabilidad la culpa de la víctima. La culpa de la víctima debe ser la causa exclusiva del daño. Si el daño se debe sólo parcialmente a culpa de la víctima, que

comparte el autor del mismo, la responsabilidad únicamente se atenúa con una reducción de la indemnización.

iv. Igualmente exime de responsabilidad el hecho de un tercero extraño, por cuyos actos no se responde.

v. Exime de responsabilidad la legítima defensa. Las condiciones que legitiman la defensa, que reglamenta el cuarto número del artículo 10 del Código Penal, deben razonablemente regir en materia penal. En consecuencia, la agresión debe ser ilegítima, el medio empleado para repeler el ataque debe ser proporcional y no ha de mediar provocación suficiente por parte del que se defiende y ocasiona el daño.

vi. Suele eximir de responsabilidad lo que se denomina genéricamente el estado de necesidad. Las reglas del séptimo número del artículo 10 del Código Penal deben aplicarse igualmente al caso. En consecuencia, se requiere que el daño que se trate de evitar sea actual o eminente, que no haya otro medio practicable o menos perjudicial para impedirlo, y que el daño que se trata de evitar sea mayor que el causado para evitarlo. Fluye de esta última exigencia que el estado de necesidad no puede legitimar los daños a las personas. El daño que se trata de impedir no puede ser jamás mayor que la pérdida de la vida o integridad personal.

vii. En fin, eximen de responsabilidad ciertas inmunidades especiales de que gozan algunas personas, por ejemplo, los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.

a.2) Cláusulas de irresponsabilidad.

Una vez cometido el delito o cuasidelito la víctima puede renunciar válidamente al derecho de reclamar las indemnizaciones consiguientes. Las cláusulas de irresponsabilidad suponen que el hecho ilícito aún no se ha cometido; el futuro autor del daño y la probable víctima convienen que el primero quedará eximido de toda responsabilidad o ésta se verá atenuada o limitada.

No es dudosa la ineficacia de la estipulación de irresponsabilidad por actos dolosos, pues conforme al artículo 1465 del CC, la condonación del dolo futuro no vale. La misma solución debe adoptarse para las cláusulas de irresponsabilidad cuando el daño proviene de culpa grave, ya que de acuerdo al artículo 44 del CC, la culpa lata equivale al dolo. En suma, la cuestión de la validez de las cláusulas de irresponsabilidad no se plantea sino cuando el daño es resultado de una culpa que no merezca el calificativo de grave o lata. La doctrina se muestra hondamente dividida; pero nos inclinamos francamente por la validez de las cláusulas de irresponsabilidad. Desde luego la ley no las prohíbe; además, sus consecuencias suelen ser saludables.

El criterio más certero para decidir acerca de la validez de las cláusulas de irresponsabilidad se encuentra en la distinción acerca de la naturaleza del daño:

i. Si el daño recae en las cosas, nada obsta a la eficacia de la cláusula. El artículo 1558 del CC proclama su validez para eximirse de una responsabilidad contractual. Ninguna razón justifica que el mismo criterio no sea aplicable a la responsabilidad extracontractual.

ii. Distinta ha de ser la solución si el daño recae en las personas. La vida, la integridad física, el honor de las personas están fuera del comercio. Inspirado en este principio el artículo 300 del Código del Trabajo establece que los derechos de las víctimas de accidentes del trabajo, las indemnizaciones y rentas a que den lugar, no pueden renunciarse, cederse o compensarse y que es nulo todo pacto en contrario.

a.3) Seguro de responsabilidad.

El seguro de responsabilidad es aquel en que el asegurador toma a su cargo el riesgo de las responsabilidades pecuniarias en que puede incurrir el asegurado por los daños que cause él o las personas por quienes responde.

b) Atenuantes de responsabilidad.

La responsabilidad proveniente de un delito o cuasidelito será atenuada por alguna de estas circunstancias:

- i. Porque el daño se ha debido parcialmente a culpa de la víctima.
- ii. Por la estipulación de una cláusula atenuante de responsabilidad.

2.9 Diferencias entre Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual.

A continuación, se exponen las principales diferencias que han sido formuladas por la doctrina y la jurisprudencia y, hemos incluido algunas no contempladas por la mayoría de los tratados de derecho civil.

a) En cuanto a su generación.

La responsabilidad contractual supone la existencia de un vínculo jurídico previo, de una obligación que no se cumple o se cumple tardía o imperfectamente. El hecho ilícito, en cambio, da origen a una obligación que antes de él no existía.

b) En cuanto a la indemnización de perjuicios.

Dado que en materia contractual las partes tienen un campo más amplio del uso de la autonomía de su voluntad, supletoriamente se permite que éstas incorporen cláusulas modificatorias de la responsabilidad, pudiendo incluso fijar anticipadamente los perjuicios mediante una cláusula penal. Respecto de los hechos ilícitos, es la ley la que fija cuándo nace la obligación de indemnizar, siendo la única facultad de las partes componer como estimen conveniente el daño, derogando las normas legales que lo determinan.

c) En cuanto a la capacidad.

Sólo son incapaces de delito y cuasidelito civil los dementes, los menores de siete años y los mayores de esta edad pero menores de dieciséis años cuando han obrado sin discernimiento. Las incapacidades contractuales son más amplias; la mayor edad es a los veintiún años y existen otras

fuera de la edad o privación de razón. Esta diferencia dice relación con que resulta más fácil distinguir lo lícito de lo ilícito que responder de los daños en el cumplimiento de un contrato.

Al respecto, un problema que se plantea es determinar ¿qué pasa cuando se deja de cumplir una obligación que emana de un cuasicontrato, o cuya fuente está en la ley? ¿Se rige por las reglas de la responsabilidad contractual o de la extracontractual? Si nos atenemos a las definiciones, la responsabilidad contractual es la que emana de la infracción de un contrato y la extracontractual es la que emana de la infracción de algo que no es un contrato. Según esto, deberían aplicarse a la infracción de un cuasicontrato y a la infracción de una obligación legal, las reglas de la responsabilidad extracontractual. No obstante, la regla general de nuestro derecho es la responsabilidad contractual y, por tanto, creemos que en este caso, el incumplimiento se rige por las reglas de la responsabilidad contractual y no extracontractual. En el CC, como señalamos anteriormente, la responsabilidad contractual se encuentra en el libro IV, título XII, que se denomina "Del Efecto de las Obligaciones", sin referirlo a una especie determinada, y este título, si bien se refiere fundamentalmente a las obligaciones que emanan del contrato, su normativa es aplicable a todas las obligaciones en general, ya nazcan del contrato, del cuasicontrato o de la ley. Los relativos a los delitos y cuasidelitos civiles se encuentran en el título XXXV del libro IV. Así parece haberlo entendido el propio legislador, al establecer que el padre o madre y el guardador son responsables hasta de la culpa leve en la administración de los bienes del hijo y del pupilo respectivamente (artículos 256 y 391 del Código Civil), responsabilidad que en ciertos casos puede llegar hasta la culpa levísima. Estas son obligaciones legales. Y en el artículo 2288 del Código Civil, que establece que "el agente oficioso o gerente debe emplear en la gestión los cuidados de un buen padre de familia, pero su responsabilidad puede ser mayor o menor en razón de las circunstancias que hayan determinado la gestión, pudiendo llegar hasta la culpa levísima cuando se haya ofrecido para la gestión, impidiendo que otros lo hiciesen".

d) En cuanto a la prueba.

Dentro de las diferencias, esta es, a nuestro juicio, al igual que para la mayoría de la jurisprudencia y doctrina, la más importante. Tratándose de responsabilidad contractual, cuando se infringe una obligación, el acreedor que demanda perjuicios sólo debe probar la existencia de la obligación y no la culpa del deudor. La culpa se presume, esto se desprende de los artículos 1547 inciso 3º y 1698 del Código Civil. En cambio, en materia de responsabilidad extracontractual, corresponde a la víctima que reclama la correspondiente indemnización probar el hecho doloso o culpable que imputa al demandado. Salvo que la ley presuma la culpabilidad de este, como los casos de los artículos 2320 a 2323 y 2326 a 2329 del Código Civil. La razón de que en un caso se presuma la culpa y en otra deba probarse es, precisamente, la diferencia básica que existe entre ambos tipos de responsabilidades: en una existe un vínculo jurídico preestablecido y en la otra no, y de acuerdo al artículo 1698 "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta (...)". En el caso de la responsabilidad extracontractual la obligación de indemnizar el daño causado nace, precisamente, del delito o cuasidelito que invoca el demente. Debe

probarse la obligación para que nazca el derecho a exigir la indemnización ante su incumplimiento. En la responsabilidad contractual, de acuerdo al artículo 1698, al acreedor le basta con probar la existencia de la obligación mediante el contrato. Podemos agregar, además, que en cuanto al dolo como elemento constitutivo de ambas responsabilidades, si su concepción es la misma de acuerdo a la teoría unitaria del dolo, sus efectos son diferentes; en materia extracontractual no produce otros efectos distintos a la culpa, mientras que es un agravante de responsabilidad en el cumplimiento de los contratos. Las diferencias entre contractual y extracontractual se refieren, principalmente, a la presunción que existe en materia contractual y la graduación que ella misma admite. La extracontractual o que deriva de hechos ilícitos, debe probarla la víctima salva las veces que la ley la presume.

e) En cuanto a la graduación de la culpa.

En materia contractual, la culpa admite graduaciones. Se distinguen la culpa lata o grave, la culpa grave y la culpa levísima (artículo 44). La culpa de que responde el deudor depende si en el contrato se beneficia a una u otra parte, o ambas. En los contratos que por su naturaleza sólo son de utilidad al acreedor, como el depósito, sólo responde de culpa lata. En los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios, como el comodato, responde de culpa levísima. En los contratos que se hacen para beneficio recíproco de ambas partes, el deudor responde de culpa leve. En materia delictual y cuasidelictual, en cambio, la jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina en general, concluyen, de manera unánime, que en la responsabilidad extracontractual la culpa no admite graduaciones y, en consecuencia, se responde de toda clase de culpa: toda falta de diligencia o cuidado, aunque levísima que sea, engendra responsabilidad.

Una parte de la doctrina, sin embargo, no piensa lo mismo. El código define la culpa en el artículo 44. Es cierto que esas definiciones se refieren a la culpa contractual, en razón de que es la única que admite graduaciones; sin embargo, son igualmente aplicables a la culpa extracontractual. La culpa es la misma en materia contractual y en materia cuasidelictual civil. El artículo 44 se limita a decir que la ley distingue tres clases de culpa o descuido. Creemos que, por regla general, la culpa no admite graduación en materia de responsabilidad extracontractual. Al respecto, la jurisprudencia ha entendido, que en el orden contractual, la culpa se gradúa en razón de la mayor o menor utilidad que una parte obtiene de un contrato en relación con la otra; no se exige la misma diligencia a quien recibe o pertenece toda la utilidad o beneficio de un contrato a quien no obtiene de él utilidad alguna. Pero, en materia de responsabilidad cuasidelictual, la culpa no tiene grados ni admite diferencias: hay culpa o no la hay, pues lo único que importa, para los efectos del pleito, es el monto de los daños y es esto lo que regula indemnización, con entera prescindencia de la gravedad de la culpa.

f) En cuanto a los perjuicios indemnizables.

La indemnización extracontractual es más completa que la contractual en materia de contratos. Comprende todo el daño sufrido por la víctima, pues no se distingue entre perjuicios previstos o imprevistos. En cambio, en materia contractual, el deudor sólo es responsable de los perjuicios

que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, salvo que pueda imputársele dolo, en cuyo caso responde aún de los imprevistos. Esta diferencia también deriva de la existencia del vínculo jurídico previo. Existe una discusión doctrinal respecto a si en nuestro derecho la indemnización abarca también los daños extrapatrimoniales o morales. Hoy en día, tanto la doctrina como la jurisprudencia, admiten la reparación del daño moral en materia de responsabilidad civil delictual o cuasidelictual. Pero aún se discute, sin embargo, en materia de responsabilidad contractual. En Chile, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, tradicionalmente, han opinado en sentido contrario. Dentro de los principales argumentos que esgrime la doctrina mayoritaria para sostener la posición de la no reparación del daño moral en materia contractual, destacan principalmente dos: La exigencia de que la obligación que emana de un contrato goce de un contenido patrimonial. Las limitaciones que impone la legislación para la reparación de esta clase de daños en materia de contratos. No obstante lo anterior, a juicio de un sector de la doctrina, sí es indemnizable el daño moral en materia contractual; en conformidad a lo que sostienen, Josseland, Planiol, Ripert, los hermanos Mazeud y, en Chile, los profesores Fernando Fueyo Laneri y Tomasello Hart, que no divisan razón para que se acepte la indemnización del daño moral en la responsabilidad extracontractual y se rechace en la contractual. Los profesores Fueyo, Tomasello, Domínguez Hidalgo, la doctrina y un par de sentencias, han clarificado que el daño moral, que puede causar el incumplimiento de un contrato, es perfectamente posible de reparar. Podemos observar, que la jurisprudencia y la doctrina actual se orientan en el sentido de estimar procedente la reparación del daño moral derivado de contrato, por ser imperativo de la simple lógica y de toda equidad, al no existir fundamentos que autoricen a introducir una distinción tan radical en el seno de la responsabilidad civil, para considerarlo únicamente procedente en materia de responsabilidad extracontractual. La responsabilidad civil es una materia que experimenta una constante evolución y cambios dentro del ámbito del derecho y, la resarcibilidad o no resarcibilidad de daño moral derivado de infracción de un contrato, no ha quedado fuera de esa evolución. Así lo demuestra el derecho comparado, sobre todo el common law y algunas legislaciones de la tradición romana germánica, incluyendo la nuestra.

g) En cuanto a la mora.

En la responsabilidad extracontractual, la obligación de indemnizar nace cuando se produce el hecho ilícito, dañoso; mientras tanto, en materia contractual para que se deban perjuicios se requiere colocar al deudor en mora. Es decir, para el autor Rubén Celis Rodríguez, en materia de responsabilidad contractual, la obligación de indemnizar perjuicios por incumplimiento de una obligación, requiere que se constituya en mora al deudor, salvo que se trate de una obligación de no hacer, en que basta el hecho de la contravención. En materia de responsabilidad extracontractual, en cambio, la constitución en mora es innecesaria, porque no hay un vínculo jurídico previo de cuyo incumplimiento se trata, sino que en ella el perjuicio resulta de la mera existencia del hecho de la ejecución de un delito o cuasidelito.

h) En cuanto a la pluralidad de los deudores.

Tratándose de los contratos, la obligación de indemnizar es por regla conjunta, salvo casos de excepción: los autores del hecho ilícito responden solidariamente. En cuanto a la solidaridad si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas responderá solidariamente por el daño causado (Art.2317 del Código Civil). En cambio, si son varios deudores que han dejado de cumplir una obligación contractual culpablemente, la responsabilidad es simplemente conjunta, pero se transforma en solidaria si se estipuló, si así lo dispone la ley o si se ha actuado con dolo.

i) En cuanto a la prescripción.

La prescripción de una acción de indemnización por incumplimiento de una obligación es de cinco años, desde que se hizo exigible; la extracontractual es de cuatro años, desde la perpetración del hecho ilícito. Hemos visto qué sucede cuando la obligación de indemnizar perjuicios emana del incumplimiento de una obligación contraída mediante un contrato, y, también analizamos que sucedía con aquella obligación de perjuicio que emanaba de la ejecución de un hecho ilícito que provocaba un daño a la víctima. Pero ahora se nos plantea el problema de determinar qué pasa cuando se deja de cumplir una obligación que emana de un cuasicontrato o cuya fuente está en la ley.

En Francia, se sostiene que las normas sobre responsabilidad extracontractual son la regla general, aplicables a lo no previsto por el legislador. En Chile, la situación es diferente, porque el título XII del libro IV trata la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones bajo el título: “Del efecto de las obligaciones”, expresión que las involucra a todas, y se reputan los hechos ilícitos por el tratamiento separado que les otorga bastante más adelante. El hecho de que la responsabilidad común sea la responsabilidad contractual, es sostenido por gran parte de la doctrina nacional. Así lo han entendido autores como Alessandri, Rubén Celis Rodríguez y Rene Abeliuk.

En consecuencia, las normas relativas a la responsabilidad contractual no se aplican sólo a las obligaciones derivadas de un contrato, sino que también a las cuasi contractuales y a las simplemente legales.

j) En cuanto a la facultades de los jueces para fijar el monto de la reparación.

Son muchas más amplias las facultades del juez en materia de responsabilidad extracontractual. El artículo 173 del CPC, dice que se aplica sólo a la responsabilidad contractual pero no en la responsabilidad extracontractual, al disponer: “Cuando una de las partes halla ser condenada a la devolución de frutos o a la indemnización de perjuicios, y si ha licitado sobre su especie y monto, la sentencia determinara la cantidad liquida que por ésta causa debe abonarse, o declarará sin lugar el pago, si no resulta probados la especie y el monto de lo que se cobra o, por lo menos las

bases que deban servir para su liquidación al ejecutarse la sentencia. En el caso de que no se haya litigado sobre la especie y el monto de los frutos o perjuicios, el Tribunal reservará a las partes el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso”

k) Competencia de los Tribunales de Justicia.

La acción de perjuicios, derivada de la infracción de un contrato, puede deducirse ante el tribunal señalado en él o, a falta de convención, ante el juez del lugar donde ha debido cumplirse la obligación, donde ésta se contrajo, donde se encuentra la cosa al tiempo de la demanda o se hallaba al tiempo del contrato o ante el juez del domicilio del demandado, según el caso. Por su parte, la acción delictual o cuasidelictual civil, debe deducirse ante el juez del domicilio del demandado, que, por lo general, es el único competente.